

Margaret Patricia Kerr *Appellant*

v.

Nelson Dennis Baranow *Respondent*

- and -

Michele Vanasse *Appellant*

v.

David Seguin *Respondent*

INDEXED AS: KERR v. BARANOW

2011 SCC 10

File Nos.: 33157, 33358.

2010: April 21; 2011: February 18.

Present: McLachlin C.J. and Binnie, LeBel, Abella, Charron, Rothstein and Cromwell JJ.

ON APPEAL FROM THE COURTS OF APPEAL FOR
BRITISH COLUMBIA AND ONTARIO

Family law — Common law spouses — Property — Unjust enrichment — Monetary remedy — Whether monetary remedy restricted to quantum meruit award — Whether evidence of joint family venture should be considered in conferring remedy — Whether mutual benefit conferral and reasonable expectations of parties should be considered in assessing award.

Family law — Common law spouses — Property — Resulting trust — Whether evidence of common intention should be considered in context of resulting trust — Whether resulting trust principles apply to property or monetary award in resolution of domestic cases.

Family law — Common law spouses — Support — Parties separating after living together for more than 25 years — Female partner commencing proceedings for a share of property and support — Whether support should be payable from date of trial or date on which proceedings commenced.

In the *Kerr* appeal, K and B, a couple in their late 60s separated after a common law relationship of more

Margaret Patricia Kerr *Appelante*

c.

Nelson Dennis Baranow *Intimé*

- et -

Michele Vanasse *Appelante*

c.

David Seguin *Intimé*

RÉPERTORIÉ : KERR c. BARANOW

2011 CSC 10

N^{os} du greffe : 33157, 33358.

2010 : 21 avril; 2011 : 18 février.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

EN APPEL DES COURS D'APPEL DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE ET DE L'ONTARIO

Droit de la famille — Conjoint de fait — Biens — Enrichissement injustifié — Réparation pécuniaire — Une réparation pécuniaire est-elle restreinte au quantum meruit? — La preuve de coentreprise familiale doit-elle être prise en compte au moment d'accorder une réparation? — Les avantages réciproques et les attentes raisonnables des parties doivent-ils être pris en compte dans l'évaluation de la réparation?

Droit de la famille — Conjoint de fait — Biens — Fiducie résultoire — La preuve de l'intention commune doit-elle être prise en compte dans le contexte de la fiducie résultoire? — Les principes de la fiducie résultoire s'appliquent-ils aux réparations accordées en biens ou en argent dans le cadre de la résolution des litiges familiaux?

Droit de la famille — Conjoint de fait — Aliments — Séparation des conjoints après plus de 25 ans de vie commune — Action de la conjointe réclamant une pension alimentaire et une part des biens — La pension alimentaire est-elle rétroactive à la date du procès ou à la date d'introduction de l'instance?

Dans le pourvoi *Kerr*, K et B, tous deux dans la soixantaine avancée, se sont séparés après plus de 25

than 25 years. They both had worked through much of that time and each had contributed in various ways to their mutual welfare. K claimed support and a share of property in B's name based on resulting trust and unjust enrichment principles. B counterclaimed that K had been unjustly enriched by his housekeeping and personal assistance services provided after K suffered a debilitating stroke. The trial judge awarded K \$315,000, a third of the value of the home in B's name that they had shared, both by way of resulting trust and unjust enrichment, based on his conclusion that K had provided \$60,000 worth of equity and assets at the beginning of their relationship. He also awarded K \$1,739 per month in spousal support effective the date she commenced proceedings. The Court of Appeal concluded that K did not make a financial contribution to the acquisition or improvement of B's property that was the basis for her award at trial, and dismissed her property claims. A new trial was ordered for B's counterclaim. The Court of Appeal further held that the commencement date of the spousal support should be the date of trial.

In the *Vanasse* appeal, it was agreed that S was unjustly enriched by the contributions of his partner, V, during their 12-year common law relationship. For the first four years of cohabitation, both parties pursued their respective careers. In 1997, V took a leave of absence from her employment and the couple moved to Halifax so that S could pursue a business opportunity. Over the next three and a half years, their children were born and V stayed at home to care for them and performed the domestic labour. S worked long hours and travelled extensively for business. In 1998, S stepped down as CEO of the business and the family returned to Ottawa where they bought a home in joint names. In 2000, S received approximately \$11 million for his shares in the business and from that time, until their separation in 2005, he participated more with the domestic chores. The trial judge found no unjust enrichment for the first and last periods of their cohabitation, but held that S had been unjustly enriched at V's expense during the period in which the children were born. V was entitled to half of the value of the wealth S accumulated during the period of unjust enrichment, less her interest in the home and RRSPs in her name. The court of appeal set aside this award and directed that the proper approach to valuation was a *quantum meruit* calculation in which the value each

ans de vie commune. Ils avaient travaillé pendant presque toutes ces années et avaient chacun contribué de diverses façons à leur bien-être commun. Sur le fondement de la fiducie résultoire et de l'enrichissement injustifié, K a réclamé une pension alimentaire et une part des biens détenus au nom de B. Par demande reconventionnelle, B a cherché à faire reconnaître que K s'était injustement enrichie grâce aux services d'entretien ménager qu'il lui avait rendus et à l'aide personnelle qu'il lui avait apportée après qu'elle eut été victime d'un grave accident vasculaire. Le juge de première instance a accordé à K 315 000 \$ et un tiers de la valeur de la maison de B qu'ils avaient partagée, sur le fondement de la fiducie résultoire et de l'enrichissement injustifié, car il avait conclu que K avait fourni des capitaux et des actifs d'une valeur de 60 000 \$ au début de la relation. Il a également accordé à K une pension alimentaire mensuelle de 1 739 \$, rétroactive à la date d'introduction de l'instance. La Cour d'appel a conclu que K n'a pas contribué financièrement à l'acquisition ou à l'amélioration de la maison de B, ce qui constituait le fondement de la réparation accordée à K en première instance, et elle a rejeté ses réclamations fondées sur un droit de propriété. La Cour d'appel a ordonné une nouvelle audition de la demande reconventionnelle de B. Elle a en outre statué que l'ordonnance alimentaire serait rétroactive à la date du début du procès.

Dans le pourvoi *Vanasse*, il a été admis que S s'est injustement enrichi grâce aux contributions de sa conjointe, V, au cours de leur union de fait qui a duré 12 ans. Pendant les quatre premières années de leur relation, les parties ont poursuivi leurs carrières respectives. En 1997, V a pris un congé et le couple a déménagé à Halifax afin que S puisse y développer son entreprise. Au cours des trois années et demie qui ont suivi, S et V ont eu des enfants et V est demeurée à la maison pour s'occuper d'eux et elle s'est occupée des tâches domestiques. S travaillait de longues heures et voyageait fréquemment pour ses affaires. En 1998, S a démissionné de son poste de PDG de l'entreprise et la famille est retournée à Ottawa où ils ont acheté une maison enregistrée en leurs deux noms. En 2000, S a reçu environ 11 millions de dollars en vendant ses actions dans l'entreprise et à compter de ce moment, jusqu'à la séparation en 2005, il s'est acquitté davantage des tâches domestiques. La juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement injuste au cours des première et dernière périodes de cohabitation, mais a conclu que S s'était injustement enrichi aux dépens de V durant la période au cours de laquelle les enfants sont nés. V a eu droit à la moitié de la valeur de la richesse accumulée par S au cours de la période d'enrichissement injustifié, moins la valeur de sa part dans la résidence familiale et

party received from the other was assessed and set off.

Held: In *Kerr*, the appeal on the spousal support issue should be allowed and the order of the trial judge should be restored. The appeal from the order dismissing K's unjust enrichment claim should also be allowed and a new trial ordered. The appeal from the order dismissing K's claim in resulting trust should be dismissed. The order for a new hearing of B's counterclaim should be affirmed.

Held: In *Vanasse*, the appeal should be allowed and the order of the trial judge restored.

These appeals require the resolution of five main issues. The first concerns the role of the "common intention" resulting trust in claims by domestic partners. The second issue is whether the monetary remedy for a successful unjust enrichment claim must always be assessed on a *quantum meruit* basis. The third area relates to mutual benefit conferral in the context of an unjust enrichment claim and when this should be taken into account. The fourth concerns the role the parties' reasonable expectations play in the unjust enrichment analysis. Finally, in the *Kerr* appeal, this Court must also decide the effective date of the commencement of spousal support.

For unmarried persons in domestic relationships in most common law provinces, judge-made law is the only option for addressing the property consequences of the breakdown of those relationships. The main legal mechanisms available have been the resulting trust and the action in unjust enrichment. Resulting trusts arise from gratuitous transfers in two types of situations: the transfer of property from one partner to the other without consideration, and the joint contribution by two partners to the acquisition of property, title to which is in the name of only one of them. The underlying legal principle is that contributions to the acquisition of a property, which were not reflected in the legal title, might nonetheless give rise to a property interest. In Canada, added to this underlying notion was the idea that a resulting trust could arise based solely on the "common intention" of the parties that the non-owner partner was intended to have an interest. This theory is doctrinally unsound, however, and should

ses REER. La cour d'appel a annulé cette décision et a statué que la réparation devait être établie par un calcul fondé sur le *quantum meruit*, où la valeur que chacune des parties a reçue de l'autre est évaluée et défalquée.

Arrêt : Dans *Kerr*, le pourvoi sur la question de la pension alimentaire est accueilli et l'ordonnance du juge de première instance est rétablie. Le pourvoi en ce qui concerne la décision de la Cour d'appel de rejeter la demande de K fondée sur l'enrichissement injustifié est également accueilli et une nouvelle audition de cette demande est ordonnée. Le pourvoi formé contre la décision rejetant la demande de K relative à une fiducie résultoire est rejeté. L'ordonnance d'une nouvelle audition de la demande reconventionnelle de B est confirmée.

Arrêt : Dans *Vanasse*, le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de la juge de première instance est rétablie.

Ces pourvois nous obligent à répondre à cinq questions principales. La première porte sur le rôle de la fiducie résultoire fondée sur « l'intention commune » dans les réclamations présentées par les conjoints de fait. La deuxième question consiste à savoir si l'indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié doit toujours être évaluée en fonction du *quantum meruit*. La troisième question a trait aux avantages réciproques dans le contexte d'une réclamation fondée sur l'enrichissement injuste et au moment auquel ceux-ci doivent être pris en compte. La quatrième question traite du rôle des attentes raisonnables des parties dans l'analyse de l'enrichissement injustifié. Enfin, dans le pourvoi *Kerr*, la Cour doit aussi déterminer la date de prise d'effet de l'ordonnance alimentaire.

En ce qui concerne les conjoints non mariés dans la plupart des provinces de common law, le recours au droit jurisprudentiel est la seule solution permettant de traiter des conséquences financières de la rupture des relations conjugales. La fiducie résultoire et l'action fondée sur l'enrichissement injustifié sont les principaux mécanismes juridiques qui s'offrent aux parties. Les fiducies résultoires découlent de transferts à titre gratuit dans deux types de situations : le transfert d'un bien d'un partenaire à l'autre sans aucune considération, et la contribution des deux partenaires à l'acquisition d'un bien, dont le titre est au nom d'un seul des partenaires. Selon le principe juridique sous-jacent, les contributions à l'acquisition de biens, qui n'étaient pas indiquées dans le titre de propriété, peuvent néanmoins créer un droit de propriété. À cette notion sous-jacente s'ajoutait l'idée, au Canada, qu'une fiducie résultoire pouvait découler de la seule « intention commune » des parties d'accorder un droit au partenaire

have no continuing role in the resolution of domestic property disputes. While traditional resulting trust principles may well have a role to play in the resolution of property disputes between unmarried domestic partners, parties have increasingly turned to the law of unjust enrichment and the remedial constructive trust. Since the decision in *Pettkus v. Becker*, the law of unjust enrichment has provided a much less artificial, more comprehensive and more principled basis to address claims for the distribution of assets on the breakdown of domestic relationships. It permits recovery whenever the plaintiff can establish three elements: an enrichment of the defendant by the plaintiff, a corresponding deprivation of the plaintiff, and the absence of a juristic reason for the enrichment. This Court has taken a straightforward economic approach to the elements of enrichment and corresponding deprivation. The plaintiff must show that he or she has given a tangible benefit to the defendant that the defendant received and retained. Further, the enrichment must correspond to a deprivation that the plaintiff has suffered. Importantly, provision of domestic services may support a claim for unjust enrichment. The absence of a juristic reason for the enrichment means that there is no reason in law or justice for the defendant's retention of the benefit conferred by the plaintiff. This third element also provides for due consideration of the autonomy of the parties, their legitimate expectations and the right to order their affairs by contract.

There are two steps to the juristic reason analysis. First, the established categories of juristic reason must be considered, which could include benefits conferred by way of gift or pursuant to a legal obligation. In their absence, the second step permits consideration of the reasonable expectations of the parties and public policy considerations to assess whether particular enrichments are unjust.

The object of the remedy for unjust enrichment is to require the defendant to reverse the unjustified enrichment and may attract either a "personal restitutionary award" or a "restitutionary proprietary award". In most cases, a monetary award will be sufficient to remedy the unjust enrichment but two issues raise difficulties in determining appropriate compensation. Where there has been a mutual conferral of benefits, it is often difficult for the court to retroactively value every service rendered by each party to the other. While the value of domestic services is not questioned, it would be unjust to only consider the contributions of one party. A second

non propriétaire. Cette théorie est toutefois sans fondement sur le plan théorique et ne devrait plus avoir aucun rôle à jouer dans la résolution des litiges familiaux. Si les principes traditionnels de la fiducie résultoire peuvent jouer un rôle dans la résolution des litiges entre partenaires non mariés, les parties ont eu recours de plus en plus au droit de l'enrichissement injustifié et à la fiducie constructive de nature réparatoire. Depuis l'arrêt *Pettkus c. Becker*, le droit de l'enrichissement injustifié offre un fondement beaucoup moins artificiel, plus complet et plus rationnel pour traiter les demandes de partage des biens après la rupture des relations conjugales. Il permet le recouvrement dès lors que le demandeur peut prouver trois éléments : un enrichissement du défendeur par le demandeur, un appauvrissement correspondant du demandeur, et l'absence de tout motif juridique de l'enrichissement. Notre Cour a appliqué une analyse économique simple aux éléments d'enrichissement et d'appauvrissement correspondant. Le demandeur doit prouver qu'il a procuré un avantage tangible au défendeur qui a reçu et retenu cet avantage. De plus, l'enrichissement doit correspondre à un appauvrissement du demandeur. Fait important, la prestation de services domestiques peut appuyer une action pour enrichissement injustifié. L'absence d'un motif juridique pour l'enrichissement signifie que ni le droit ni les exigences de la justice ne permettent au défendeur de conserver l'avantage conféré par le demandeur. Ce troisième élément permet aussi de prendre dûment en considération l'autonomie des parties, leurs attentes légitimes et leur droit de régler contractuellement leurs affaires.

L'analyse du motif juridique comprend deux étapes. Premièrement, les catégories établies de motifs juridiques doivent être examinées, par exemple l'avantage conféré par don ou découlant d'une obligation légale. En l'absence de motifs juridiques d'une catégorie, la deuxième étape autorise la prise en considération des attentes légitimes des parties ainsi que des considérations d'intérêt public afin de déterminer si l'enrichissement est injustifié.

La réparation fondée sur l'enrichissement injustifié oblige le défendeur à rembourser ou à annuler l'enrichissement et peut donner lieu soit à une « indemnisation », soit à une « restitution du bien ». Dans la plupart des cas, une réparation pécuniaire suffira à corriger l'enrichissement injustifié, mais deux questions suscitent des difficultés dans la détermination de la réparation adéquate. Dans les cas où les conjoints ont mutuellement tiré des avantages, la cour a souvent de la difficulté à évaluer rétroactivement chaque service rendu par chacune des parties à l'autre partie. Bien que la valeur des services domestiques ne soit pas remise en question, il

difficulty is whether a monetary award must invariably be calculated on a *quantum meruit*, “value received” or “fee-for-services” basis or whether that monetary relief may be assessed more flexibly, on a “value survived basis” by reference to the overall increase in the couple’s wealth during the relationship. In some cases, a proprietary remedy may be required. Where the plaintiff can demonstrate a link or causal connection between his or her contributions and the acquisition, preservation, maintenance or improvement of the disputed property, and that a monetary award would be insufficient, a share of the property proportionate to the claimant’s contribution can be impressed with a constructive trust in his or her favour.

Three areas in the law of unjust enrichment require clarification. Once the choice has been made to award a monetary remedy, the question is how to quantify it. If a monetary remedy must invariably be quantified on a *quantum meruit* basis, the remedial choice in unjust enrichment cases becomes whether to impose a constructive trust or to order a monetary remedy calculated on a *quantum meruit* basis. This dichotomy of remedial choice should be rejected, however, as the value survived measure is a perfectly plausible alternative to the constructive trust. Restricting the money remedy to a fee-for-service calculation is inappropriate for four reasons. First, it fails to reflect the reality of the lives of many domestic partners. The basis of all domestic unjust enrichment claims do not fit into only two categories — those where the enrichment consists of the provision of unpaid services, and those where it consists of an unrecognized contribution to the acquisition, improvement, maintenance or preservation of specific property. Where the contributions of both parties over time have resulted in an accumulation of wealth, the unjust enrichment occurs when one party retains a disproportionate share of the assets that are the product of their joint efforts following the breakdown of their relationship. The required link between the contributions and a specific property may not exist but there may clearly be a link between the joint efforts of the parties and the accumulation of wealth. While the law of unjust enrichment does not mandate a presumption of equal sharing, nor does the mere fact of cohabitation entitle one party to share in the other’s property, the legal consequences of the breakdown of a domestic relationship should reflect realistically the way people live their lives. Second, the remedial dichotomy is inconsistent with the inherent flexibility of unjust enrichment and with the Court’s approach to equitable

serait injuste de tenir compte des contributions d’une seule partie. Une deuxième difficulté tient à la question de savoir si une réparation pécuniaire doit invariablement être calculée en fonction du *quantum meruit*, de la « valeur reçue » ou de la « rémunération des services », ou si la réparation pécuniaire peut être évaluée de manière plus souple, selon la méthode fondée sur la « valeur accumulée », soit l’augmentation globale de la richesse du couple pendant l’union. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’accorder une réparation fondée sur le droit de propriété. Si le demandeur peut établir un lien ou un rapport de causalité entre ses contributions et l’acquisition, la conservation, l’entretien ou l’amélioration du bien en cause, et qu’une réparation pécuniaire serait insuffisante, une part du bien proportionnelle à la contribution du demandeur peut faire l’objet d’une fiducie constructive en sa faveur.

Trois sujets dans les règles relatives à l’enrichissement injustifié nécessitent des précisions. Une fois que la décision est prise d’accorder une réparation pécuniaire, la question se pose de savoir comment quantifier cette réparation. Si la réparation pécuniaire doit invariablement être quantifiée en fonction du *quantum meruit*, il faut alors, dans les cas d’enrichissement injustifié, se demander s’il faut choisir d’imposer une fiducie constructive ou d’ordonner une réparation pécuniaire calculée en fonction du *quantum meruit*. Cette dichotomie des mesures de réparation devrait toutefois être rejetée car la réparation fondée sur la valeur accumulée est une alternative tout à fait plausible à la fiducie constructive. Il est inapproprié de calculer la réparation pécuniaire en fonction de la rémunération des services rendus, et ce, pour quatre raisons. Premièrement, ce type de calcul ne reflète pas la réalité de nombreux conjoints vivant en union libre. Les fondements de toutes les actions pour enrichissement injustifié intentées par des conjoints de fait n’entrent pas dans deux catégories seulement — celle où l’enrichissement découle de la prestation de services non rémunérés, et celle où il découle d’une contribution non reconnue à l’acquisition, à l’amélioration, à l’entretien ou à la conservation d’un bien en particulier. Lorsque les contributions des deux parties ont, au fil du temps, entraîné une accumulation de la richesse, il y a un enrichissement injustifié quand une partie conserve, après la rupture, une part disproportionnée des biens obtenus grâce à l’effort conjoint des deux parties. Le lien requis entre les contributions et un bien en particulier n’existe peut-être pas, mais il peut y avoir un lien incontestable entre les efforts conjoints des parties et l’accumulation de richesse. Bien que les règles relatives à l’enrichissement injustifié n’entraînent pas une présomption de partage égal et que la cohabitation, en soi, ne confère pas à

remedies. Moreover, the Court has recognized that, given the wide variety of circumstances addressed by the traditional categories of unjust enrichment, as well as the flexibility of the broader, principled approach, its development requires recourse to a number of different sorts of remedies depending on the circumstances. There is no reason in principle why one of the traditional categories of unjust enrichment should be used to force the monetary remedy for all present domestic unjust enrichment cases into a remedial strait-jacket. What is essential is that there must be a link between the contribution and the accumulation of wealth. Where that link exists, and a proprietary remedy is either inappropriate or unnecessary, the monetary award should be fashioned to reflect the true nature of the enrichment and the corresponding deprivation. Third, the remedial dichotomy ignores the historical basis of *quantum meruit* claims. Finally, a remedial dichotomy is not mandated, as has been suggested, by the Court's judgment in *Peter v. Beblow*.

Where the unjust enrichment is best characterized as an unjust retention of a disproportionate share of assets accumulated during the course of a "joint family venture" to which both partners have contributed, the monetary remedy should be calculated according to the share of the accumulated wealth proportionate to the claimant's contributions. Where the spouses are domestic and financial partners, there is no need for "dueling *quantum meruits*". The law of unjust enrichment, including the remedial constructive trust, is the preferable method of responding to the inequities brought about by the breakdown of a common law relationship, since the remedies for unjust enrichment "are tailored to the parties' specific situation and grievances". To be entitled to a monetary remedy on a value-survived basis, the claimant must show both that there was a joint family venture and a link between his or her contributions and the accumulation of wealth.

To determine whether the parties have, in fact, been engaged in a joint family venture, the particular circumstances of each particular relationship must be taken into account. This is a question of fact and must

une personne le droit à une part des biens de l'autre personne, les conséquences juridiques de la rupture d'une relation conjugale devraient refléter la façon dont les gens vivent. Deuxièmement, la dichotomie des mesures de réparation est incompatible avec la souplesse inhérente à l'enrichissement injustifié et avec l'approche de la Cour à l'égard des réparations en equity. De plus, la Cour a reconnu que, compte tenu de la grande variété de situations relevant des catégories traditionnelles de l'enrichissement injustifié et de la souplesse de l'approche plus générale et raisonnée, le principe exige qu'on ait recours à différents types de réparation selon les circonstances. Rien ne justifie, en principe, qu'une des catégories traditionnelles d'enrichissement injustifié serve à imposer la réparation pécuniaire dans tous les cas d'enrichissement injustifié entre conjoints de fait. Il est essentiel qu'il y ait un lien entre la contribution et l'accumulation de la richesse. Lorsque ce lien est établi, et qu'une réparation fondée sur le droit de propriété est inappropriée ou inutile, la réparation pécuniaire devrait être adaptée pour refléter la nature véritable de l'enrichissement et de l'appauvrissement correspondant. Troisièmement, la dichotomie des mesures de réparation ne tient pas compte de l'historique des réclamations fondées sur le *quantum meruit*. Enfin, l'arrêt *Peter c. Beblow* n'impose pas, comme il a déjà été donné à penser, la dichotomie des mesures de réparation.

Dans les cas où la meilleure façon de qualifier l'enrichissement injustifié est de le considérer comme une rétention injuste d'une part disproportionnée des biens accumulés dans le cadre d'une « coentreprise familiale » à laquelle les deux conjoints ont contribué, la réparation pécuniaire devrait être calculée en fonction de la part proportionnelle de la contribution du demandeur à cette accumulation de la richesse. Lorsque les conjoints sont des partenaires conjugaux et financiers, il n'est nul besoin d'un « duel de *quantum meruit* ». Les règles relatives à l'enrichissement injustifié, y compris la fiducie constructive de nature réparatoire, constituent la meilleure façon de remédier aux iniquités susceptibles de survenir au moment de la rupture d'une union de fait puisque la réparation pour enrichissement injustifié « est adaptée à la situation et aux revendications particulières des parties ». Pour avoir droit à une réparation pécuniaire fondée sur la valeur accumulée, le demandeur doit prouver qu'une coentreprise familiale existait effectivement et qu'il existe un lien entre ses contributions à la coentreprise et l'accumulation de la richesse.

Pour déterminer si les parties ont, de fait, été engagées dans une coentreprise familiale, les circonstances particulières de chaque relation doivent être prises en compte. Il s'agit d'une question de fait que l'on peut

be assessed by having regard to all of the relevant circumstances, including factors relating to mutual effort, economic integration, actual intent and priority of the family. The pooling of effort and team work, the decision to have and raise children together, and the length of the relationship may all point towards the extent to which the parties have formed a true partnership and jointly worked towards important mutual goals. The use of parties' funds entirely for family purposes or where one spouse takes on all, or a greater proportion, of the domestic labour, freeing the other spouse from those responsibilities and enabling him or her to pursue activities in the paid workforce, may also indicate a pooling of resources. The more extensive the integration of the couple's finances, economic interests and economic well-being, the more likely it is that they have engaged in a joint family venture. The actual intentions of the parties, either express or inferred from their conduct, must be given considerable weight. Their conduct may show that they intended the domestic and professional spheres of their lives to be part of a larger, common venture, but may also conversely negate the existence of a joint family venture, or support the conclusion that particular assets were to be held independently. Another consideration is whether and to what extent the parties have given priority to the family in their decision making, and whether there has been detrimental reliance on the relationship, by one or both of the parties, for the sake of the family. This may occur where one party leaves the workforce for a period of time to raise children; relocates for the benefit of the other party's career; foregoes career or educational advancement for the benefit of the family or relationship; or accepts underemployment in order to balance the financial and domestic needs of the family unit.

The unjust enrichment analysis in domestic situations is often complicated by the fact that there has been a mutual conferral of benefits. When the appropriate remedy is a money award based on a fee-for-services provided approach, the fact that the defendant has also provided services to the claimant should mainly be considered at the defence and remedy stages of the analysis but may be considered at the juristic reason stage to the extent that the provision of reciprocal benefits constitutes relevant evidence of the existence (or non-existence) of a juristic reason for the enrichment. However, given that the purpose of the juristic reason

apprécier en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les facteurs relatifs à l'effort commun, à l'intégration économique, à l'intention réelle et à la priorité accordée à la famille. Les efforts conjoints et le travail d'équipe, la décision d'avoir et d'éduquer des enfants ensemble, ainsi que la durée de la relation peuvent tous indiquer la mesure dans laquelle, le cas échéant, les parties constituaient véritablement une association et ont collaboré à la réalisation d'objectifs communs importants. Le fait que les fonds des parties soient entièrement consacrés à la famille ou le fait qu'un conjoint s'acquitte de la totalité, ou de la plus grande partie, des travaux domestiques, libérant l'autre de ces responsabilités et lui permettant de se consacrer à ses activités rémunérées à l'extérieur, peuvent également indiquer une mise en commun des ressources. Plus le niveau d'intégration des finances, des intérêts économiques et du bien-être économique des conjoints est élevé, plus il est probable que ceux-ci se seront engagés dans une coentreprise familiale. Il faut accorder une importance considérable aux intentions réelles des parties; ces intentions peuvent avoir été exprimées par les parties ou inférées de leur conduite. La conduite des parties peut démontrer qu'elles voulaient que leurs vies familiale et professionnelle fassent partie d'un tout, d'une entreprise commune, mais pourrait aussi permettre d'écarter l'existence d'une coentreprise familiale ou étayer la conclusion selon laquelle des biens déterminés devaient être détenus de façon indépendante. Un autre facteur à considérer consiste à savoir si, et dans quelle mesure, les conjoints avaient donné la priorité à la famille dans le processus décisionnel, et si, pour le bien-être de la famille, une des parties ou les deux se sont fiées à la relation à leur détriment. Cela peut survenir lorsqu'une partie quitte le marché du travail pendant un certain temps pour élever les enfants; lorsqu'elle déménage pour aider la carrière de l'autre partie; lorsqu'elle renonce à une carrière ou à une formation pour le bien de la famille ou de la relation; et lorsqu'elle accepte un sous-emploi dans le but d'équilibrer les besoins financiers et domestiques de l'unité familiale.

L'analyse de l'enrichissement injustifié en matière familiale se complique souvent du fait qu'il y a eu des avantages réciproques. Lorsque la réparation appropriée consiste en une indemnité pécuniaire calculée en fonction de la valeur de la rémunération des services rendus, le fait que le défendeur ait aussi fourni des services au demandeur devrait être examiné principalement au stade de la défense ou à celui de la réparation, mais il est aussi possible de le faire au stade de l'analyse du motif juridique dans la mesure où l'octroi d'avantages réciproques constitue une preuve pertinente de l'existence (ou de l'absence) d'un motif juridique de

step in the analysis is to determine whether the enrichment was just, not its extent, mutual benefit conferral should only be considered at the juristic reason stage for that limited purpose. Otherwise, the mutual exchange of benefits should be taken into account only after the three elements of an unjust enrichment claim have been established.

Claimants must show that there is no juristic reason falling within any of the established categories, such as whether the benefit was a gift or pursuant to a legal obligation. It is then open to the defendant to show that a different juristic reason for the enrichment should be recognized, having regard to the parties' reasonable expectations and public policy considerations. Mutual benefit conferral and the parties' reasonable expectations have a very limited role to play at the first step of the juristic reason analysis. In some cases, the fact that mutual benefits were conferred or that the benefits were provided pursuant to the parties' reasonable expectations may be relevant evidence of whether one of the existing categories of juristic reasons is present. The parties' reasonable or legitimate expectations have a role to play at the second step of the juristic reason analysis, where the defendant bears the burden of establishing that there is a juristic reason for retaining the benefit that does not fall within the existing categories. The question is whether the parties' mutual expectations show that retention of the benefits is just.

In the *Vanasse* appeal, although not labelling it as such, the trial judge found that there was a joint family venture and that there was a link between V's contribution to it and the substantial accumulation of wealth that the family achieved. She made a reasonable assessment of the monetary award appropriate to reverse this unjust enrichment, taking due account of S's substantial contributions. Her findings of fact and analysis indicate that the unjust enrichment of S at the expense of V ought to be characterized as the retention by S of a disproportionate share of the wealth generated from a joint family venture. Several factors suggested that, throughout their relationship, the parties were working collaboratively towards common goals. They made important decisions keeping the overall welfare of the family at the forefront. It was through their joint efforts that they were able to raise a young family and acquire wealth. S could not have made the efforts he did to build up the company but for V's assumption of the domestic responsibilities. Notably, the period of unjust enrichment corresponds to the time during which the parties had two children together, a further indicator

l'enrichissement. Cependant, comme l'analyse du motif juridique vise à déterminer si l'enrichissement était équitable et non à en mesurer l'ampleur, les avantages réciproques ne devraient être pris en considération à cette étape que pour cette fin précise. Autrement, il faut tenir compte des avantages réciproques seulement une fois remplies les trois conditions de l'action pour enrichissement injustifié.

Les demandeurs doivent démontrer qu'aucun motif juridique ne se retrouve dans l'une ou l'autre des catégories établies, par exemple si l'avantage était un don ou s'il découlait d'une obligation légale. Si cette preuve est faite, le défendeur peut alors démontrer qu'un motif juridique différent justifiant l'enrichissement devrait être reconnu, compte tenu des attentes raisonnables des parties et des considérations d'intérêt public. Les avantages réciproques et les attentes raisonnables des parties ont un rôle très limité à jouer dans la première étape de l'analyse du motif juridique. Dans certains cas, le fait que des avantages réciproques aient été conférés ou le fait que les avantages aient été fournis conformément aux attentes raisonnables des parties peut constituer une preuve pertinente pour déterminer si l'une des catégories établies de motifs juridiques s'applique. Les attentes raisonnables ou légitimes des parties jouent un rôle à la deuxième étape de l'analyse du motif juridique, où il incombe au défendeur d'établir qu'il existe un motif juridique de conserver l'avantage n'appartenant pas aux catégories établies. La question est de savoir si les attentes des parties prouvent qu'il est équitable de conserver les avantages.

Dans *Vanasse*, la juge de première instance a conclu qu'il y avait une coentreprise familiale, bien qu'elle ne l'ait pas qualifiée ainsi, et qu'il existait un lien entre la contribution de V à la coentreprise et l'accumulation importante de la richesse familiale. Elle a raisonnablement évalué l'indemnité pécuniaire appropriée pour permettre l'annulation de cet enrichissement injustifié, en tenant dûment compte des contributions importantes de S. Selon ses conclusions de fait et son analyse, l'enrichissement injustifié de S au détriment de V tient à la conservation, par S, d'une part disproportionnée de la richesse générée par une coentreprise familiale. Plusieurs facteurs donnaient à penser que, pendant toute la durée de leur relation, les parties collaboraient en vue d'atteindre des buts communs. Elles ont pris des décisions importantes en gardant le bien-être de la famille au premier plan. Les parties ont été en mesure d'élever une famille et d'acquérir une richesse grâce à leurs efforts communs. S n'aurait pas pu faire tous les efforts qu'il a faits pour développer l'entreprise si V n'avait pas assumé les responsabilités familiales. Il convient de souligner que la période d'enrichissement

that they were working together to achieve common goals. The length of the relationship is also relevant, and their 12-year cohabitation is a significant period of time. There was also evidence of economic integration as their house was registered jointly and they had a joint bank account. Their words and actions indicated that there was a joint family venture, to which the couple jointly contributed for their mutual benefit and the benefit of their children. There is a strong inference from the factual findings that, to S's knowledge, V relied on the relationship to her detriment. She left her career, gave up her own income, and moved away from her family and friends. V then stayed home and cared for their two small children. During the period of the unjust enrichment, V was responsible for a disproportionate share of the domestic labour. There was a clear link between V's contribution and the accumulation of wealth. The trial judge took a realistic and practical view of the evidence and took into account S's non-financial contributions and periods during which V's contributions were not disproportionate to S and her judgment should be restored.

The Court of Appeal was right to set aside the trial judge's findings of resulting trust and unjust enrichment in *Kerr* and in ordering a new hearing on B's counterclaim. On the basis of the unsatisfactory record at trial, which includes findings of fact tainted by clear error, K's unjust enrichment claim should not have been dismissed but a new trial ordered. The Court of Appeal erred in assessing B's contributions as part of the juristic reason analysis and prematurely truncated K's *prima facie* case of unjust enrichment. The family property approach is rejected, and for K to show an entitlement to a proportionate share of the wealth accumulated during the relationship, she must establish that B has been unjustly enriched at her expense, that their relationship constituted a joint family venture, and that her contributions are linked to the generation of wealth during the relationship. She would then have to show what proportion of the jointly accumulated wealth reflects her contributions. With regard to B's counterclaim, there was evidence that he made very significant contributions to K's welfare such that his counterclaim cannot simply be dismissed. The trial judge also referred to various other monetary and non-monetary contributions which K made to the couple's welfare and comfort, but he did not evaluate them, let alone compare them with the

injustifié correspond à la période pendant laquelle les parties ont eu leurs deux enfants, un autre indice qu'elles travaillaient ensemble en vue de réaliser des objectifs communs. La durée de la relation est aussi pertinente, et 12 ans de cohabitation se veut une période assez longue. Certains éléments de preuve indiquaient également qu'il y avait intégration économique car la résidence familiale était enregistrée aux deux noms et les parties avaient un compte chèque conjoint. Leurs paroles et leurs actes indiquaient qu'il existait une coentreprise familiale à laquelle le couple a contribué conjointement pour leur bénéfice et le bénéfice de leurs enfants. Il y a de fortes raisons d'inférer des conclusions de fait que, à la connaissance de S, V s'est fiée sur la relation à son détriment. Elle a renoncé à sa carrière et à son salaire et déménagé loin de sa famille et de ses amis. V est donc restée à la maison et s'est occupée de leurs deux jeunes enfants. Pendant la période d'enrichissement injustifié, V assumait une part disproportionnée des travaux domestiques. Il y avait un lien clair entre la contribution de V et l'accumulation de la richesse. La juge de première instance s'est prononcée de manière réaliste et pratique quant à la preuve et elle a pris en considération les importantes contributions non financières de S et les périodes pendant lesquelles les contributions de V n'étaient pas disproportionnées par rapport à celles de S, et sa décision devrait être rétablie.

Dans *Kerr*, la Cour d'appel a eu raison d'écarter les conclusions de première instance en ce qui concerne la fiducie résultoire et l'enrichissement injustifié et d'ordonner une nouvelle audition de la demande reconventionnelle de B. Compte tenu du dossier insatisfaisant en première instance, qui comprend des conclusions de fait clairement erronées, la demande de K fondée sur l'enrichissement injustifié n'aurait pas dû être rejetée mais la tenue d'un nouveau procès aurait dû être ordonnée. La Cour d'appel a commis une erreur en évaluant les contributions de B dans le cadre de l'analyse du motif juridique et a prématurément tronqué la preuve *prima facie* d'enrichissement injustifié de K. La méthode fondée sur l'avoir familial est rejetée, et pour démontrer qu'elle a droit à une part proportionnelle de la richesse accumulée pendant la relation, K doit établir que B s'est injustement enrichi à ses dépens, que leur relation constituait une coentreprise familiale et que ses contributions sont liées à l'accumulation de la richesse pendant la relation. Elle devrait ensuite démontrer quelle proportion de la richesse accumulée conjointement correspond à ses contributions. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de B, certains éléments de preuve indiquaient que B a contribué de façon importante au bien-être de K de sorte que sa

contributions made by B. There are few findings of fact relevant to the key question of whether the parties' relationship constituted a joint family venture. Further, the Court of Appeal ought not to have set aside the trial judge's order for spousal support in favour of K effective on the date she had commenced proceedings. It is clear that K was in need of support from B at the date she started her proceedings and remained so at the time of trial. K should not have been faulted for not bringing an interim application in seeking support for the period in question. She suffered from a serious physical disability, and her standard of living was markedly lower than it was while she lived with B. B had the means to provide support, had prompt notice of her claim, and there was no indication in the Court of Appeal's reasons that it considered the judge's award imposed on him a hardship so as to make that award inappropriate.

Cases Cited

Applied: *Peel (Regional Municipality) v. Canada*, [1992] 3 S.C.R. 762; *Peter v. Beblow*, [1993] 1 S.C.R. 980, rev'g (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266, rev'g [1988] B.C.J. No. 887 (QL); *Sorochan v. Sorochan*, [1986] 2 S.C.R. 38; *Garland c. Consumers' Gas Co.*, 2004 SCC 25, [2004] 1 S.C.R. 629; **considered:** *Pettikus v. Becker*, [1980] 2 S.C.R. 834; *Rathwell v. Rathwell*, [1978] 2 S.C.R. 436; *Pecore v. Pecore*, 2007 SCC 17, [2007] 1 S.C.R. 795; *D.B.S. v. S.R.G.*, 2006 SCC 37, [2006] 2 S.C.R. 231; **referred to:** *Dyer v. Dyer* (1788), 2 Cox Eq. Cas. 92, 30 E.R. 42; *Murdoch v. Murdoch*, [1975] 1 S.C.R. 423; *Gissing v. Gissing*, [1970] 2 All E.R. 780; *Pettitt v. Pettitt*, [1970] A.C. 777; *Reference re Goods and Services Tax*, [1992] 2 S.C.R. 445; *Mack v. Canada (Attorney General)* (2002), 60 O.R. (3d) 737; *Nova Scotia (Attorney General) v. Walsh*, 2002 SCC 83, [2002] 4 S.C.R. 325; *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574; *Bell v. Bailey* (2001), 203 D.L.R. (4th) 589; *Wilson v. Fotsch*, 2010 BCCA 226, 319 D.L.R. (4th) 26; *Pickelein v. Gillmore* (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 44; *Harrison v. Kalinocha* (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 273; *MacFarlane v. Smith*, 2003 NBCA 6, 256 N.B.R. (2d) 108; *Shannon v. Gidden*, 1999 BCCA 539, 71 B.C.L.R. (3d) 40; *Herman v. Smith* (1984), 42 R.F.L. (2d) 154; *Clarke v. Clarke*, [1990] 2 S.C.R. 795; *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI*

demande reconventionnelle ne peut simplement pas être rejetée. Le juge de première instance a aussi mentionné diverses autres contributions financières et non financières apportées par K au bien-être et au confort du couple, mais il ne les a pas évaluées et les a encore moins comparées à celles de B. Peu de conclusions de fait sont pertinentes en ce qui concerne la question clé de savoir si la relation des parties constituait une coentreprise familiale. De plus, la Cour d'appel n'aurait pas dû annuler l'ordonnance du juge de première instance accordant à K une pension alimentaire rétroactive à la date d'introduction de l'action. Il est clair que K avait besoin que B lui verse une pension alimentaire à la date où elle a introduit les procédures et qu'elle en avait toujours besoin lors du procès. On a eu tort de reprocher à K de ne pas avoir présenté une demande provisoire dans sa demande de pension alimentaire pour la période en question. Elle souffrait d'une grave invalidité physique et son niveau de vie était nettement inférieur à celui qu'elle avait quand elle habitait avec B. B avait les moyens de lui verser une pension, il avait reçu sans délai un avis de sa réclamation, et rien dans les motifs de la Cour d'appel n'indiquait qu'elle considérait que la pension alimentaire imposée par le juge mettait B dans une situation financière difficile, de sorte que l'ordonnance était inappropriée.

Jurisprudence

Arrêts appliqués : *Peel (Municipalité régionale) c. Canada*, [1992] 3 R.C.S. 762; *Peter c. Beblow*, [1993] 1 R.C.S. 980, inf. (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266, inf. [1988] B.C.J. No. 887 (QL); *Sorochan c. Sorochan*, [1986] 2 R.C.S. 38; *Garland c. Consumers' Gas Co.*, 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629; **arrêts examinés :** *Pettikus c. Becker*, [1980] 2 R.C.S. 834; *Rathwell c. Rathwell*, [1978] 2 R.C.S. 436; *Pecore c. Pecore*, 2007 CSC 17, [2007] 1 R.C.S. 795; *D.B.S. c. S.R.G.*, 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231; **arrêts mentionnés :** *Dyer c. Dyer* (1788), 2 Cox Eq. Cas. 92, 30 E.R. 42; *Murdoch c. Murdoch*, [1975] 1 R.C.S. 423; *Gissing c. Gissing*, [1970] 2 All E.R. 780; *Pettitt c. Pettitt*, [1970] A.C. 777; *Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services*, [1992] 2 R.C.S. 445; *Mack c. Canada (Procureur général)* (2002), 60 O.R. (3d) 756; *Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh*, 2002 CSC 83, [2002] 4 R.C.S. 325; *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574; *Bell c. Bailey* (2001), 203 D.L.R. (4th) 589; *Wilson c. Fotsch*, 2010 BCCA 226, 319 D.L.R. (4th) 26; *Pickelein c. Gillmore* (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 44; *Harrison c. Kalinocha* (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 273; *MacFarlane c. Smith*, 2003 NBCA 6, 256 R.N.-B. (2^e) 108; *Shannon c. Gidden*, 1999 BCCA 539, 71 B.C.L.R. (3d) 40; *Herman c. Smith* (1984), 42 R.F.L. (2d) 154; *Clarke c. Clarke*, [1990] 2 R.C.S. 795; *Cadbury*

Foods Ltd., [1999] 1 S.C.R. 142; *Soulos v. Korkontzilas*, [1997] 2 S.C.R. 217; *Pacific National Investments Ltd. v. Victoria (City)*, 2004 SCC 75, [2004] 3 S.C.R. 575; *Birmingham v. Ferguson*, 2004 CanLII 4764; *McDougall v. Gesell Estate*, 2001 MBCA 3, 153 Man. R. (2d) 54; *Nasser v. Mayer-Nasser* (2000), 5 R.F.L. (5th) 100; *Panara v. Di Ascenzo*, 2005 ABCA 47, 361 A.R. 382; *Ford v. Werden* (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 169; *Thomas v. Fenton*, 2006 BCCA 299, 269 D.L.R. (4th) 376; *Giles v. McEwan* (1896), 11 Man. R. 150; *Garland v. Consumers' Gas Co.*, [1998] 3 S.C.R. 112; *Nance v. British Columbia Electric Railway Co.*, [1951] A.C. 601; *MacKinnon v. MacKinnon* (2005), 75 O.R. (3d) 175; *S. (L.) v. P. (E.)* (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254.

Statutes and Regulations Cited

Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp.).

Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128, ss. 1(1) “spouse”, 93(5)(d).

Authors Cited

Birks, Peter. *An Introduction to the Law of Restitution*. Oxford: Clarendon Press, 1985.

Birks, Peter. *Unjust Enrichment*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Davies, J. D. “Duties of Confidence and Loyalty”, [1990] *L.M.C.L.Q.* 4.

Fridman, G. H. L. *Restitution*, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992.

Gordon, Marie L. “Blame Over: Retroactive Child and Spousal Support in the Post-Guideline Era” (2004-2005), 23 *C.F.L.Q.* 243.

Lord Goff of Chieveley and Gareth Jones. *The Law of Restitution*, 7th ed. London: Sweet & Maxwell, 2007.

Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. *The Law of Restitution*. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1990.

Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. *The Law of Restitution*. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2004 (loose-leaf updated August 2010, release 6).

Matrimonial Property Law in Canada, vol. 1, by James G. McLeod and Alfred A. Mamo, eds. Toronto: Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2010, release 8).

McCamus, John D. “Restitution on Dissolution of Marital and Other Intimate Relationships: Constructive Trust or Quantum Meruit?”, in Jason W. Neyers, Mitchell McInnes and Stephen G. A. Pitel, eds., *Understanding Unjust Enrichment*. Portland: Hart Publishing, 2004, 359.

Mee, John. *The Property Rights of Cohabitees: An Analysis of Equity's Response in Five Common Law Jurisdictions*. Portland: Hart Publishing, 1999.

Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142; *Soulos c. Korkontzilas*, [1997] 2 R.C.S. 217; *Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville)*, 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575; *Birmingham c. Ferguson*, 2004 CanLII 4764; *McDougall c. Gesell Estate*, 2001 MBCA 3, 153 Man. R. (2d) 54; *Nasser c. Mayer-Nasser* (2000), 5 R.F.L. (5th) 100; *Panara c. Di Ascenzo*, 2005 ABCA 47, 361 A.R. 382; *Ford c. Werden* (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 169; *Thomas c. Fenton*, 2006 BCCA 299, 269 D.L.R. (4th) 376; *Giles c. McEwan* (1896), 11 Man. R. 150; *Garland c. Consumers' Gas Co.*, [1998] 3 R.C.S. 112; *Nance c. British Columbia Electric Railway Co.*, [1951] A.C. 601; *MacKinnon c. MacKinnon* (2005), 75 O.R. (3d) 175; *S. (L.) c. P. (E.)* (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254.

Lois et règlements cités

Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 1(1) « spouse », 93(5)d).

Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2^e suppl.).

Doctrine citée

Birks, Peter. *An Introduction to the Law of Restitution*. Oxford : Clarendon Press, 1985.

Birks, Peter. *Unjust Enrichment*, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2005.

Davies, J. D. « Duties of Confidence and Loyalty », [1990] *L.M.C.L.Q.* 4.

Fridman, G. H. L. *Restitution*, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1992.

Gordon, Marie L. « Blame Over : Retroactive Child and Spousal Support in the Post-Guideline Era » (2004-2005), 23 *C.F.L.Q.* 243.

Lord Goff of Chieveley and Gareth Jones. *The Law of Restitution*, 7th ed. London : Sweet & Maxwell, 2007.

Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. *The Law of Restitution*. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1990.

Maddaugh, Peter D., and John D. McCamus. *The Law of Restitution*. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2004 (loose-leaf updated August 2010, release 6).

Matrimonial Property Law in Canada, vol. 1, by James G. McLeod and Alfred A. Mamo, eds. Toronto : Carswell, 1993 (loose-leaf updated 2010, release 8).

McCamus, John D. « Restitution on Dissolution of Marital and Other Intimate Relationships : Constructive Trust or Quantum Meruit? », in Jason W. Neyers, Mitchell McInnes and Stephen G. A. Pitel, eds., *Understanding Unjust Enrichment*. Portland : Hart Publishing, 2004, 359.

Mee, John. *The Property Rights of Cohabitees : An Analysis of Equity's Response in Five Common Law Jurisdictions*. Portland : Hart Publishing, 1999.

Oosterhoff on Trusts: Text, Commentary and Materials, 7th ed. by A. H. Oosterhoff et al. Toronto: Carswell, 2009.

Parkinson, Patrick. “Beyond *Pettkus v. Becker*: Quantifying Relief for Unjust Enrichment” (1993), 43 *U.T.L.J.* 217.

Pettit, Philip H. *Equity and the Law of Trusts*, 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Scane, Ralph E. “Relationships ‘Tantamount to Spousal’, Unjust Enrichment, and Constructive Trusts” (1991), 70 *Can. Bar Rev.* 260.

Waters, Donovan. Comment (1975), 53 *Can. Bar Rev.* 366.

Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Toronto: Thomson, 2005.

Youdan, Timothy G. “Resulting and Constructive Trusts”, in *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1993 — Family Law: Roles, Fairness and Equality*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994, 169.

APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (Levine, Tysoc and Smith J.J.A.), 2009 BCCA 111, 93 B.C.L.R. (4th) 201, 266 B.C.A.C. 298, [2009] 9 W.W.R. 285, 66 R.F.L. (6th) 1, [2009] B.C.J. No. 474 (QL), 2009 CarswellBC 642, reversing in part a decision of Romilly J., 2007 BCSC 1863, 47 R.F.L. (6th) 103, [2007] B.C.J. No. 2737 (QL), 2007 CarswellBC 3047. Appeal allowed in part.

APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (Weiler, Jursanz and Epstein J.J.A.), 2009 ONCA 595, 252 O.A.C. 218, 96 O.R. (3d) 321, [2009] O.J. No. 3211 (QL), 2009 CarswellOnt 4407, reversing a decision of Blishen J., 2008 CanLII 35922, [2008] O.J. No. 2832 (QL), 2008 CarswellOnt 4265. Appeal allowed.

Armand A. Petronio and Geoffrey B. Gomery, for the appellant Margaret Kerr.

Susan G. Label and Marie-France Major, for the respondent Nelson Baranow.

John E. Johnson, for the appellant Michele Vanasse.

H. Hunter Phillips, for the respondent David Seguin.

Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials, 7th ed. by A. H. Oosterhoff et al. Toronto : Carswell, 2009.

Parkinson, Patrick. « Beyond *Pettkus v. Becker* : Quantifying Relief for Unjust Enrichment » (1993), 43 *U.T.L.J.* 217.

Pettit, Philip H. *Equity and the Law of Trusts*, 11th ed. Oxford : Oxford University Press, 2009.

Scane, Ralph E. « Relationships “Tantamount to Spousal”, Unjust Enrichment, and Constructive Trusts » (1991), 70 *R. du B. can.* 260.

Waters, Donovan. Comment (1975), 53 *R. du B. can.* 366. *Waters’ Law of Trusts in Canada*, 3rd ed. by Donovan W. M. Waters, Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Toronto : Thomson, 2005.

Youdan, Timothy G. « Resulting and Constructive Trusts », in *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1993 — Family Law : Roles, Fairness and Equality*. Scarborough, Ont. : Carswell, 1994, 169.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Levine, Tysoc et Smith), 2009 BCCA 111, 93 B.C.L.R. (4th) 201, 266 B.C.A.C. 298, [2009] 9 W.W.R. 285, 66 R.F.L. (6th) 1, [2009] B.C.J. No. 474 (QL), 2009 CarswellBC 642, qui a infirmé en partie une décision du juge Romilly, 2007 BCSC 1863, 47 R.F.L. (6th) 103, [2007] B.C.J. No. 2737 (QL), 2007 CarswellBC 3047. Pourvoi accueilli en partie.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Jursanz et Epstein), 2009 ONCA 595, 252 O.A.C. 218, 96 O.R. (3d) 321, [2009] O.J. No. 3211 (QL), 2009 CarswellOnt 4407, qui a infirmé une décision de la juge Blishen, 2008 CanLII 35922, [2008] O.J. No. 2832 (QL), 2008 CarswellOnt 4265. Pourvoi accueilli.

Armand A. Petronio et Geoffrey B. Gomery, pour l’appelante Margaret Kerr.

Susan G. Label et Marie-France Major, pour l’intimé Nelson Baranow.

John E. Johnson, pour l’appelante Michele Vanasse.

H. Hunter Phillips, pour l’intimé David Seguin.

The judgment of the Court was delivered by

Version française du jugement de la Cour rendu
par

CROMWELL J. —

LE JUGE CROMWELL —

I. Introduction

[1] In a series of cases spanning 30 years, the Court has wrestled with the financial and property rights of parties on the breakdown of a marriage or domestic relationship. Now, for married spouses, comprehensive matrimonial property statutes enacted in the late 1970s and 1980s provide the applicable legal framework. But for unmarried persons in domestic relationships in most common law provinces, judge-made law was and remains the only option. The main legal mechanisms available to parties and courts have been the resulting trust and the action in unjust enrichment.

[2] In the early cases of the 1970s, the parties and the courts turned to the resulting trust. The underlying legal principle was that contributions to the acquisition of a property, which were not reflected in the legal title, could nonetheless give rise to a property interest. Added to this underlying notion was the idea that a resulting trust could arise based on the “common intention” of the parties that the non-owner partner was intended to have an interest. The resulting trust soon proved to be an unsatisfactory legal solution for many domestic property disputes, but claims continue to be advanced and decided on that basis.

[3] As the doctrinal problems and practical limitations of the resulting trust became clearer, parties and courts turned increasingly to the emerging law of unjust enrichment. As the law developed, unjust enrichment carried with it the possibility of a remedial constructive trust. In order to successfully prove a claim for unjust enrichment, the claimant must show that the defendant has been enriched, the claimant suffered a corresponding detriment, and there is no “juristic reason” for the enrichment.

I. Introduction

[1] Dans une série de décisions rendues dans les 30 dernières années, la Cour s’est heurtée aux questions de droits financiers et de droits des biens des parties à la rupture du mariage ou de la relation conjugale. Aujourd’hui, des lois exhaustives en matière de régimes matrimoniaux adoptées à la fin des années 1970 et dans les années 1980 prévoient le cadre juridique applicable aux époux. Cependant, en ce qui concerne les conjoints non mariés dans la plupart des provinces de common law, le recours au droit jurisprudentiel était et demeure la seule solution. Les principaux mécanismes juridiques auxquels les parties et les tribunaux peuvent avoir recours sont la fiducie résultoire et l’action en enrichissement injustifié.

[2] Dans les premières décisions rendues dans les années 1970, les parties et les tribunaux se sont tournés vers la fiducie résultoire. Selon le principe juridique sous-jacent, les contributions à l’acquisition de biens, qui n’étaient pas indiquées dans le titre de propriété, pouvaient néanmoins créer un droit de propriété. À ce principe s’ajoutait l’idée qu’une fiducie résultoire pouvait découler d’une « intention commune » des parties d’accorder un droit au partenaire non propriétaire. La fiducie résultoire s’est vite avérée une solution juridique insatisfaisante dans de nombreux litiges se rapportant aux biens conjugaux, mais des recours sont encore intentés et tranchés sur ce fondement.

[3] À mesure que les problèmes théoriques et les limitations pratiques de la fiducie résultoire se sont précisés, les parties et les tribunaux se sont de plus en plus tournés vers le droit naissant de l’enrichissement injustifié. Au fil de son évolution, l’enrichissement injustifié a conduit à la possibilité d’une fiducie constructive de nature réparatoire. Pour réussir à établir le bien-fondé d’une action en enrichissement injustifié, le demandeur doit démontrer l’enrichissement du défendeur, son

This claim has become the pre-eminent vehicle for addressing the financial consequences of the breakdown of domestic relationships. However, various issues continue to create controversy, and these two appeals, argued consecutively, provide the Court with the opportunity to address them.

[4] In the *Kerr* appeal, a couple in their late 60s separated after a common law relationship of more than 25 years. Both had worked through much of that time and each had contributed in various ways to their mutual welfare. Ms. Kerr claimed support and a share of property held in her partner's name based on resulting trust and unjust enrichment principles. The trial judge awarded her one-third of the value of the couple's residence, grounded in both resulting trust and unjust enrichment claims (2007 BCSC 1863, 47 R.F.L. (6th) 103). He did not address, other than in passing, Mr. Baranow's counterclaim that Ms. Kerr had been unjustly enriched at his expense. The judge also ordered substantial monthly support for Ms. Kerr pursuant to statute, effective as of the date she applied to the court for relief. However, the resulting trust and unjust enrichment conclusions of the trial judge were set aside by the British Columbia Court of Appeal (2009 BCCA 111, 93 B.C.L.R. (4th) 201). Both lower courts addressed the role of the parties' common intention and reasonable expectations. The appeal to this Court raises the questions of the role of resulting trust law in these types of disputes, as well as how an unjust enrichment analysis should take account of the mutual conferral of benefits and what role the parties' intentions and expectations play in that analysis. This Court is also called upon to decide whether the award of spousal support should be effective as of the date of application, as found by the trial judge, the date the trial began, as ordered by the Court of Appeal, or some other date.

propre appauvrissement correspondant et l'absence de « motif juridique » de l'enrichissement. Ce recours est devenu le moyen prééminent pour traiter des conséquences financières de la rupture des relations conjugales. Cependant, diverses questions continuent de susciter la controverse, et ces deux pourvois entendus consécutivement donnent à la Cour l'occasion d'y répondre.

[4] Dans le pourvoi *Kerr*, un couple dans la soixantaine avancée s'est séparé après plus de 25 ans de vie commune. Tous deux avaient travaillé pendant presque toutes ces années et avaient chacun contribué de diverses façons à leur bien-être commun. Sur le fondement de la fiducie résultoire et de l'enrichissement injustifié, M^{me} Kerr a réclamé une pension alimentaire et une part des biens détenus au nom de son conjoint. Le juge de première instance lui a accordé un tiers de la valeur de la résidence du couple au titre de la fiducie résultoire et de l'enrichissement injustifié (2007 BCSC 1863, 47 R.F.L. (6th) 103). Il n'a pas traité, sauf dans une remarque incidente, de la demande reconventionnelle de M. Baranow suivant laquelle M^{me} Kerr se serait injustement enrichie à ses dépens. Le juge a aussi ordonné le paiement d'une pension alimentaire mensuelle élevée à M^{me} Kerr en vertu de la loi, et ce, à compter de la date à laquelle la demande de réparation a été présentée à la cour. Toutefois, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a écarté les conclusions du juge de première instance se rapportant à la fiducie résultoire et à l'enrichissement injustifié (2009 BCCA 111, 93 B.C.L.R. (4th) 201). Les deux tribunaux d'instance inférieure ont examiné le rôle que peuvent jouer l'intention commune et les attentes raisonnables des parties. Le présent pourvoi soulève des questions relatives au rôle du droit des fiducies résultoires dans les litiges de ce genre, ainsi que celle de la mesure dans laquelle l'analyse de l'enrichissement injustifié devrait prendre en compte les avantages réciproques et de l'importance à accorder aux intentions et attentes des parties dans cette analyse. Notre Cour est également appelée à décider si l'ordonnance alimentaire en faveur d'un conjoint devrait prendre effet à la date de la demande, comme l'a conclu le juge de première instance, à la date du procès, comme l'a ordonné la Cour d'appel, ou à une autre date.

[5] In the *Vanasse* appeal, the central problem is how to quantify a monetary award for unjust enrichment. It is agreed that Mr. Seguin was unjustly enriched by the contributions of his partner, Ms. Vanasse; the two lived in a common law relationship for about 12 years and had two children together during this time. The trial judge valued the extent of the enrichment by determining what proportion of Mr. Seguin's increased wealth was due to Ms. Vanasse's efforts as an equal contributor to the family venture (2008 CanLII 35922). The Court of Appeal set aside this finding and, while ordering a new trial, directed that the proper approach to valuation was to place a monetary value on the services provided by Ms. Vanasse to the family, taking due account of Mr. Seguin's own contributions by way of set-off (2009 ONCA 595, 252 O.A.C. 218). In short, the Court of Appeal held that Ms. Vanasse should be treated as an unpaid employee, not a co-venturer. The appeal to this Court challenges this conclusion.

[6] These appeals require us to resolve five main issues. The first concerns the role of the "common intention" resulting trust in claims by domestic partners. In my view, it is time to recognize that the "common intention" approach to resulting trust has no further role to play in the resolution of property claims by domestic partners on the breakdown of their relationship.

[7] The second issue concerns the nature of the money remedy for a successful unjust enrichment claim. Some courts take the view that if the claimant's contribution cannot be linked to specific property, a money remedy must always be assessed on a fee-for-services basis. Other courts have taken a more flexible approach. In my view, where both parties have worked together for the common good, with each making extensive, but different, contributions to the welfare of the other and, as a result,

[5] Dans le pourvoi *Vanasse*, le problème fondamental est de savoir comment déterminer l'indemnité à accorder pour enrichissement injustifié. Il est admis que M. Seguin s'est injustement enrichi grâce aux contributions de sa conjointe, M^{me} Vanasse; ils ont vécu en union de fait pendant environ 12 ans et ils ont eu deux enfants pendant cette période. La juge de première instance a établi la valeur de l'enrichissement en déterminant la proportion de l'avoir de M. Seguin qui était attribuable aux efforts de M^{me} Vanasse, qui avait contribué de manière aussi importante à l'entreprise familiale (2008 CanLII 35922). La Cour d'appel a écarté cette conclusion et, bien qu'elle ait ordonné la tenue d'un nouveau procès, elle a indiqué que la méthode appropriée pour déterminer la valeur de l'enrichissement injustifié consistait à attribuer une valeur pécuniaire aux services fournis à la famille par M^{me} Vanasse, en prenant en considération les contributions de M. Seguin en compensation (2009 ONCA 595, 252 O.A.C. 218). En résumé, la Cour d'appel a conclu que M^{me} Vanasse devait être considérée comme une employée non rémunérée, et non comme une co-entrepreneure. Dans le présent pourvoi, on conteste cette conclusion.

[6] Les présents pourvois nous obligent à répondre à cinq questions principales. La première porte sur le rôle de la fiducie résultoire fondée sur l'intention commune dans les réclamations présentées par les partenaires vivant en union libre. À mon avis, il est temps de reconnaître que, dans l'examen de la fiducie résultoire, il ne faut plus accorder un rôle à l'« intention commune » lorsqu'il s'agit de trancher les réclamations fondées sur un droit de propriété présentées par des partenaires vivant en union libre au moment de la rupture de leur relation.

[7] La deuxième question porte sur la nature de l'indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié. Selon certains tribunaux, s'il est impossible d'établir un lien entre la contribution d'un demandeur et un bien précis, une réparation pécuniaire doit toujours être évaluée en fonction de la valeur des services rendus. D'autres tribunaux ont adopté une approche plus souple. À mon avis, si les deux parties ont travaillé ensemble dans un intérêt commun et ont fait des contributions importantes,

have accumulated assets, the money remedy for unjust enrichment should reflect that reality. The money remedy in those circumstances should not be based on a minute totting up of the give and take of daily domestic life, but rather should treat the claimant as a co-venturer, not as the hired help.

[8] The third area requiring clarification relates to mutual benefit conferral. Many domestic relationships involve the mutual conferral of benefits, in the sense that each contributes in various ways to the welfare of the other. The question is how and at what point in the unjust enrichment analysis should this mutual conferral of benefits be taken into account? For reasons I will develop below, this issue should, with a small exception, be addressed at the defence and remedy stage.

[9] Fourth, there is the question of what role the parties' reasonable or legitimate expectations play in the unjust enrichment analysis. My view is that they have a limited role, and must be considered in relation to whether there is a juristic reason for the enrichment.

[10] Finally, there is the issue of the appropriate date for the commencement of spousal support. In my respectful view, the Court of Appeal erred in setting aside the trial judge's selection of the date of application in the circumstances of the *Kerr* appeal.

[11] I will first address the law of resulting trusts as it applies to the breakdown of a marriage-like relationship. Next, I will turn to the law of unjust enrichment in this context. Finally, I will address the specific issues raised in the two appeals.

II. Resulting Trusts

[12] The resulting trust played an important role in the early years of the Court's jurisprudence relating to property rights following the breakdown of

mais différentes, au bien-être de l'autre et, de ce fait, elles ont accumulé des biens, la réparation pécuniaire pour enrichissement injustifié devrait refléter cette réalité. Dans ces circonstances, la réparation ne devrait pas être fondée sur un calcul détaillé des contributions et des concessions de la vie quotidienne; le demandeur devrait être traité comme un co-entrepreneur plutôt qu'un employé.

[8] La troisième question qui mérite clarification se rapporte aux avantages réciproques. Plusieurs relations conjugales supposent des avantages réciproques, dans le sens que chacune des parties contribue de diverses façons au bien-être de l'autre. La question est de savoir comment et à quel moment de l'analyse de l'enrichissement injustifié ces avantages réciproques devraient être pris en considération. Pour des raisons que je vais exposer plus loin, cette question devrait, à une exception près, être traitée à l'étape de la défense et de la réparation.

[9] La quatrième question concerne le rôle que jouent les attentes raisonnables ou légitimes des parties dans l'analyse de l'enrichissement injustifié. Je suis d'avis qu'elles ont un rôle limité et qu'elles doivent être examinées par rapport à la question de savoir s'il y a un motif juridique de l'enrichissement.

[10] Enfin, il reste la question de la date de prise d'effet de la pension alimentaire. À mon avis, dans l'affaire *Kerr*, la Cour d'appel a commis une erreur en annulant la décision du juge de première instance quant à la date de prise d'effet de la pension dans les circonstances.

[11] Je vais d'abord traiter du droit des fiducies résultoires tel qu'il s'applique à la rupture d'une relation de nature conjugale. Ensuite, j'examinerai le droit relatif à l'enrichissement injustifié dans ce contexte. Enfin, je vais aborder les questions particulières soulevées dans les deux pourvois.

II. Fiducies résultoires

[12] La fiducie résultoire a joué un rôle important dans les premières décisions de la Cour se rapportant aux droits de propriété à la suite de la rupture

intimate personal relationships. This is not surprising; it had been settled law since at least 1788 in England (and likely long before) that the trust of a legal estate, whether in the names of the purchaser or others, “results” to the person who advances the purchase money: *Dyer v. Dyer* (1788), 2 Cox Eq. Cas. 92, 30 E.R. 42, at p. 43. The resulting trust, therefore, seemed a promising vehicle to address claims that one party’s contribution to the acquisition of property was not reflected in the legal title.

[13] The resulting trust jurisprudence in domestic property cases developed into what has been called “a purely Canadian invention”, the “common intention” resulting trust: A. H. Oosterhoff, et al., *Oosterhoff on Trusts: Text, Commentary and Materials* (7th ed. 2009), at p. 642. While this vehicle has largely been eclipsed by the law of unjust enrichment since the decision of the Court in *Pettkus v. Becker*, [1980] 2 S.C.R. 834, claims based on the “common intention” resulting trust continue to be advanced. In the *Kerr* appeal, for example, the trial judge justified the imposition of a resulting trust, in part, on the basis that the parties had a common intention that Mr. Baranow would hold title to the property by way of a resulting trust for Ms. Kerr. The Court of Appeal, while reversing the trial judge’s finding of fact on this point, implicitly accepted the ongoing vitality of the common intention resulting trust.

[14] However promising this common intention resulting trust approach looked at the beginning, doctrinal and practical problems soon became apparent and have been the subject of comment by the Court and scholars: see, e.g., *Pettkus*, at pp. 842-43; Oosterhoff, at pp. 641-47; D. W. M. Waters, M. R. Gillen and L. D. Smith, eds., *Waters’ Law of Trusts in Canada* (3rd ed. 2005) (“*Waters*”), at pp. 430-35; J. Mee, *The Property Rights of Cohabitees: An Analysis of Equity’s Response in Five Common Law Jurisdictions* (1999), at pp. 39-43; T. G. Youdan, “Resulting and Constructive Trusts”, in *Special Lectures of the Law Society of Upper*

d’une relation personnelle. Cela n’est guère surprenant; il est bien établi en droit, depuis au moins 1788 en Angleterre (et probablement bien avant), qu’une fiducie à l’égard d’un domaine légal au nom de l’acheteur ou d’une autre personne est créée au bénéfice de la personne qui fournit le prix d’achat : *Dyer c. Dyer* (1788), 2 Cox Eq. Cas. 92, 30 E.R. 42, p. 43. Par conséquent, la fiducie résultoire semblait être un moyen prometteur de traiter la prétention selon laquelle la contribution d’une partie à l’acquisition d’un bien ne se reflétait pas dans le titre de propriété.

[13] La jurisprudence portant sur la fiducie résultoire en matière de biens familiaux a donné lieu à ce qu’on a appelé [TRADUCTION] « une invention purement canadienne », la fiducie résultoire fondée sur « l’intention commune » : A. H. Oosterhoff, et autres, *Oosterhoff on Trusts : Text, Commentary and Materials* (7^e éd. 2009), p. 642. Bien que ce recours ait été largement éclipsé par les règles de l’enrichissement injustifié depuis l’arrêt de notre Cour *Pettkus c. Becker*, [1980] 2 R.C.S. 834, des réclamations fondées sur l’« intention commune » de créer une fiducie résultoire continuent d’être présentées. Par exemple, dans l’affaire *Kerr*, le juge de première instance a justifié l’existence d’une fiducie résultoire, en partie, parce que les parties voulaient toutes les deux que M. Baranow détienne le titre de propriété au moyen d’une fiducie résultoire pour M^{me} Kerr. La Cour d’appel, tout en infirmant la conclusion de fait du juge de première instance sur ce point, a implicitement accepté la validité de la fiducie résultoire fondée sur l’intention commune.

[14] La fiducie résultoire fondée sur l’intention commune est apparue comme une méthode prometteuse au début, mais les problèmes théoriques et pratiques sont vite devenus évidents et ont suscité les commentaires de la Cour et des auteurs : voir, par exemple, *Pettkus*, p. 842-843; Oosterhoff, p. 641-647; D. W. M. Waters, M. R. Gillen et L. D. Smith, dir., *Waters’ Law of Trusts in Canada* (3^e éd. 2005) (« *Waters*’ »), p. 430-435; J. Mee, *The Property Rights of Cohabitees : An Analysis of Equity’s Response in Five Common Law Jurisdictions* (1999), p. 39-43; T. G. Youdan, « Resulting and Constructive Trusts », dans *Special*

Canada 1993 — Family Law: Roles, Fairness and Equality (1994), 169, at pp. 172-74.

[15] In this Court, since *Pettikus*, the common intention resulting trust remains intact but unused. While traditional resulting trust principles may well have a role to play in the resolution of property disputes between unmarried domestic partners, the time has come to acknowledge that there is no continuing role for the common intention resulting trust. To explain why, I must first put the question in the context of some basic principles about resulting trusts.

[16] That task is not as easy as it should be; there is not much one can say about resulting trusts without a well-grounded fear of contradiction. There is debate about how they should be classified and how they arise, let alone about many of the finer points: see, e.g., *Rathwell v. Rathwell*, [1978] 2 S.C.R. 436, at pp. 449-50; *Waters*, at pp. 19-22; P. H. Pettit, *Equity and the Law of Trusts* (11th ed. 2009), at p. 67. However, it is widely accepted that the underlying notion of the resulting trust is that it is imposed “to return property to the person who gave it and is entitled to it beneficially, from someone else who has title to it. Thus, the beneficial interest ‘results’ (jumps back) to the true owner”: Oosterhoff, at p. 25. There is also widespread agreement that, traditionally, resulting trusts arose where there had been a gratuitous transfer or where the purposes set out by an express or implied trust failed to exhaust the trust property: *Waters*, at p. 21.

[17] Resulting trusts arising from gratuitous transfers are the ones relevant to domestic situations. The traditional view was they arose in two types of situations: the gratuitous transfer of property from one partner to the other, and the joint contribution by two partners to the acquisition of property, title to which is in the name of only one of them. In either case, the transfer is gratuitous, in

Lectures of the Law Society of Upper Canada 1993 — Family Law : Roles, Fairness and Equality (1994), 169, p. 172-174.

[15] Devant notre Cour, depuis l’arrêt *Pettikus*, la fiducie résultoire fondée sur l’intention commune demeure intacte mais inutilisée. Il se pourrait bien que les principes traditionnels de la fiducie résultoire aient un rôle à jouer dans le règlement des litiges concernant les biens entre des partenaires non mariés, mais le moment est venu de reconnaître que la fiducie résultoire fondée sur l’intention commune a perdu sa raison d’être. Pour expliquer cette conclusion, je dois d’abord situer la question dans le contexte de certains principes de base se rapportant aux fiducies résultoires.

[16] Cette tâche n’est pas aussi simple qu’elle devrait l’être; dès que l’on aborde le sujet des fiducies résultoires, on risque la contradiction. Un débat entoure le mode de constitution et de classification de ce type de fiducie, sans compter de nombreuses autres subtilités : voir, par exemple, *Rathwell c. Rathwell*, [1978] 2 R.C.S. 436, p. 449-450; *Waters*, p. 19-22; P. H. Pettit, *Equity and the Law of Trusts* (11^e éd. 2009), p. 67. Toutefois, il est largement reconnu que la notion sous-jacente de la fiducie résultoire est qu’elle est imposée afin que [TRADUCTION] « la personne qui détient le titre sur le bien le retourne à la personne qui lui a donné et qui détient le droit à titre de bénéficiaire. Ainsi, l’intérêt bénéficiaire “revient” (retourne) au véritable propriétaire » : Oosterhoff, p. 25. De plus, on s’entend de manière générale pour dire que, traditionnellement, les fiducies résultoires prenaient naissance dans les cas où il y avait eu un transfert à titre gratuit ou quand les fins énoncées par une fiducie explicite ou implicite n’avaient pas permis d’épuiser les biens en fiducie : *Waters*, p. 21.

[17] Les fiducies résultoires découlant de transferts à titre gratuit sont celles qui sont pertinentes en matière familiale. Selon le point de vue traditionnel, elles découlaient de deux types de situations : le transfert à titre gratuit d’un bien d’un partenaire à l’autre, et la contribution des deux partenaires à l’acquisition d’un bien, dont le titre est au nom d’un seul des partenaires. Dans l’un ou l’autre

the first case because there was no consideration for the transfer of the property, and in the second case because there was no consideration for the contribution to the acquisition of the property.

[18] The Court's most recent decision in relation to resulting trusts is consistent with the view that, in these gratuitous transfer situations, the actual intention of the grantor is the governing consideration: *Pecore v. Pecore*, 2007 SCC 17, [2007] 1 S.C.R. 795, at paras. 43-44. As Rothstein J. noted at para. 44 of *Pecore*, where a gratuitous transfer is being challenged, "[t]he trial judge will commence his or her inquiry with the applicable presumption and will weigh all of the evidence in an attempt to ascertain, on a balance of probabilities, the transferor's actual intention" (emphasis added).

[19] As noted by Rothstein J. in this passage, presumptions may come into play when dealing with gratuitous transfers. The law generally presumes that the grantor intended to create a trust, rather than to make a gift, and so the presumption of resulting trust will often operate. As Rothstein J. explained, a presumption of a resulting trust is the general rule that applies to gratuitous transfers. When such a transfer is made, the onus will be on the person receiving the transfer to demonstrate that a gift was intended. Otherwise, the transferee holds that property in trust for the transferor. This presumption rests on the principle that equity presumes bargains and not gifts (*Pecore*, at para. 24).

[20] The presumption of resulting trust, however, is neither universal nor irrebuttable. So, for example, in the case of transfers between persons in certain relationships (such as from a parent to a minor child), a presumption of advancement — that is, a presumption that the grantor intended to make a gift — rather than a presumption of resulting trust applies: see *Pecore*, at paras. 27-41. The presumption of advancement traditionally applied to grants from husband to wife, but the presumption of resulting trust traditionally applied to

des cas, le transfert est à titre gratuit; dans le premier cas, parce que le transfert du bien s'effectue sans contrepartie, et dans le second cas, parce que la contribution à l'acquisition du bien est faite sans contrepartie.

[18] L'arrêt le plus récent de la Cour en matière de fiducies résultaires confirme l'approche selon laquelle, dans ces situations de transfert à titre gratuit, l'intention réelle du donateur est le facteur déterminant : *Pecore c. Pecore*, 2007 CSC 17, [2007] 1 R.C.S. 795, par. 43-44. Comme le juge Rothstein l'a indiqué au par. 44 de *Pecore*, lorsqu'un transfert à titre gratuit est contesté, « [l]e juge de première instance entamera son instruction en appliquant la présomption appropriée et il appréciera tous les éléments de preuve pour déterminer l'intention réelle de l'auteur du transfert, selon la prépondérance des probabilités » (je souligne).

[19] Comme le fait remarquer le juge Rothstein dans ce passage, les présomptions peuvent entrer en jeu lorsqu'il est question de transferts à titre gratuit. Le droit présume généralement que le donateur avait l'intention de créer une fiducie, au lieu de faire une donation, de sorte que la présomption de fiducie résultaire trouve souvent application. Comme l'a expliqué le juge Rothstein, une présomption de fiducie résultaire est la règle générale applicable aux transferts à titre gratuit. Dans le cas d'un tel transfert, la preuve de l'intention de faire un don incombe à son destinataire. Autrement, le destinataire détient le bien en fiducie au profit de l'auteur du transfert. Cette présomption repose sur le principe que l'équité présume l'existence d'une entente, et non d'une donation (*Pecore*, par. 24).

[20] Cependant, la présomption de fiducie résultaire n'est ni universelle ni irréfutable. Ainsi, par exemple, dans le cas de transferts entre des personnes ayant entre eux une certaine relation (comme celle d'un parent à un enfant mineur), une présomption d'avancement — c'est-à-dire une présomption selon laquelle l'auteur du transfert avait l'intention de faire une donation — au lieu d'une présomption de fiducie résultaire s'applique : voir *Pecore*, par. 27-41. Traditionnellement, la présomption d'avancement s'appliquait aux transferts à l'épouse alors

grants from wife to husband. Whether the application of the presumption of advancement applies to unmarried couples may be more controversial: Oosterhoff, at pp. 681-82. Although the trial judge in *Kerr* touched on this issue, neither party relies on the presumption of advancement and I need say nothing further about it.

[21] That brings me to the “common intention” resulting trust. It figured prominently in the majority judgment in *Murdoch v. Murdoch*, [1975] 1 S.C.R. 423. Quoting from Lord Diplock’s speech in *Gissing v. Gissing*, [1970] 2 All E.R. 780 (H.L.), at pp. 789 and 793, Martland J. held for the majority that, absent a financial contribution to the acquisition of the contested property, a resulting trust could only arise “where the court is satisfied by the words or conduct of the parties that it was their common intention that the beneficial interest was not to belong solely to the spouse in whom the legal estate was vested but was to be shared between them in some proportion or other”: *Murdoch*, at p. 438.

[22] This approach was repeated and followed by a majority of the Court three years later in *Rathwell*, at pp. 451-53, although the Court also unanimously found there had been a direct financial contribution by the claimant. In *Rathwell*, there is, as well, some blurring of the notions of contribution and common intention; there are references to the fact that a presumption of resulting trust is sometimes explained by saying that the fact of contribution evidences the common intention to share ownership: see p. 452, *per* Dickson J. (as he then was); p. 474, *per* Ritchie J. This blurring is also evident in the reasons of the Court of Appeal in *Kerr*, where the court said, at para. 42, that “[a] resulting trust is an equitable doctrine that, by operation of law, imposes a trust on a party who holds legal title to property that was gratuitously transferred to that party by another and where there is evidence of a common intention that the property was to be shared by both parties” (emphasis added).

que la présomption de fiducie résultoire s’appliquait aux transferts à l’époux. Il est fort possible que la question de savoir si la présomption d’avancement s’applique aux couples non mariés soit plus controversée : Oosterhoff, p. 681-682. Bien que, dans *Kerr*, le juge de première instance ait abordé cette question, ni l’une ni l’autre des parties n’invoque la présomption d’avancement et je ne dirai rien de plus sur cette question.

[21] Cela m’amène à la fiducie résultoire fondée sur l’« intention commune ». Elle a eu beaucoup d’importance dans les motifs de la majorité dans l’arrêt *Murdoch c. Murdoch*, [1975] 1 R.C.S. 423. Citant un extrait des motifs de lord Diplock dans *Gissing c. Gissing*, [1970] 2 All E.R. 780 (H.L.), p. 789 et 793, le juge Martland a conclu au nom de la majorité que, en l’absence d’une contribution financière à l’acquisition du bien contesté, une fiducie résultoire ne pouvait prendre naissance « que dans des cas où la cour est convaincue par les paroles ou la conduite des parties que leur intention commune était que la propriété véritable n’appartiendrait pas seulement au conjoint investi de la propriété légale mais serait partagée entre eux selon telle ou telle proportion » : *Murdoch*, p. 438.

[22] Trois ans plus tard, cette approche a été retenue et adoptée par une majorité de la Cour dans *Rathwell*, p. 451-453, bien que la Cour ait aussi conclu à l’unanimité qu’il y avait eu une contribution financière directe de la part de la demanderesse. Dans cet arrêt, les notions de contribution et d’intention commune sont aussi embrouillées; on y mentionne le fait qu’une présomption de fiducie résultoire s’explique parfois par le fait que la contribution prouve l’intention commune de partager le titre de propriété : voir p. 452, le juge Dickson (plus tard Juge en chef); p. 474, le juge Ritchie. Cette confusion ressort aussi des motifs de la Cour d’appel dans *Kerr*, où la cour a affirmé au par. 42 qu’[TRADUCTION] « [u]ne fiducie résultoire est une notion d’équité qui, par effet de la loi, impose une fiducie à une partie qui détient un titre légal afférent à un bien qui lui a été transféré à titre gratuit par une autre partie et dans les cas où des éléments de preuve indiquent l’intention commune qu’avaient les parties de partager le bien » (je souligne).

[23] The Court's development of the common intention resulting trust ended with *Pettkus*, in which Dickson J. (as he then was) noted the "many difficulties, chronicled in the cases and in the legal literature" as well as the "artificiality of the common intention approach" to resulting trusts: at pp. 842-43. He also clearly rejected the notion that the requisite common intention could be attributed to the parties where such an intention was negated by the evidence: p. 847. The import of *Pettkus* was that the law of unjust enrichment, coupled with the remedial constructive trust, became the more flexible and appropriate lens through which to view property and financial disputes in domestic situations. As Ms. Kerr stated in her factum, the "approach enunciated in *Pettkus v. Becker* has become the dominant legal paradigm for the resolution of property disputes between common law spouses" (para. 100).

[24] This, in my view, is as it should be, and the time has come to say that the common intention resulting trust has no further role to play in the resolution of domestic cases. I say this for four reasons.

[25] First, as the abundant scholarly criticism demonstrates, the common intention resulting trust is doctrinally unsound. It is inconsistent with the underlying principles of resulting trust law. Where the issue of intention is relevant to the finding of resulting trust, it is the intention of the grantor or contributor alone that counts. As Professor Waters puts it, "In imposing a resulting trust upon the recipient, Equity is never concerned with [common] intention" (*Waters'*, at p. 431). The underlying principles of resulting trust law also make it hard to accommodate situations in which the contribution made by the claimant was not in the form of property or closely linked to its acquisition. The point of the resulting trust is that the claimant is asking for his or her own property back, or for the recognition of his or her proportionate interest in the asset which the other has acquired with

[23] La Cour a cessé d'acquiescer à la notion de fiducie résultoire fondée sur l'intention commune dans l'arrêt *Pettkus*, où le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a souligné les « multiples difficultés, mentionnées dans la jurisprudence et les commentaires sur le sujet » ainsi que « le caractère artificiel de la recherche de l'intention commune » dans les fiducies résultoires : p. 842-843. Le juge Dickson a aussi clairement rejeté la notion selon laquelle l'intention commune requise pouvait être attribuée aux parties lorsqu'une telle intention était réfutée par la preuve : p. 847. Par suite de l'arrêt *Pettkus*, les règles de l'enrichissement injustifié, conjuguées aux règles de la fiducie constructive de nature réparatoire, sont devenues le mécanisme le plus souple et le plus approprié pour résoudre les litiges en matière de biens et les différends financiers en matière familiale. Comme M^{me} Kerr l'affirme dans son mémoire, [TRADUCTION] « l'approche énoncée dans l'arrêt *Pettkus c. Becker* est devenue le paradigme juridique dominant pour la résolution de litiges en matière de biens entre conjoints de fait » (par. 100).

[24] Selon moi, il doit en être ainsi et le moment est venu de dire que la fiducie résultoire à base d'intention commune n'a plus aucun rôle à jouer dans la résolution des litiges familiaux, et ce, pour quatre raisons.

[25] Premièrement, comme le démontrent les abondantes critiques, la fiducie résultoire basée sur l'intention commune est mal fondée sur le plan théorique. Elle est incompatible avec les principes sous-jacents du droit des fiducies résultoires. Dans les cas où la question de l'intention est pertinente pour conclure à l'existence d'une fiducie résultoire, seule l'intention du donateur ou du contributeur compte. Comme l'a dit le professeur Waters, [TRADUCTION] « [e]n imposant une fiducie résultoire au bénéficiaire, l'equity ne s'intéresse jamais à l'intention [commune] » (*Waters'*, p. 431). Les principes sous-jacents du droit des fiducies résultoires s'appliquent mal également aux situations où la contribution du demandeur ne s'est pas faite sous la forme d'un bien ni sous une forme étroitement liée à l'acquisition du bien. Le principe au cœur de la fiducie résultoire est que le demandeur réclame son propre

that property. This thinking extends artificially to claims that are based on contributions that are not clearly associated with the acquisition of an interest in property; in such cases there is not, in any meaningful sense, a “resulting” back of the transferred property: *Waters*’, at p. 432. It follows that a resulting trust based solely on intention without a transfer of property is, as Oosterhoff puts it, a doctrinal impossibility: “. . . a resulting trust can arise only when one person has transferred assets to, or purchased assets for, another person and did not intend to make a gift of the property”: p. 642. The final doctrinal problem is that the relevant time for ascertaining intention is the time of acquisition of the property. As a result, it is hard to see how a resulting trust can arise from contributions made over time to the improvement of an existing asset, or contributions in kind over time for its maintenance. As Oosterhoff succinctly puts it at p. 652, a resulting trust is inappropriate in these circumstances because its imposition, in effect, forces one party to give up beneficial ownership which he or she enjoyed before the improvement or maintenance occurred.

[26] There are problems beyond these doctrinal issues. A second difficulty with the common intention resulting trust is that the notion of common intention may be highly artificial, particularly in domestic cases. The search for common intention may easily become “a mere vehicle or formula” for giving a share of an asset, divorced from any realistic assessment of the actual intention of the parties. Dickson J. in *Pettkus* noted the artificiality and undue malleability of the common intention approach: at pp. 843-44.

[27] Third, the “common intention” resulting trust in Canada evolved from a misreading of some imprecise language in early authorities from the House of Lords. While much has been written on this topic, it is sufficient for my purposes to note, as did Dickson J. in *Pettkus*, at p. 842, that the principles upon which the common intention resulting

bien, ou la reconnaissance de son intérêt proportionnel dans l’actif acquis par une autre personne grâce à ce bien. Ce raisonnement s’étend artificiellement aux réclamations fondées sur des contributions qui ne sont pas clairement liées à l’acquisition d’un droit de propriété; dans de tels cas, il n’y a pas à toutes fins utiles de [TRADUCTION] « retour » du bien transféré : *Waters*’, p. 432. Ainsi, une fiducie résultoire uniquement fondée sur l’intention, sans transfert de biens, est, comme l’indique Oosterhoff, une impossibilité théorique : [TRADUCTION] « . . . une fiducie résultoire ne peut prendre naissance que lorsqu’une personne a transféré des biens à une autre personne, ou acheté des biens pour elle, sans avoir eu l’intention de lui en faire don » : p. 642. Le dernier problème théorique est qu’il faut déterminer l’intention au moment de l’acquisition du bien. Par conséquent, il est difficile de concevoir comment une fiducie résultoire peut découler de contributions versées au fil du temps dans le but d’améliorer un bien existant, ou de contributions en nature pour son entretien. Comme Oosterhoff l’explique brièvement à la p. 652, une fiducie résultoire est inappropriée dans ces circonstances parce que, dans les faits, elle oblige une partie à renoncer au droit de propriété à titre de bénéficiaire dont elle jouissait avant l’amélioration ou l’entretien du bien.

[26] Ces problèmes théoriques ne sont pas les seuls. La fiducie résultoire fondée sur l’intention commune pose une deuxième difficulté parce que la notion d’intention commune peut être extrêmement artificielle, surtout en matière familiale. La recherche d’une intention commune peut facilement devenir « un simple moyen ou une formule » pour donner une part dans un actif, sans aucune évaluation réaliste de l’intention réelle des parties. Dans *Pettkus*, le juge Dickson a fait remarquer le caractère artificiel et la malléabilité induite de la recherche de l’intention commune : p. 843-844.

[27] Troisièmement, la fiducie résultoire fondée sur « l’intention commune » au Canada tire son origine d’une interprétation erronée de quelques formulations imprécises dans l’ancienne jurisprudence de la Chambre des lords. Comme ce sujet a fait couler beaucoup d’encre, il suffit ici de noter, comme l’a fait le juge Dickson à la p. 842

trust jurisprudence developed are found in the House of Lords decisions in *Pettitt v. Pettitt*, [1970] A.C. 777, and *Gissing*. However, no clear majority opinion emerged in those cases and four of the five Law Lords in *Gissing* spoke of “resulting, implied or constructive trusts” without distinction. The passages that have been most influential in Canada on this point, those authored by Lord Diplock, in fact relate to constructive rather than resulting trusts: see, e.g., *Waters*, at pp. 430-35; Oosterhoff, at pp. 642-43. I find persuasive Professor Waters’ comments, specifically approved by Dickson J. in *Pettkus*, that where the search for common intention becomes simply a vehicle for reaching what the court perceives to be a just result, “[i]t is in fact a constructive trust approach masquerading as a resulting trust approach”: D. Waters, Comment (1975), 53 *Can. Bar Rev.* 366, at p. 368.

[28] Finally, as the development of the law since *Pettkus* has shown, the principles of unjust enrichment, coupled with the possible remedy of a constructive trust, provide a much less artificial, more comprehensive and more principled basis to address the wide variety of circumstances that lead to claims arising out of domestic partnerships. There is no need for any artificial inquiry into common intent. Claims for compensation as well as for property interests may be addressed. Contributions of all kinds and made at all times may be justly considered. The equities of the particular case are considered transparently and according to principle, rather than masquerading behind often artificial attempts to find common intent to support what the court thinks for unstated reasons is a just result.

[29] I would hold that the resulting trust arising solely from the common intention of the parties, as described by the Court in *Murdoch* and *Rathwell*,

de *Pettkus*, que les principes qui ont guidé l’évolution de la jurisprudence relative aux fiducies résultoires fondée sur l’intention commune se trouvent dans les arrêts *Pettitt c. Pettitt*, [1970] A.C. 777, et *Gissing* de la Chambre des lords. Cependant, aucune opinion majoritaire claire ne s’est dégagée dans ces arrêts et quatre des cinq lords juges dans *Gissing* ont parlé de [TRADUCTION] « fiducie résultoire, implicite, ou par interprétation » sans faire de distinction. Les passages ayant eu le plus de retentissement au Canada sur ce point, sous la plume de Lord Diplock, se rapportent en fait aux fiducies constructoires plutôt que résultoires : voir, par exemple, *Waters*, p. 430-435; Oosterhoff, p. 642-643. J’estime convaincants les commentaires du professeur Waters, expressément acceptés par le juge Dickson dans *Pettkus*, selon lesquels lorsque la recherche de l’intention commune devient simplement un moyen pour atteindre ce que le tribunal considère comme étant un résultat équitable, [TRADUCTION] « [c]’est en fait la fiducie par interprétation qui se déguise en une fiducie par déduction » : D. Waters, Commentaire (1975), 53 *R. du B. can.* 366, p. 368.

[28] Enfin, comme le montre l’évolution du droit depuis l’arrêt *Pettkus*, les principes de l’enrichissement injustifié, conjugués au recours possible à la fiducie constructive, fournissent un fondement beaucoup moins artificiel, plus complet et plus rationnel pour traiter de la grande variété des circonstances donnant lieu à des réclamations découlant d’unions conjugales. Il n’est nul besoin de mener une enquête artificielle sur l’intention commune. Les demandes d’indemnisation et les revendications de droits de propriété peuvent être examinées. Les contributions de toute sorte, versées à tout moment, peuvent être équitablement prises en considération. Le tribunal peut analyser l’équilibre particulier de l’affaire dans la transparence et conformément aux principes applicables, au lieu de tenter souvent artificiellement de trouver une intention commune qui appuie ce qu’il considère, pour des raisons inexprimées, être un résultat équitable.

[29] Je suis d’avis que la fiducie résultoire créée du seul fait de l’intention commune des parties, telle que décrite par la Cour dans *Murdoch* et *Rathwell*,

no longer has a useful role to play in resolving property and financial disputes in domestic cases. I emphasize that I am speaking here only of the common intention resulting trust. I am not addressing other aspects of the law relating to resulting trusts, nor am I suggesting that a resulting trust that would otherwise validly arise is defeated by the existence in fact of common intention.

III. Unjust Enrichment

A. *Introduction*

[30] The law of unjust enrichment has been the primary vehicle to address claims of inequitable distribution of assets on the breakdown of a domestic relationship. In a series of decisions, the Court has developed a sturdy framework within which to address these claims. However, a number of doctrinal and practical issues require further attention. I will first briefly set out the existing framework, then articulate the issues that in my view require further attention, and finally propose the ways in which they should be addressed.

B. *The Legal Framework for Unjust Enrichment Claims*

[31] At the heart of the doctrine of unjust enrichment lies the notion of restoring a benefit which justice does not permit one to retain: *Peel (Regional Municipality) v. Canada*, [1992] 3 S.C.R. 762, at p. 788. For recovery, something must have been given by the plaintiff and received and retained by the defendant without juristic reason. A series of categories developed in which retention of a conferred benefit was considered unjust. These included, for example: benefits conferred under mistakes of fact or law; under compulsion; out of necessity; as a result of ineffective transactions; or at the defendant's request: see *Peel*, at p. 789; see, generally, G. H. L. Fridman, *Restitution* (2nd ed. 1992), c. 3-5, 7, 8 and 10; and Lord Goff of Chieveley and G. Jones, *The Law of Restitution* (7th ed. 2007), c. 4-11, 17 and 19-26.

n'a plus de rôle utile à jouer dans la résolution des litiges relatifs aux droits de propriété et aux finances en matière familiale. Je tiens à préciser que je renvoie uniquement à la fiducie résultoire fondée sur l'intention commune. Je ne traite pas des autres aspects du droit applicable aux fiducies résultoires, et je ne suggère pas non plus qu'une fiducie résultoire par ailleurs valablement créée est anéantie en raison de l'existence d'une intention commune.

III. Enrichissement injustifié

A. *Introduction*

[30] Les règles relatives à l'enrichissement injustifié ont été le principal moyen utilisé pour régler les réclamations pour partage inéquitable des biens après la rupture d'une relation conjugale. Dans une série de décisions, la Cour a élaboré un cadre solide pour traiter de ces réclamations. Cependant, un certain nombre de questions théoriques et pratiques demandent un examen plus approfondi. Je vais d'abord énoncer brièvement le cadre juridique existant, puis j'exposerai les questions qui, à mon avis, méritent d'être examinées plus attentivement, et, enfin, je proposerai des façons de les aborder.

B. *Le cadre juridique de l'action pour enrichissement injustifié*

[31] Au cœur de la doctrine de l'enrichissement injustifié se trouve la notion de la restitution d'un avantage que la justice ne permet pas à une personne de conserver : *Peel (Municipalité régionale) c. Canada*, [1992] 3 R.C.S. 762, p. 788. Pour qu'il y ait recouvrement, il faut que le demandeur ait donné une chose et que la chose donnée ait été reçue et retenue par le défendeur sans motif juridique. Une série de catégories, où la conservation de l'avantage conféré a été jugée inéquitable, a été élaborée. Ces catégories incluaient notamment les avantages conférés par suite d'une erreur de fait ou de droit, sous la contrainte, par nécessité, par suite d'une opération non consommée ou à la demande du défendeur : voir *Peel*, p. 789; voir, en général, G. H. L. Fridman, *Restitution* (2^e éd. 1992), ch. 3-5, 7, 8 et 10; et Lord Goff of Chieveley et G. Jones, *The Law of Restitution* (7^e éd. 2007), ch. 4-11, 17 et 19-26.

[32] Canadian law, however, does not limit unjust enrichment claims to these categories. It permits recovery whenever the plaintiff can establish three elements: an enrichment of or benefit to the defendant, a corresponding deprivation of the plaintiff, and the absence of a juristic reason for the enrichment: *Pettkus*; *Peel*, at p. 784. By retaining the existing categories, while recognizing other claims that fall within the principles underlying unjust enrichment, the law is able “to develop in a flexible way as required to meet changing perceptions of justice”: *Peel*, at p. 788.

[33] The application of unjust enrichment principles to claims by domestic partners was resisted until the Court’s 1980 decision in *Pettkus*. In applying unjust enrichment principles to domestic claims, however, the Court has been clear that there is and should be no separate line of authority for “family” cases developed within the law of unjust enrichment. Rather, concern for clarity and doctrinal integrity mandate that “the basic principles governing the rights and remedies for unjust enrichment remain the same for all cases” (*Peter v. Beblow*, [1993] 1 S.C.R. 980, at p. 997).

[34] Although the legal principles remain constant across subject areas, they must be applied in the particular factual and social context out of which the claim arises. The Court in *Peter* was unanimously of the view that the courts “should exercise flexibility and common sense when applying equitable principles to family law issues with due sensitivity to the special circumstances that can arise in such cases” (p. 997, *per* McLachlin J. (as she then was); see also p. 1023, *per* Cory J.). Thus, while the underlying legal principles of the law of unjust enrichment are the same for all cases, the courts must apply those common principles in ways that respond to the particular context in which they are to operate.

[32] Toutefois, en droit canadien, les demandes fondées sur l’enrichissement injustifié ne se limitent pas à ces catégories. Le recouvrement est permis quand le demandeur peut prouver trois éléments : un enrichissement ou un avantage pour le défendeur, l’appauvrissement correspondant du demandeur et l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement : *Pettkus*; *Peel*, p. 784. En conservant les catégories existantes, tout en reconnaissant que les principes qui sous-tendent l’enrichissement injustifié s’appliquent à d’autres réclamations, le droit peut « évoluer avec la souplesse qui s’impose pour tenir compte des perceptions changeantes de la justice » : *Peel*, p. 788.

[33] L’application des principes de l’enrichissement injustifié aux réclamations présentées par des conjoints de fait s’est heurtée à une certaine résistance jusqu’à ce que la Cour rende sa décision dans *Pettkus* en 1980. En appliquant ces principes aux réclamations présentées par des conjoints de fait, la Cour a pris soin de préciser cependant qu’il n’y a pas et qu’il n’y avait pas lieu d’élaborer une jurisprudence distincte dans les affaires « familiales » dans le cadre des règles relatives à l’enrichissement injustifié. Au contraire, le souci de clarté et d’uniformité de la doctrine dans ce domaine veut que « les principes fondamentaux régissant les droits et les réparations demeurent les mêmes dans tous les cas » (*Peter c. Beblow*, [1993] 1 R.C.S. 980, p. 997).

[34] Bien que les principes juridiques demeurent constants dans tous les domaines, il faut les appliquer en fonction du contexte factuel et social particulier dans lequel les réclamations sont présentées. Dans *Peter*, la Cour a conclu à l’unanimité que les tribunaux « doivent faire preuve de souplesse et de bon sens lorsqu’ils appliquent les principes d’équité à des questions relevant du droit de la famille, tout en tenant bien compte des circonstances particulières de chaque cas » (p. 997, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef); voir aussi p. 1023, le juge Cory). Ainsi, bien que les principes juridiques qui sous-tendent les règles relatives à l’enrichissement injustifié soient les mêmes dans tous les cas, les tribunaux doivent appliquer ces principes communs en fonction du contexte particulier dans lequel ils doivent s’appliquer.

[35] It will be helpful to review, briefly, the current state of the law with respect to each of the elements of an unjust enrichment claim and note the particular issues in relation to each that arise in claims by domestic partners.

C. The Elements of an Unjust Enrichment Claim

(1) Enrichment and Corresponding Deprivation

[36] The first and second steps in the unjust enrichment analysis concern first, whether the defendant has been enriched by the plaintiff and second, whether the plaintiff has suffered a corresponding deprivation.

[37] The Court has taken a straightforward economic approach to the first two elements — enrichment and corresponding deprivation. Accordingly, other considerations, such as moral and policy questions, are appropriately dealt with at the juristic reason stage of the analysis: see *Peter*, at p. 990, referring to *Pettkus*, *Sorochan v. Sorochan*, [1986] 2 S.C.R. 38, and *Peel*, affirmed in *Garland v. Consumers' Gas Co.*, 2004 SCC 25, [2004] 1 S.C.R. 629, at para. 31.

[38] For the first requirement — enrichment — the plaintiff must show that he or she gave something to the defendant which the defendant received and retained. The benefit need not be retained permanently, but there must be a benefit which has enriched the defendant and which can be restored to the plaintiff *in specie* or by money. Moreover, the benefit must be tangible. It may be positive or negative, the latter in the sense that the benefit conferred on the defendant spares him or her an expense he or she would have had to undertake (*Peel*, at pp. 788 and 790; *Garland*, at paras. 31 and 37).

[39] Turning to the second element — a *corresponding* deprivation — the plaintiff's loss is material only if the defendant has gained a benefit or been enriched (*Peel*, at pp. 789-90). That is why the second requirement obligates the plaintiff to

[35] Il est utile de rappeler, brièvement, l'état actuel du droit relativement à chacun des éléments d'une demande fondée sur l'enrichissement injustifié et de signaler les questions particulières que soulèvent les réclamations des conjoints de fait.

C. Les éléments d'une demande fondée sur l'enrichissement injustifié

(1) Enrichissement et appauvrissement correspondant

[36] Les première et deuxième étapes de l'analyse de l'enrichissement injustifié portent premièrement sur la question de savoir si le défendeur s'est enrichi grâce au demandeur et, deuxièmement, sur la question de savoir si le demandeur a subi un appauvrissement correspondant.

[37] La Cour a appliqué une analyse économique simple aux deux premiers éléments — enrichissement et appauvrissement correspondant. Par conséquent, d'autres considérations, comme les questions de morale et d'intérêt public, doivent plutôt être examinées à l'étape de l'analyse du motif juridique : voir *Peter*, p. 990, renvoyant à *Pettkus*; *Sorochan c. Sorochan*, [1986] 2 R.C.S. 38; et *Peel*, confirmé dans *Garland c. Consumers' Gas Co.*, 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629, par. 31.

[38] Pour ce qui est du premier élément — l'enrichissement —, le demandeur doit prouver qu'il a donné quelque chose au défendeur et que ce dernier a reçu et retenu la chose donnée. Il n'est pas nécessaire que l'avantage soit conservé de façon permanente, mais il doit y avoir un avantage qui a enrichi le défendeur et qui peut être restitué *en nature* ou en argent au demandeur. De plus, l'avantage doit être tangible. Il peut être positif ou négatif, « négatif » en ce sens qu'il épargne au défendeur une dépense à laquelle il aurait été tenu (*Peel*, p. 788 et 790; *Garland*, par. 31 et 37).

[39] Pour ce qui est du deuxième élément — l'appauvrissement *correspondant* —, la perte subie par le demandeur n'est pertinente que si le défendeur a reçu un avantage ou qu'il a été enrichi (*Peel*, p. 789-790). C'est la raison pour laquelle le deuxième

establish not simply that the defendant has been enriched, but also that the enrichment corresponds to a deprivation which the plaintiff has suffered (*Pettkus*, at p. 852; *Rathwell*, at p. 455).

(2) Absence of Juristic Reason

[40] The third element of an unjust enrichment claim is that the benefit and corresponding detriment must have occurred without a juristic reason. To put it simply, this means that there is no reason in law or justice for the defendant's retention of the benefit conferred by the plaintiff, making its retention "unjust" in the circumstances of the case: see *Pettkus*, at p. 848; *Rathwell*, at p. 456; *Sorochan*, at p. 44; *Peter*, at p. 987; *Peel*, at pp. 784 and 788; *Garland*, at para. 30.

[41] Juristic reasons to deny recovery may be the intention to make a gift (referred to as a "donative intent"), a contract, or a disposition of law (*Peter*, at pp. 990-91; *Garland*, at para. 44; *Rathwell*, at p. 455). The latter category generally includes circumstances where the enrichment of the defendant at the plaintiff's expense is required by law, such as where a valid statute denies recovery (P. D. Maddaugh and J. D. McCamus, *The Law of Restitution* (1990), at p. 46; *Reference re Goods and Services Tax*, [1992] 2 S.C.R. 445; *Mack v. Canada (Attorney General)* (2002), 60 O.R. (3d) 737 (C.A.)). However, just as the Court has resisted a purely categorical approach to unjust enrichment claims, it has also refused to limit juristic reasons to a closed list. This third stage of the unjust enrichment analysis provides for due consideration of the autonomy of the parties, including factors such as "the legitimate expectation of the parties, the right of parties to order their affairs by contract" (*Peel*, at p. 803).

[42] A critical early question in domestic claims was whether the provision of domestic services could support a claim for unjust enrichment. After

élément oblige le demandeur à prouver non seulement que le défendeur s'est enrichi, mais aussi qu'il a subi un appauvrissement qui correspond à cet enrichissement (*Pettkus*, p. 852; *Rathwell*, p. 455).

(2) Absence de motif juridique

[40] Le troisième élément d'une action pour enrichissement injustifié est qu'il doit y avoir eu un avantage et un appauvrissement correspondant sans motif juridique. En somme, ni le droit ni les exigences de la justice ne permettent au défendeur de conserver l'avantage conféré par le demandeur, rendant la conservation de l'avantage « injuste » dans les circonstances de l'affaire : voir *Pettkus*, p. 848; *Rathwell*, p. 456; *Sorochan*, p. 44; *Peter*, p. 987; *Peel*, p. 784 et 788; *Garland*, par. 30.

[41] L'intention de faire un don (appelée « intention libérale »), le contrat ou la disposition légale peuvent constituer des motifs juridiques de refuser le recouvrement (*Peter*, p. 990-991; *Garland*, par. 44; *Rathwell*, p. 455). Cette dernière catégorie comprend habituellement les cas où la loi prescrit l'enrichissement du défendeur au détriment du demandeur, comme lorsqu'une loi valide empêche le recouvrement (P. D. Maddaugh et J. D. McCamus, *The Law of Restitution* (1990), p. 46; *Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services*, [1992] 2 R.C.S. 445; *Mack c. Canada (Procureur général)* (2002), 60 O.R. (3d) 756 (C.A.)). Cependant, tout comme la Cour n'a pas retenu une approche purement fondée sur des catégories de réclamations pour enrichissement injustifié, elle a aussi refusé de limiter les motifs juridiques à une liste restrictive. Cette troisième étape de l'analyse de l'enrichissement injustifié permet de prendre dûment en considération l'autonomie des parties, y compris des facteurs comme « l'expectative légitime des parties, leur droit de régler contractuellement leurs affaires et le droit des législateurs [...] d'agir selon leur bon jugement, sans avoir à craindre de se voir imposer ultérieurement des obligations imprévues » (*Peel*, p. 803).

[42] Dans les réclamations contre le conjoint, une question cruciale consistait au début à savoir si la prestation de services domestiques pouvait appuyer

some doubts, the matter was conclusively resolved in *Peter*, where the Court held that they could. A spouse or domestic partner generally has no duty, at common law, equity, or by statute, to perform work or services for the other. It follows, on a straight-forward economic approach, that there is no reason to distinguish domestic services from other contributions (*Peter*, at pp. 991 and 993; *Sorochan*, at p. 46). They constitute an enrichment because such services are of great value to the family and to the other spouse; any other conclusion devalues contributions, mostly by women, to the family economy (*Peter*, at p. 993). The unpaid provision of services (including domestic services) or labour may also constitute a deprivation because the full-time devotion of one's labour and earnings without compensation may readily be viewed as such. The Court rejected the view that such services could not found an unjust enrichment claim because they are performed out of "natural love and affection" (*Peter*, at pp. 989-95, *per* McLachlin J., and pp. 1012-16, *per* Cory J.).

[43] In *Garland*, the Court set out a two-step analysis for the absence of juristic reason. It is important to remember that what prompted this development was to ensure that the juristic reason analysis was not "purely subjective", thereby building into the unjust enrichment analysis an unacceptable "immeasurable judicial discretion" that would permit "case by case 'palm tree' justice": *Garland*, at para. 40. The first step of the juristic reason analysis applies the established categories of juristic reasons; in their absence, the second step permits consideration of the reasonable expectations of the parties and public policy considerations to assess whether recovery should be denied:

First, the plaintiff must show that no juristic reason from an established category exists to deny recovery. . . . The established categories that can constitute juristic reasons include a contract (*Pettkus*, *supra*), a disposition of law (*Pettkus*, *supra*), a donative intent (*Peter*, *supra*), and other valid common law, equitable or statutory

une action pour enrichissement injustifié. Après certaines hésitations, ce point a été définitivement réglé dans l'arrêt *Peter*, où la Cour a conclu que cela était possible. Généralement, un conjoint de fait n'est pas tenu en common law, en equity ou par la loi de travailler pour son conjoint ou de lui fournir des services. Par conséquent, selon une analyse économique simple, il n'y a aucune raison de distinguer les services domestiques des autres contributions (*Peter*, p. 991 et 993; *Sorochan*, p. 46). Ils constituent un enrichissement parce que de tels services sont fort utiles pour la famille et pour l'autre conjoint; toute autre conclusion dévalue les contributions apportées, principalement par les femmes, aux finances de la famille (*Peter*, p. 993). La prestation non rémunérée de services (y compris de services domestiques) ou le travail non rémunéré peuvent aussi constituer un appauvrissement parce qu'il n'y a aucune difficulté à considérer comme un appauvrissement la contribution à plein temps et sans compensation de son travail et de ses revenus. La Cour a rejeté l'argument selon lequel ces services ne peuvent fonder une action pour enrichissement injustifié parce qu'ils sont offerts par « amour et affection naturels » : (*Peter*, p. 989-995, la juge McLachlin, et p. 1012-1016, le juge Cory).

[43] Dans *Garland*, la Cour a élaboré une analyse en deux étapes de l'absence du motif juridique. Il est important de se rappeler que cela visait à éviter que l'analyse du motif juridique soit « purement subjecti[ve] », ajoutant à l'analyse de l'enrichissement injustifié un « pouvoir discrétionnaire incommensurable » inacceptable qui allait permettre le « cas par cas » : *Garland*, par. 40. La première étape de l'analyse du motif juridique consiste à appliquer les catégories établies de motifs juridiques; en l'absence de motif juridique dans une catégorie, la deuxième étape permet de tenir compte des attentes raisonnables des parties et des considérations d'intérêt public afin de déterminer si le recouvrement devrait être refusé :

Le demandeur doit d'abord démontrer qu'aucun motif juridique appartenant à une catégorie établie ne justifie de refuser le recouvrement. [. . .] Parmi les catégories établies susceptibles de constituer un motif juridique, il y a le contrat (*Pettkus*, précité), la disposition légale (*Pettkus*, précité), l'intention libérale (*Peter*, précité) et

obligations (*Peter*, *supra*). If there is no juristic reason from an established category, then the plaintiff has made out a *prima facie* case under the juristic reason component of the analysis.

The *prima facie* case is rebuttable, however, where the defendant can show that there is another reason to deny recovery. As a result, there is a *de facto* burden of proof placed on the defendant to show the reason why the enrichment should be retained. This stage of the analysis thus provides for a category of residual defence in which courts can look to all of the circumstances of the transaction in order to determine whether there is another reason to deny recovery.

As part of the defendant's attempt to rebut, courts should have regard to two factors: the reasonable expectations of the parties, and public policy considerations. [paras. 44-46]

[44] Thus, at the juristic reason stage of the analysis, if the case falls outside the existing categories, the court may take into account the legitimate expectations of the parties (*Pettkus*, at p. 849) and moral and policy-based arguments about whether particular enrichments are unjust (*Peter*, at p. 990). For example, in *Peter*, it was at this stage that the Court considered and rejected the argument that the provision of domestic and childcare services should not give rise to equitable claims against the other spouse in a marital or quasi-marital relationship (pp. 993-95). Overall, the test for juristic reason is flexible, and the relevant factors to consider will depend on the situation before the court (*Peter*, at p. 990).

[45] Policy arguments concerning individual autonomy may arise under the second branch of the juristic reason analysis. In the context of claims for unjust enrichment, this has led to questions regarding how (and when) factors relating to the manner in which the parties organized their relationship should be taken into account. It has been argued, for example, that the legislative decision to exclude unmarried couples from property division legislation indicates the court should not use the equitable doctrine of unjust enrichment to address their property and asset disputes. However, the court in

les autres obligations valides imposées par la common law, l'équité ou la loi (*Peter*, précité). S'il n'existe aucun motif juridique appartenant à une catégorie établie, le demandeur a alors établi une preuve *prima facie* en ce qui concerne le volet « motif juridique » de l'analyse.

La preuve *prima facie* est cependant réfutable si le défendeur parvient à démontrer qu'il existe un autre motif de refuser le recouvrement. En conséquence, le défendeur a l'obligation *de facto* de démontrer pourquoi il devrait conserver ce dont il s'est enrichi. À cette étape de l'analyse, le défendeur peut donc recourir à une catégorie de moyens de défense résiduels qui permettent aux tribunaux d'examiner toutes les circonstances de l'opération afin de déterminer s'il existe un autre motif de refuser le recouvrement.

Lorsque le défendeur tente de réfuter la preuve en question, les tribunaux doivent tenir compte de deux facteurs : les attentes raisonnables des parties et les considérations d'intérêt public. [par. 44-46]

[44] Ainsi, à l'étape de l'analyse qui porte sur le motif juridique, si aucune catégorie établie ne s'applique, la cour peut prendre en considération les attentes légitimes des parties (*Pettkus*, p. 849) ainsi que les arguments de morale et d'intérêt public sur la question de savoir si l'enrichissement est injustifié (*Peter*, p. 990). Par exemple, dans *Peter*, c'est à cette étape que la Cour a examiné et rejeté l'argument selon lequel la prestation de services domestiques et de soins des enfants ne devrait pas, dans une relation matrimoniale ou quasi matrimoniale, donner lieu à une réclamation en equity contre l'autre conjoint (p. 993-995). Dans l'ensemble, le critère du motif juridique est souple et les facteurs à considérer varieront en fonction de la situation dont la cour est saisie (*Peter*, p. 990).

[45] Les arguments d'intérêt public touchant l'autonomie personnelle peuvent être soulevés à la deuxième étape de l'analyse du motif juridique. Dans le contexte des actions pour enrichissement injustifié, cela a mené à rechercher comment (et quand) les facteurs relatifs à la façon dont les parties structurent leur union devraient être pris en considération. On a soutenu, par exemple, que la décision du législateur d'exclure les couples non mariés de la protection des lois relatives au partage des biens indique que la cour ne devrait pas appliquer la théorie de l'enrichissement injustifié

Peter rejected this argument, noting that it misapprehended the role of equity. As McLachlin J. put it at p. 994, “It is precisely where an injustice arises without a legal remedy that equity finds a role.” (See also *Nova Scotia (Attorney General) v. Walsh*, 2002 SCC 83, [2002] 4 S.C.R. 325, at para. 61.)

(3) Remedy

[46] Remedies for unjust enrichment are restitutionary in nature; that is, the object of the remedy is to require the defendant to repay or reverse the unjustified enrichment. A successful claim for unjust enrichment may attract either a “personal restitutionary award” or a “restitutionary proprietary award”. In other words, the plaintiff may be entitled to a monetary or a proprietary remedy (*Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574, at p. 669, *per* La Forest J.).

(a) *Monetary Award*

[47] The first remedy to consider is always a monetary award (*Peter*, at pp. 987 and 999). In most cases, it will be sufficient to remedy the unjust enrichment. However, calculation of such an award is far from straightforward. Two issues have given rise to disagreement and difficulty in domestic unjust enrichment claims.

[48] First, the fact that many domestic claims of unjust enrichment arise out of relationships in which there has been a mutual conferral of benefits gives rise to difficulties in determining what will constitute adequate compensation. While the value of domestic services is not questioned (*Peter*; *Sorochan*), it is unjust to pay attention only to the contributions of one party in assessing an appropriate remedy. This is not only an important issue of principle; in practice, it is enormously difficult for the parties and the court to “create, retroactively, a notional ledger to record and value every service rendered by each party to the other” (R. E. Scane,

reconnue en equity pour régler les différends en matière de biens et d’actifs. Toutefois, dans *Peter*, la Cour a rejeté cet argument, soulignant qu’on se méprenait sur le rôle de l’equity. Comme l’a dit la juge McLachlin à la p. 994, « [c]’est précisément dans les cas où une injustice ne peut pas être réparée en vertu de la loi que l’equity joue un rôle. » (Voir également *Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh*, 2002 CSC 83, [2002] 4 R.C.S. 325, par. 61.)

(3) Réparation

[46] Les moyens utilisés pour corriger l’enrichissement injustifié sont de nature réparatoire, en ce que la réparation oblige le défendeur à rembourser ou à annuler l’enrichissement injustifié. Lorsqu’une action pour enrichissement injustifié est accueillie, il y a soit « indemnisation », soit « restitution du bien ». En d’autres termes, le demandeur a droit à une réparation pécuniaire ou fondée sur le droit de propriété (*Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574, p. 669, le juge La Forest).

a) *Une réparation pécuniaire*

[47] Il faut toujours considérer la réparation pécuniaire en premier (*Peter*, p. 987 et 999). Dans la plupart des cas, elle suffira à corriger l’enrichissement injustifié. Toutefois, le calcul d’une telle réparation est loin d’être simple. Deux questions ont suscité des désaccords et des difficultés dans le cas des conjoints de fait.

[48] D’abord, comme bon nombre d’actions pour enrichissement injustifié découlent de relations où les conjoints ont mutuellement tiré des avantages, il est difficile de déterminer ce qui constitue une réparation adéquate. Bien que la valeur des services domestiques ne soit pas remise en question (*Peter*; *Sorochan*), il est injuste de tenir compte des contributions d’une seule partie au moment de déterminer la réparation appropriée. Ce n’est pas seulement une importante question de principe; en pratique, il est extrêmement difficile pour les parties et le tribunal de [TRADUCTION] « créer, rétroactivement, un registre symbolique où inscrire chaque service

“Relationships ‘Tantamount to Spousal’, Unjust Enrichment, and Constructive Trusts” (1991), 70 *Can. Bar Rev.* 260, at p. 281). This gives rise to the practical problem that one scholar has aptly referred to as “duelling *quantum meruits*” (J. D. McCamus, “Restitution on Dissolution of Marital and Other Intimate Relationships: Constructive Trust or Quantum Meruit?”, in J. W. Neyers, M. McInnes and S. G. A. Pitel, eds., *Understanding Unjust Enrichment* (2004), 359, at p. 376). McLachlin J. also alluded to this practical problem in *Peter*, at p. 999.

[49] A second difficulty arises from the fact that some courts and commentators have read *Peter* as holding that when a monetary award is appropriate, it must invariably be calculated on the basis of the monetary value of the unpaid services. This is often referred to as the *quantum meruit*, or “value received” or “fee-for-services” approach. This was followed in *Bell v. Bailey* (2001), 203 D.L.R. (4th) 589 (Ont. C.A.). Other appellate courts have held that monetary relief may be assessed more flexibly — in effect, on a value survived basis — by reference, for example, to the overall increase in the couple’s wealth during the relationship: *Wilson v. Fotsch*, 2010 BCCA 226, 319 D.L.R. (4th) 26, at para. 50; *Pickelein v. Gillmore* (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 44 (C.A.); *Harrison v. Kalinocha* (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 273 (C.A.); *MacFarlane v. Smith*, 2003 NBCA 6, 256 N.B.R. (2d) 108, at paras. 31-34 and 41-43; *Shannon v. Gidden*, 1999 BCCA 539, 71 B.C.L.R. (3d) 40, at para. 37. With respect to inconsistencies in how *in personam* relief for unjust enrichment may be quantified, see also *Matrimonial Property Law in Canada* (loose-leaf), vol. 1, by J. G. McLeod and A. A. Mamo, eds., at pp. 40.78-40.79.

(b) *Proprietary Award*

[50] The Court has recognized that, in some cases, when a monetary award is inappropriate or insufficient, a proprietary remedy may be required. *Pettkus* is responsible for an important remedial

rendu par chacune des parties et en déterminer la valeur » (R. E. Scane, « Relationships ‘Tantamount to Spousal’, Unjust Enrichment, and Constructive Trusts » (1991), 70 *R. du B. can.* 260, p. 281). Un auteur a judicieusement qualifié ce problème pratique de [TRADUCTION] « duel de *quantum meruit* » (J. D. McCamus, « Restitution on Dissolution of Marital and Other Intimate Relationships : Constructive Trust or Quantum Meruit? » dans J. W. Neyers, M. McInnes et S. G. A. Pitel, dir., *Understanding Unjust Enrichment* (2004), 359, p. 376). La juge McLachlin a également mentionné ce problème pratique dans *Peter*, p. 999.

[49] Une deuxième difficulté tient au fait que, selon certains tribunaux et certains auteurs, l’arrêt *Peter* pose qu’une réparation pécuniaire appropriée doit invariablement être calculée en fonction de la valeur monétaire des services non rémunérés. On parle souvent, dans ce cas, de *quantum meruit*, de « valeur reçue » ou de « rémunération des services ». Ce raisonnement a été suivi dans *Bell c. Bailey* (2001), 203 D.L.R. (4th) 589 (C.A. Ont.). D’autres cours d’appel ont conclu que la réparation pécuniaire pouvait être évaluée de manière plus souple — selon la méthode fondée sur la valeur accumulée — en fonction, par exemple, de l’augmentation globale de la richesse du couple pendant l’union : *Wilson c. Fotsch*, 2010 BCCA 226, 319 D.L.R. (4th) 26, par. 50; *Pickelein c. Gillmore* (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 44 (C.A.); *Harrison c. Kalinocha* (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 273 (C.A.); *MacFarlane c. Smith*, 2003 NBCA 6, 256 R.N.-B. (2^e) 108, par. 31-34 et 41-43; *Shannon c. Gidden*, 1999 BCCA 539, 71 B.C.L.R. (3d) 40, par. 37. Quant aux incohérences relevées dans la façon de calculer une réparation personnelle pour enrichissement injustifié, voir aussi *Matrimonial Property Law in Canada* (feuilles mobiles), vol. 1, J. G. McLeod et A. A. Mamo, dir., p. 40.78-40.79.

b) *Réparation fondée sur le droit de propriété*

[50] La Cour a reconnu que, dans certains cas, si une réparation pécuniaire est inappropriée ou insuffisante, il peut être nécessaire d’accorder une réparation fondée sur le droit de propriété. C’est

feature of the Canadian law of unjust enrichment: the development of the remedial constructive trust. Imposed without reference to intention to create a trust, the constructive trust is a broad and flexible equitable tool used to determine beneficial entitlement to property (*Pettkus*, at pp. 843-44 and 847-48). Where the plaintiff can demonstrate a link or causal connection between his or her contributions and the acquisition, preservation, maintenance or improvement of the disputed property, a share of the property proportionate to the unjust enrichment can be impressed with a constructive trust in his or her favour (*Pettkus*, at pp. 852-53; *Sorochan*, at p. 50). *Pettkus* made clear that these principles apply equally to unmarried cohabitants, since “[t]he equitable principle on which the remedy of constructive trust rests is broad and general; its purpose is to prevent unjust enrichment in whatever circumstances it occurs” (pp. 850-51).

[51] As to the nature of the link required between the contribution and the property, the Court has consistently held that the plaintiff must demonstrate a “sufficiently substantial and direct” link, a “causal connection” or a “nexus” between the plaintiff’s contributions and the property which is the subject matter of the trust (*Peter*, at pp. 988, 997 and 999; *Pettkus* at p. 852; *Sorochan*, at pp. 47-50; *Rathwell*, at p. 454). A minor or indirect contribution will not suffice (*Peter*, at p. 997). As Dickson C.J. put it in *Sorochan*, the primary focus is on whether the contributions have a “clear proprietary relationship” (p. 50, citing Professor McLeod’s annotation of *Herman v. Smith* (1984), 42 R.F.L. (2d) 154, at p. 156). Indirect contributions of money and direct contributions of labour may suffice, provided that a connection is established between the plaintiff’s deprivation and the acquisition, preservation, maintenance, or improvement of the property (*Sorochan*, at p. 50; *Pettkus*, at p. 852).

[52] The plaintiff must also establish that a monetary award would be insufficient in the circumstances (*Peter*, at p. 999). In this regard, the court may take into account the probability of recovery, as well as whether there is a reason to grant the

dans l’arrêt *Pettkus* qu’on a d’abord reconnu un remède important en enrichissement injustifié au Canada : la fiducie constructive de nature réparatoire. Imposée sans qu’il y ait une intention de créer une fiducie, la fiducie constructive est un outil général, souple et juste qui permet de déterminer le droit de propriété véritable (*Pettkus*, p. 843-844 et 847-848). Si le demandeur peut établir un lien ou un rapport de causalité entre ses contributions et l’acquisition, la conservation, l’entretien ou l’amélioration du bien en cause, une part proportionnelle à l’enrichissement injustifié peut faire l’objet d’une fiducie constructive en sa faveur (*Pettkus*, p. 852-853; *Sorochan*, p. 50). Il ressort clairement de l’arrêt *Pettkus* que ces principes s’appliquent également aux conjoints non mariés, puisque « [l]e principe d’équité sur lequel repose le recours à la fiducie par interprétation [ou fiducie constructive] est large et général; son but est d’empêcher l’enrichissement sans cause dans toutes les circonstances où il se présente » (p. 850-851).

[51] Quant à la nature du lien exigé entre la contribution et le bien, la Cour a toujours jugé que le demandeur devait démontrer un lien « suffisamment important et direct », un « lien causal » ou un « lien » entre les contributions du demandeur et le bien visé par la fiducie (*Peter*, p. 988, 997 et 999; *Pettkus*, p. 852; *Sorochan*, p. 47-50; *Rathwell*, p. 454). Une contribution mineure ou indirecte ne suffit pas (*Peter*, p. 997). Comme l’a dit le juge en chef Dickson dans *Sorochan*, la question fondamentale est de savoir si les contributions « se rapportent clairement aux biens » (p. 50, citant les notes du professeur McLeod relatives à *Herman c. Smith* (1984), 42 R.F.L. (2d) 154, p. 156). La contribution indirecte d’argent et la contribution directe de labeur peuvent être suffisantes, pourvu qu’un lien soit établi entre l’appauvrissement du demandeur et l’acquisition, la conservation, l’entretien ou l’amélioration du bien (*Sorochan*, p. 50; *Pettkus*, p. 852).

[52] Le demandeur doit aussi prouver qu’une réparation pécuniaire serait insuffisante dans les circonstances (*Peter*, p. 999). À cet égard, le tribunal peut tenir compte de la probabilité de recouvrement ainsi que de la question de savoir s’il existe

plaintiff the additional rights that flow from recognition of property rights (*Lac Minerals*, at p. 678, *per* La Forest J.).

[53] The extent of the constructive trust interest should be proportionate to the claimant's contributions. Where the contributions are unequal, the shares will be unequal (*Pettkus*, at pp. 852-53; *Rathwell*, at p. 448; *Peter*, at pp. 998-99). As Dickson J. put it in *Rathwell*, "The court will assess the contributions made by each spouse and make a fair, equitable distribution having regard to the respective contributions" (p. 454).

D. *Areas Needing Clarification*

[54] While the law of unjust enrichment sets out a sturdy legal framework within which to address claims by domestic partners, three areas continue to generate controversy and require clarification. As mentioned earlier, these are as follows: the approach to the assessment of a monetary award for a successful unjust enrichment claim, how and where to address the mutual benefit problem, and the role of the parties' reasonable or legitimate expectations. I will address these in turn.

E. *Is a Monetary Award Restricted to Quantum Meruit?*

(1) Introduction

[55] As noted earlier, remedies for unjust enrichment may either be proprietary (normally a remedial constructive trust) or personal (normally a money remedy). Once the choice has been made to award a monetary rather than a proprietary remedy, the question of how to quantify that monetary remedy arises. Some courts have held that monetary relief must always be calculated based on a value received or *quantum meruit* basis (*Bell*), while others have held that monetary relief may also be based on a value survived (i.e. by reference to the value of property) approach (*Wilson*; *Pickelein*; *Harrison*; *MacFarlane*; *Shannon*). If, as some courts have

une raison d'accorder au demandeur des droits supplémentaires découlant de la reconnaissance d'un droit de propriété (*Lac Minerals*, p. 678, le juge La Forest).

[53] La part de propriété devrait être proportionnelle aux contributions du demandeur. Si les contributions sont inégales, les parts seront inégales (*Pettkus*, p. 852-853; *Rathwell*, p. 448; *Peter*, p. 998-999). Comme l'a expliqué le juge Dickson dans *Rathwell*, « [l]e tribunal évaluera les contributions de chaque conjoint et fera un partage juste et équitable selon leur contribution respective » (p. 454).

D. *Sujets nécessitant des précisions*

[54] Bien que les règles relatives à l'enrichissement injustifié constituent un cadre juridique solide pour régler les réclamations présentées par les conjoints vivant en union de fait, trois sujets continuent de susciter la controverse et nécessitent des précisions. Comme je l'ai déjà dit, ce sont le mode de calcul de la réparation pécuniaire lorsqu'une action pour enrichissement injustifié est accueillie, la façon d'examiner le problème des avantages réciproques et le moment pour le faire, ainsi que le rôle des attentes raisonnables ou légitimes des parties. Je vais aborder ces trois sujets à tour de rôle.

E. *Une réparation pécuniaire est-elle restreinte au quantum meruit?*

(1) Introduction

[55] Comme je l'ai fait remarquer précédemment, les réparations en cas d'enrichissement injustifié peuvent être soit fondées sur le droit de propriété (habituellement un recours à la fiducie constructive), soit personnelles (habituellement une réparation pécuniaire). Une fois que la décision est prise d'accorder une réparation pécuniaire plutôt qu'une réparation fondée sur le droit de propriété, la question de savoir comment quantifier cette réparation pécuniaire se pose. Selon certains tribunaux, la réparation pécuniaire doit toujours être calculée en fonction de la valeur reçue ou du *quantum meruit* (*Bell*), et selon d'autres tribunaux, elle peut aussi

held, a monetary remedy must invariably be quantified on a *quantum meruit* basis, the remedial choice in unjust enrichment cases becomes whether to impose a constructive trust or order a monetary remedy calculated on a *quantum meruit* basis. One scholar has referred to this approach as the false dichotomy between constructive trust and *quantum meruit* (McCamus, at pp. 375-76). Scholars have also noted this area of uncertainty in the case law, and have suggested that an *in personam* remedy using the value survived measure is a plausible alternative to the constructive trust (McCamus, at p. 377; P. Birks, *An Introduction to the Law of Restitution* (1985), at pp. 394-95). As I will explain below, *Peter* is said to have established this dichotomy of remedial choice. However, in my view, the focus in *Peter* was on the availability of the constructive trust remedy, and that case should not be taken as limiting the calculation of monetary relief for unjust enrichment to a *quantum meruit* basis. In appropriate circumstances, monetary relief may be assessed on a value survived basis.

[56] I will first briefly describe the genesis of the purported limitation on the monetary remedy. Then I will explain why, in my view, it should be rejected. Finally, I will set out my views on how money remedies for unjust enrichment claims in domestic situations should be approached.

(2) The Remedial Dichotomy

[57] As noted, there is a widespread, although not unanimous, view that there are only two choices of remedy for an unjust enrichment: a monetary award, assessed on a fee-for-services basis; or a proprietary one (generally taking the form of a remedial constructive trust), where the claimant can show

être fondée sur la valeur accumulée (c.-à-d. en fonction de la valeur du bien) (*Wilson; Pickelien; Harrison; MacFarlane; Shannon*). Si, comme l'ont conclu certains tribunaux, la réparation pécuniaire doit invariablement être quantifiée en fonction du *quantum meruit*, il faut alors, dans les cas d'enrichissement injustifié, se demander s'il faut choisir d'imposer une fiducie constructive ou d'ordonner une réparation pécuniaire calculée en fonction du *quantum meruit*. Un auteur a qualifié cette approche de fausse dichotomie entre la fiducie constructive et le *quantum meruit* (McCamus, p. 375-376). Certains auteurs ont aussi souligné cette incertitude qui règne dans la jurisprudence et ont affirmé qu'une réparation personnelle (*in personam*) fondée sur la valeur accumulée est une alternative plausible à la fiducie constructive (McCamus, p. 377; P. Birks, *An Introduction to the Law of Restitution* (1985), p. 394-395). Comme je l'explique ci-après, on dit que c'est dans l'arrêt *Peter* que ce principe de dichotomie quant au choix de la réparation a été établi. Toutefois, à mon avis, l'arrêt *Peter* portait principalement sur la possibilité de recourir à la fiducie constructive de nature réparatoire et cet arrêt ne devrait pas être interprété comme limitant le calcul de la réparation pécuniaire au *quantum meruit* dans les cas d'enrichissement injustifié. Lorsque les circonstances s'y prêtent, la réparation pécuniaire peut être fondée sur la valeur accumulée.

[56] Je vais d'abord exposer brièvement la genèse de la restriction à laquelle on voudrait soumettre la réparation pécuniaire. Ensuite, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, elle devrait être rejetée. Enfin, je vais exposer mon opinion sur la façon dont il convient de traiter les réparations pécuniaires pour enrichissement injustifié en matière familiale.

(2) La dichotomie des mesures de réparation

[57] Comme je l'ai déjà dit, selon une opinion très répandue, mais non unanime, il y a seulement deux choix de réparation en cas d'enrichissement injustifié : une réparation pécuniaire, évaluée en fonction de la rémunération des services rendus; ou une réparation fondée sur le droit de

that the benefit conferred contributed to the acquisition, preservation, maintenance, or improvement of specific property. Some brief comments in *Peter* seem to have spawned this idea, which is reflected in a number of appellate authorities. For instance, in the *Vanasse* appeal, the Ontario Court of Appeal reasoned that since Ms. Vanasse could not show that her contributions were linked to specific property, her claim had to be quantified on a fee-for-services basis. I respectfully do not agree that monetary awards for unjust enrichment must always be calculated in this way.

(3) Why the Remedial Dichotomy Should Be Rejected

[58] In my view, restricting the money remedy to a fee-for-services calculation is inappropriate for four reasons. First, it fails to reflect the reality of the lives of many domestic partners. Second, it is inconsistent with the inherent flexibility of unjust enrichment. Third, it ignores the historical basis of *quantum meruit* claims. Finally, it is not mandated by the Court's judgment in *Peter*. For those reasons, this remedial dichotomy should be rejected. The discussion which follows is concerned only with the quantification of a monetary remedy for unjust enrichment; the law relating to when a proprietary remedy should be granted is well established and remains unchanged.

(a) *Life Experience*

[59] The remedial dichotomy would be appropriate if, in fact, the bases of all domestic unjust enrichment claims fit into only two categories — those where the enrichment consists of the provision of unpaid services, and those where it consists

propriété (généralement sous la forme d'une fiducie constructive de nature réparatoire), si le demandeur peut prouver que l'avantage conféré a contribué à l'acquisition, la conservation, l'entretien ou l'amélioration d'un bien en particulier. Quelques brefs commentaires formulés dans *Peter* semblent être à l'origine de cette idée, laquelle est reflétée dans un certain nombre de décisions rendues par des cours d'appel. Par exemple, dans *Vanasse*, la Cour d'appel de l'Ontario a adopté le raisonnement suivant : puisque M^{me} Vanasse ne pouvait pas prouver que ses contributions étaient liées à un bien en particulier, sa réclamation devait être quantifiée en fonction de la rémunération des services rendus. En toute déférence, je ne souscris pas à l'opinion selon laquelle les réparations pécuniaires en cas d'enrichissement injustifié doivent toujours être calculées de cette façon.

(3) Pourquoi rejeter la dichotomie des mesures de réparation?

[58] À mon avis, il est inapproprié de calculer la réparation pécuniaire en fonction de la rémunération des services rendus, et ce, pour quatre raisons. Premièrement, ce type de calcul ne reflète pas la réalité de nombreux conjoints vivant en union libre. Deuxièmement, il est incompatible avec la souplesse inhérente à l'enrichissement injustifié. Troisièmement, il ne tient pas compte de l'historique des réclamations fondées sur le *quantum meruit*. Enfin, l'arrêt *Peter* ne l'impose pas. Pour ces raisons, la dichotomie des mesures de réparation devrait être rejetée. L'analyse qui suit concerne seulement la quantification d'une réparation pécuniaire en cas d'enrichissement injustifié; les règles servant à déterminer dans quels cas une réparation fondée sur le droit de propriété devrait être accordée sont bien établies et demeurent inchangées.

a) *Expérience de vie*

[59] La dichotomie des mesures de réparation serait appropriée si, dans les faits, les fondements de toutes les actions pour enrichissement injustifié intentées par des conjoints de fait entraient dans deux catégories seulement — celle

of an unrecognized contribution to the acquisition, improvement, maintenance or preservation of specific property. To be sure, those two bases for unjust enrichment claims exist. However, all unjust enrichment cases cannot be neatly divided into these two categories.

[60] At least one other basis for an unjust enrichment claim is easy to identify. It consists of cases in which the contributions of both parties over time have resulted in an accumulation of wealth. The unjust enrichment occurs following the breakdown of their relationship when one party retains a disproportionate share of the assets which are the product of their joint efforts. The required link between the contributions and a specific property may not exist, making it inappropriate to confer a proprietary remedy. However, there may clearly be a link between the joint efforts of the parties and the accumulation of wealth; in other words, a link between the “value received” and the “value surviving”, as McLachlin J. put it in *Peter*, at pp. 1000-1001. Thus, where there is a relationship that can be described as a “joint family venture”, and the joint efforts of the parties are linked to the accumulation of wealth, the unjust enrichment should be thought of as leaving one party with a disproportionate share of the jointly earned assets.

[61] There is nothing new about the notion of a joint family venture in which both parties contribute to their overall accumulation of wealth. It was recognition of this reality that contributed to comprehensive matrimonial property legislative reform in the late 1970s and early 1980s. As the Court put it in *Clarke v. Clarke*, [1990] 2 S.C.R. 795, at p. 807 (in relation to Nova Scotia’s *Matrimonial Property Act*), “. . . the Act supports the equality of both parties to a marriage and recognizes the joint contribution of the spouses, be it financial or otherwise, to that enterprise. . . . The Act is accordingly remedial in nature. It was designed to alleviate the inequities of the past when the contribution made by

où l’enrichissement découle de la prestation de services non rémunérés, et celle où il découle d’une contribution non reconnue à l’acquisition, à l’amélioration, à l’entretien ou à la conservation d’un bien en particulier. Certes, ces deux fondements sur lesquels reposent les actions pour enrichissement injustifié existent. Cependant, tous les cas d’enrichissement injustifié ne se répartissent pas nettement entre ces deux catégories.

[60] Il est facile de dégager au moins une autre catégorie d’enrichissement injustifié, soit celle où les contributions des deux parties ont, au fil du temps, entraîné une accumulation de la richesse. Il y a un enrichissement injustifié quand une partie conserve, après la rupture, une part disproportionnée des biens obtenus grâce à l’effort conjoint des deux parties. Le lien requis entre les contributions et un bien en particulier n’existe peut-être pas, de sorte qu’il est inapproprié d’accorder une réparation fondée sur le droit de propriété. Or, il peut y avoir un lien incontestable entre les efforts conjoints des parties et l’accumulation de richesse; en d’autres termes, un lien entre la « valeur reçue » et la « valeur accumulée » comme la juge McLachlin l’a dit dans *Peter*, p. 1000-1001. Ainsi, si une relation peut être décrite comme étant une « coentreprise familiale » et les efforts conjoints des parties sont liés à l’accumulation de la richesse, on peut considérer qu’il y a un enrichissement injustifié lorsqu’une partie quitte avec une part disproportionnée des avoirs acquis conjointement.

[61] Il n’y a rien de nouveau à propos de la notion d’entreprise familiale où les deux parties contribuent à leur enrichissement global. C’est la reconnaissance de cette réalité qui a donné lieu à la réforme législative globale des régimes matrimoniaux à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Comme l’a expliqué la Cour dans *Clarke c. Clarke*, [1990] 2 R.C.S. 795, à la p. 807 (relativement à la *Matrimonial Property Act* de la Nouvelle-Écosse), « [l]a Loi appuie donc l’égalité des deux parties dans un mariage et reconnaît la contribution solidaire des conjoints, qu’elle soit financière ou autre, à cette entreprise. [. . .] En conséquence, la Loi est de nature réparatrice. Elle

women to the economic survival and growth of the family was not recognized” (emphasis added).

[62] Unlike much matrimonial property legislation, the law of unjust enrichment does not mandate a presumption of equal sharing. However, the law of unjust enrichment can and should respond to the social reality identified by the legislature that many domestic relationships are more realistically viewed as a joint venture to which the parties jointly contribute.

[63] This reality has also been recognized many times and in many contexts by the Court. For instance, in *Murdoch*, Laskin J. (as he then was), in dissent, would have imposed constructive trust relief, on the basis that the facts were “consistent with a pooling of effort by the spouses” to establish themselves in a ranch operation (p. 457), and that the spouses had worked together for fifteen years to improve “their lot in life through progressively larger acquisitions of ranch property” (p. 446). Similarly, in *Rathwell*, a majority of the judges agreed that Mr. and Mrs. Rathwell had pooled their efforts to accumulate wealth as a team. Dickson J. emphasized that the parties had together “decided to make farming their way of life” (p. 444), and that the acquisition of property in Mr. Rathwell’s name was only made possible through their “joint effort” and “team work” (p. 461).

[64] A similar recognition is evident in *Pettkus* and *Peter*.

[65] In *Pettkus*, the parties developed a successful beekeeping business, the profits from which they used to acquire real property. Dickson J., writing for the majority of the Court, emphasized facts suggestive of a domestic and financial partnership. He observed that “each started with nothing; each worked continuously, unremittingly and sedulously in the joint effort” (p. 853); that each contributed

a été rédigée pour pallier les inéquités du passé, quand la contribution faite par les femmes à la survie économique et à la croissance de la famille n’était pas reconnue » (je souligne).

[62] Les règles relatives à l’enrichissement injustifié n’entraînent pas une présomption de partage égal, comme c’est le cas de nombreux textes législatifs relatifs aux régimes matrimoniaux. Cependant, elles peuvent et devraient tenir compte de la réalité sociale cernée par le législateur selon laquelle beaucoup de relations conjugales sont, de manière plus réaliste, considérées comme des coentreprises auxquelles contribuent conjointement les deux parties.

[63] La Cour a reconnu cette réalité à maintes reprises et dans de nombreux contextes. Par exemple, dans *Murdoch*, le juge Laskin (plus tard Juge en chef), en dissidence, aurait imposé une fiducie constructive, au motif que les faits étaient « compatibles avec une mise en commun, par les conjoints, d’efforts » destinés à réaliser leur établissement dans une exploitation d’élevage (p. 457), et que les conjoints avaient travaillé ensemble pendant quinze ans dans le but d’améliorer « leur sort en faisant des acquisitions toujours plus grandes de biens de ranch » (p. 446). De même, dans *Rathwell*, les juges majoritaires ont convenu que M. et M^{me} Rathwell avaient uni leurs efforts pour accumuler une richesse. Le juge Dickson a souligné que les parties avaient décidé ensemble « de faire de l’agriculture » (p. 444) et que seuls un « effort conjoint » et un « travail d’équipe » ont permis à M. Rathwell d’acquérir en son propre nom des propriétés (p. 461).

[64] C’est également ce qu’a reconnu la Cour dans *Pettkus* et dans *Peter*.

[65] Dans *Pettkus*, les parties avaient mis sur pied une exploitation apicole prospère, dont les profits avaient servi à acquérir des immeubles. Le juge Dickson, rédigeant pour la majorité, a souligné les faits qui indiquaient une relation conjugale et financière entre partenaires. Il a fait remarquer qu’« ils sont tous deux partis de rien; chacun a travaillé continuellement, assidûment et diligemment

to the “good fortune of the common enterprise” (p. 838); that Wilson J.A. (as she then was) at the Court of Appeal had found the wealth they accumulated was through “joint effort” and “teamwork” (p. 849); and finally, that “[t]heir lives and their economic well-being were fully integrated” (p. 850).

[66] I agree with Professor McCamus that the Court in *Pettkus* was “satisfied that the parties were engaged in a common venture in which they expected to share the benefits flowing from the wealth that they jointly created” (p. 367). Put another way, Mr. Pettkus was not unjustly enriched because Ms. Becker had a precise expectation of obtaining a legal interest in certain properties, but rather because they were in reality partners in a common venture.

[67] The significance of the fact that wealth had been acquired through joint effort was again at the forefront of the analysis in *Peter* where the parties lived together for 12 years in a common law relationship. While Mr. Beblow generated most of the family income and also contributed to the maintenance of the property, Ms. Peter did all of the domestic work (including raising the six children of their blended family), helped with property maintenance, and was solely responsible for the property when Mr. Beblow was away. The reality of their joint venture was acknowledged when McLachlin J. wrote that the “joint family venture, in effect, was no different from the farm which was the subject of the trust in *Pettkus v. Becker*” (p. 1001).

[68] The Court’s recognition of the joint family venture is evident in three other places in *Peter*. First, in reference to the appropriateness of the “value survived” measure of relief, McLachlin J. observed, “it is more likely that a couple expects to share in the wealth generated from their partnership, rather than to receive compensation for the services performed during the relationship” (p. 999). Second, and also related to valuing the extent of the unjust enrichment, McLachlin J. noted that,

à l’entreprise conjointe » (p. 853); que chacun a contribué « à la réussite de l’entreprise commune » (p. 838); que la juge Wilson (plus tard juge de notre Cour) de la Cour d’appel avait conclu que leur richesse avait été accumulée grâce à un « effort conjoint » et à un « travail d’équipe » (p. 849); et enfin, que « [l]eur vie et leur bien-être économique étaient entièrement intégrés » (p. 850).

[66] Je suis d’accord avec le professeur McCamus pour dire que la Cour, dans *Pettkus*, était [TRADUCTION] « convaincue que les parties participaient à une entreprise commune et s’attendaient à partager les avantages découlant de la richesse qu’elles ont créée ensemble » (p. 367). Autrement dit, M. Pettkus ne s’est pas injustement enrichi parce que M^{me} Becker s’attendait précisément à obtenir un droit sur certains biens, mais plutôt parce qu’ils étaient en réalité partenaires d’une entreprise commune.

[67] Le fait que les biens aient été acquis grâce à un effort conjoint était encore une fois au premier plan de l’analyse dans *Peter*. Dans cette affaire, les parties ont vécu en union de fait pendant 12 ans. Bien que M. Beblow ait généré la majeure partie du revenu familial et ait aussi contribué à l’entretien de la propriété, M^{me} Peter s’est chargée des travaux domestiques (y compris l’éducation des six enfants des deux familles réunies), elle a aidé à l’entretien et elle s’est occupée de la propriété toute seule lorsque M. Beblow était absent. La juge McLachlin a reconnu la réalité de leur coentreprise lorsqu’elle a écrit : « En effet, cette coentreprise familiale n’est pas différente de la ferme qui a été grevée d’une fiducie dans l’arrêt *Pettkus c. Becker* » (p. 1001).

[68] La Cour a clairement reconnu la coentreprise familiale à trois autres reprises dans *Peter*. Premièrement, au sujet de la justesse de la méthode de calcul de l’indemnité fondée sur la « valeur accumulée », la juge McLachlin fait remarquer qu’« un couple s’attendra davantage à participer à la richesse générée par la relation qu’à être indemnisé des services rendus pendant la durée de la relation » (p. 999). Deuxièmement, et aussi en ce qui concerne l’indemnité à accorder

in a case where both parties had contributed to the “family venture”, it was appropriate to look to all of the family assets, rather than simply one of them, to approximate the value of the claimant’s contributions to that family venture (p. 1001). Third, the Court’s justification for affirming the value of domestic services was, in part, based on reasoning that such services are often proffered in the context of a common venture (p. 993).

[69] Relationships of this nature are common in our life experience. For many domestic relationships, the couple’s venture may only sensibly be viewed as a joint one, making it highly artificial in theory and extremely difficult in practice to do a detailed accounting of the contributions made and benefits received on a fee-for-services basis. Of course, this is a relationship-specific issue; there can be no presumption one way or the other. However, the legal consequences of the breakdown of a domestic relationship should reflect realistically the way people live their lives. It should not impose on them the need to engage in an artificial balance sheet approach which does not reflect the true nature of their relationship.

(b) *Flexibility*

[70] Maintaining a strict remedial dichotomy is inconsistent with the Court’s approach to equitable remedies in general, and to its development of remedies for unjust enrichment in particular.

[71] The Court has often emphasized the flexibility of equitable remedies and the need to fashion remedies that respond to various situations in principled and realistic ways. So, for example, when speaking of equitable compensation for breach of confidence, Binnie J. affirmed that “the Court has ample jurisdiction to fashion appropriate relief out of the full gamut of available remedies, including appropriate financial compensation”: *Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods Ltd.*,

pour enrichissement injustifié, la juge McLachlin a souligné que, lorsque les deux parties contribuent à la « coentreprise familiale », il faut examiner l’ensemble de l’avoir familial, et non un seul bien, pour déterminer la valeur approximative de la contribution du demandeur à l’avoir familial (p. 1001). Troisièmement, la justification de la Cour au sujet de la confirmation de la valeur des services domestiques reposait, en partie, sur le raisonnement voulant que ces services soient souvent rendus dans le contexte d’une entreprise commune (p. 993).

[69] Les relations de cette nature sont chose commune dans notre société. Dans de nombreux cas, la seule conclusion raisonnable est de considérer le couple comme une entreprise conjointe, de sorte qu’il est hautement artificiel en théorie et extrêmement difficile en pratique de faire un bilan détaillé des contributions apportées et des avantages reçus en fonction de la rémunération des services rendus. Bien entendu, chaque relation est particulière et on ne peut rien présumer dans un sens ou dans l’autre. Cependant, les conséquences juridiques de la rupture d’une relation conjugale devraient refléter la façon dont les gens vivent. Elles ne devraient pas les forcer à recourir à une approche comptable artificielle, qui ne reflète pas la véritable nature de leur relation.

b) *Souplesse*

[70] Maintenir une dichotomie stricte des mesures de réparation est incompatible avec l’approche de la Cour à l’égard des réparations en equity en général et à l’égard de l’élaboration de réparations en cas d’enrichissement injustifié en particulier.

[71] La Cour a souvent souligné la souplesse des réparations en equity et la nécessité d’établir des réparations raisonnées et réalistes, adaptées aux diverses situations. Par exemple, à propos de l’indemnité en equity en matière d’abus de confiance, le juge Binnie a affirmé que « la Cour a largement compétence pour établir la réparation appropriée à partir de la gamme complète des réparations disponibles, dont une indemnité pécuniaire adéquate » : *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*,

[1999] 1 S.C.R. 142, at para. 61. At para. 24, he noted the broad approach to equitable remedies for breach of confidence taken by the Court in *Lac Minerals*. In doing so, he cited this statement with approval: “. . . the remedy that follows [once liability is established] should be the one that is most appropriate on the facts of the case rather than one derived from history or over-categorization” (from J. D. Davies, “Duties of Confidence and Loyalty”, [1990] *L.M.C.L.Q.* 4, at p. 5). Similarly, in the context of the constructive trust, McLachlin J. (as she then was) noted that “[e]quitable remedies are flexible; their award is based on what is just in all the circumstances of the case”: *Soulos v. Korkontzilas*, [1997] 2 S.C.R. 217, at para. 34.

[72] Turning specifically to remedies for unjust enrichment, I refer to Binnie J.’s comments in *Pacific National Investments Ltd. v. Victoria (City)*, 2004 SCC 75, [2004] 3 S.C.R. 575, at para. 13. He noted that the doctrine of unjust enrichment, while predicated on clearly defined principles, “retains a large measure of remedial flexibility to deal with different circumstances according to principles rooted in fairness and good conscience”. Moreover, the Court has recognized that, given the wide variety of circumstances addressed by the traditional categories of unjust enrichment, as well as the flexibility of the broader, principled approach, its development has been characterized by, and indeed requires, recourse to a number of different sorts of remedies depending on the circumstances: see *Peter*, at p. 987; *Sorochan*, at p. 47.

[73] Thus, the remedy should mirror the flexibility inherent in the unjust enrichment principle itself, so as to allow the court to respond appropriately to the substance of the problem put before it. This means that a monetary remedy must match, as best it can, the extent of the enrichment unjustly retained by the defendant. There is no reason to think that the wide range of circumstances that may give rise to unjust enrichment claims will necessarily fall into one or the other of the two

[1999] 1 R.C.S. 142, par. 61. Au paragraphe 24, il a souligné l’approche libérale à l’égard des réparations en equity dans les cas d’abus de confiance adoptée par la Cour dans *Lac Minerals*. Ce faisant, il a cité et approuvé l’extrait suivant : « . . . la réparation à accorder [une fois qu’un motif de responsabilité est établi] devrait donc être celle qui est la plus appropriée compte tenu des faits de l’affaire plutôt qu’une réparation résultant du passé ou d’une multiplication des catégories » (tiré de J. D. Davies, « Duties of Confidence and Loyalty », [1990] *L.M.C.L.Q.* 4, p. 5). De même, dans le contexte d’une fiducie constructive, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a dit que « [l]es réparations reconnues en equity sont souples; elles sont accordées en fonction de ce qui est juste compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce » : *Soulos c. Korkontzilas*, [1997] 2 R.C.S. 217, par. 34.

[72] Quant aux réparations pour enrichissement injustifié, je reprends les propos du juge Binnie dans *Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville)*, 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575, au par. 13. Il a fait remarquer que l’enrichissement injustifié, qui se fonde sur des principes clairement définis, « offre une grande souplesse dans les réparations susceptibles d’être accordées dans différentes circonstances selon des principes fondés sur l’équité et la bonne conscience ». De plus, la Cour a reconnu que, compte tenu de la grande variété de situations relevant des catégories traditionnelles de l’enrichissement injustifié et de la souplesse de l’approche plus générale et raisonnée, le principe suppose, et en fait exige, qu’on ait recours à différents types de réparation selon les circonstances : voir *Peter*, p. 987; *Sorochan*, p. 47.

[73] Ainsi, la réparation devrait refléter la souplesse inhérente au principe de l’enrichissement injustifié, de façon à permettre à la cour de trouver une réponse appropriée au problème dont elle est saisie. Cela signifie qu’une réparation pécuniaire doit correspondre, autant que possible, à la mesure de l’enrichissement injustifié du défendeur. Il n’y a aucune raison de penser que le vaste éventail des situations pouvant donner ouverture à l’action pour enrichissement injustifié tomberont nécessairement

remedial options into which some have tried to force them.

(c) *History*

[74] Imposing a strict remedial dichotomy is also inconsistent with the historical development of the unjust enrichment principle. Unjust enrichment developed through several particular categories of cases. *Quantum meruit*, the origin of the fee-for-services award, was only one of them. *Quantum meruit* originated as a common law claim for compensation for benefits conferred under an agreement which, while apparently binding, was rendered ineffective for a reason recognized at common law. The scope of the claim was expanded over time, and the measure of a *quantum meruit* award was flexible. It might be assessed, for example, by the cost to the plaintiff of providing the service, the market value of the benefit, or even the value placed on the benefit by the recipient: P. D. Maddaugh and J. D. McCamus, *The Law of Restitution* (loose-leaf ed.), vol. I, at §4:200.30. The important point, however, is that *quantum meruit* is simply one of the established categories of unjust enrichment claims. There is no reason in principle why one of the traditional categories of unjust enrichment should be used to force the monetary remedy for all present domestic unjust enrichment cases into a remedial straitjacket.

(d) *Peter v. Beblow*

[75] *Peter* does not mandate strict adherence to a *quantum meruit* approach to money remedies for unjust enrichment. One must remember that the focus of *Peter* was on whether the plaintiff's contributions entitled her to a constructive trust over the former family home. While it was assumed by both McLachlin J. and Cory J., who wrote concurring reasons in the case, that a money award would be fashioned on the basis of *quantum meruit*, that was not an issue, let alone a holding, in the case.

dans l'une ou l'autre des deux catégories de réparations possibles, où d'aucuns ont voulu les faire entrer.

c) *Historique*

[74] Imposer une dichotomie stricte des mesures de réparation est aussi incompatible avec l'évolution historique du principe de l'enrichissement injustifié, lequel a été élaboré à partir de catégories particulières de cas, dont le *quantum meruit*, qui est à l'origine de la réparation fondée sur la rémunération des services rendus. Le *quantum meruit* tire son origine d'une demande d'indemnisation en common law pour les avantages conférés en vertu d'une entente qui, malgré qu'elle semblait lier les parties, est devenue inopérante pour une raison reconnue en common law. La portée du recours a été élargie au fil du temps, et l'appréciation du *quantum meruit* était souple. Il peut équivaloir, par exemple, à ce qu'il en coûte au demandeur pour fournir le service, à la valeur marchande de l'avantage ou encore à la valeur que le bénéficiaire accorde à l'avantage : P. D. Maddaugh et J. D. McCamus, *The Law of Restitution* (éd. feuilles mobiles), vol. I, §4:200.30. Cependant, il est important de souligner que le *quantum meruit* n'est qu'une des catégories établies d'action pour enrichissement injustifié. Rien ne justifie, en principe, qu'une catégorie traditionnelle d'enrichissement injustifié serve à imposer la réparation pécuniaire dans tous les cas d'enrichissement injustifié entre conjoints de fait.

d) *L'arrêt Peter c. Beblow*

[75] L'arrêt *Peter* ne commande pas une stricte adhésion à la méthode du *quantum meruit* pour le calcul de la réparation en matière d'enrichissement injustifié. Il faut se rappeler que cette affaire portait essentiellement sur la question de savoir si les contributions de la demanderesse lui donnaient droit à une fiducie constructive à l'égard de l'ancienne demeure familiale. Bien que les juges McLachlin et Cory, auteurs des motifs concourants de l'arrêt, aient supposé qu'une réparation pécuniaire serait établie en fonction du *quantum meruit*, ce point n'était pas en litige et n'a pas davantage fait l'objet d'une conclusion.

[76] There are, in fact, only two sentences in the judgments that could be taken as supporting the view that this rule should always apply. At p. 995, McLachlin J. said, “Two remedies are possible: an award of money on the basis of the value of the services rendered, i.e. *quantum meruit*; and the one the trial judge awarded, title to the house based on a constructive trust”; at p. 999, she wrote that “[f]or a monetary award, the ‘value received’ approach is appropriate”. Given that the focus of the case was deciding whether a proprietary remedy was appropriate, I would not read these two brief passages as laying down the sweeping rule that a monetary award must always be calculated on a fee-for-services basis.

[77] Moreover, McLachlin J. noted that the doctrine of unjust enrichment applies to a variety of situations, and that successful claims have been addressed through a number of remedies, depending on the circumstances. Only one of these remedies is a payment for services rendered on the basis of *quantum meruit*: p. 987. There is nothing in this observation to suggest that the Court decided to opt for a one-size-fits-all monetary remedy, especially when such an approach would be contrary to the very flexibility that the Court has repeatedly affirmed with regards to the law of unjust enrichment and corresponding remedies.

[78] This restrictive reading of *Peter* is not consistent with the underlying nature of the claim founded on the principles set out in *Pettkus*. As Professor McCamus has suggested, cases like *Pettkus* rest on a claimant’s right to share surplus wealth created by joint effort and teamwork. It follows that a remedy based on notional fees for services is not responsive to the underlying nature of that claim: McCamus, at pp. 376-77. In my view, this reasoning is persuasive whether the joint effort has led to the accumulation of specific property, in which case a remedial constructive trust may be appropriate according to the well-settled principles in that area of trust law, or where the joint effort has led to an accumulation of assets generally. In the

[76] En fait, seules deux phrases dans les jugements paraissent appuyer le point de vue selon lequel cette règle devrait toujours s’appliquer. À la page 995, la juge McLachlin a affirmé : « [i]l y a deux réparations possibles : une indemnité calculée en fonction de la valeur des services rendus, c’est-à-dire le *quantum meruit* et celle accordée par le juge de première instance, soit le titre de propriété sur la maison, fondée sur une fiducie par interprétation ». À la page 999, elle a écrit que « [d]ans le cas du versement d’une indemnité, il convient d’utiliser la méthode fondée sur la “valeur reçue” ». Comme l’arrêt portait sur la question de savoir si une réparation fondée sur le droit de propriété était appropriée, ces deux courts passages ne posent pas, à mon avis, comme règle absolue qu’une réparation pécuniaire doit toujours être calculée en fonction de la rémunération des services rendus.

[77] De plus, la juge McLachlin a souligné que le principe de l’enrichissement injustifié s’appliquait à diverses situations et que différentes réparations avaient été accordées, selon les circonstances. Seule l’une d’elles était le paiement pour services rendus sur la base du *quantum meruit* : p. 987. Rien dans ses propos n’indique que la Cour ait décidé d’opter pour une réparation pécuniaire universelle, surtout lorsqu’une telle approche serait contraire à la souplesse des règles de l’enrichissement injustifié et des réparations correspondantes, que la Cour a maintes fois reconnue.

[78] Cette interprétation restrictive de l’arrêt *Peter* n’est pas compatible avec la nature sous-jacente de l’action fondée sur les principes énoncés dans *Pettkus*. Comme l’a dit le professeur McCamus, les affaires de type *Pettkus* reposent sur le droit du demandeur de partager la richesse créée par un effort conjoint et un travail d’équipe. Ainsi, une réparation fondée sur des honoraires théoriques pour des services rendus n’est pas adaptée à la nature sous-jacente de la demande : McCamus, p. 376-377. À mon avis, ce raisonnement est convaincant, que l’effort conjoint ait donné lieu à l’accumulation de biens en particulier, auquel cas une fiducie constructrice de nature réparatoire peut être appropriée selon les principes bien établis dans

latter instance, when appropriate, there is no reason in principle why a monetary remedy cannot be fashioned to reflect this basis of the enrichment and corresponding deprivation. What is essential, in my view, is that, in either type of case, there must be a link between the contribution and the accumulation of wealth, or to use the words of McLachlin J. in *Peter*, between the “value received” and the “value surviving”. Where that link exists, and a proprietary remedy is either inappropriate or unnecessary, the monetary award should be fashioned to reflect the true nature of the enrichment and the corresponding deprivation.

[79] Professor McCamus has suggested that the equitable remedy of an accounting of profits could be an appropriate remedial tool: p. 377. While I would not discount that as a possibility, I doubt that the complexity and technicality of that remedy would be well suited to domestic situations, which are more often than not rather straightforward. The unjust enrichment principle is inherently flexible and, in my view, the calculation of a monetary award for a successful unjust enrichment claim should be equally flexible. This is necessary to respond, to the extent money can, to the particular enrichment being addressed. To my way of thinking, Professor Fridman was right to say that “where a claim for unjust enrichment has been made out by the plaintiff, the court may award whatever form of relief is most appropriate so as to ensure that the plaintiff obtains that to which he or she is entitled, regardless of whether the situation would have been governed by common law or equitable doctrines or whether the case would formerly have been considered one for a personal or a proprietary remedy” (p. 398).

(4) The Approach to the Monetary Remedy

[80] The next step in the legal development of this area should be to move away from the false remedial dichotomy between *quantum meruit* and

ce domaine du droit des fiducies, ou que l'effort conjoint ait donné lieu à l'accumulation de richesse en général. Dans le second cas, lorsque la situation s'y prête, il n'y a en principe aucune raison de refuser une réparation pécuniaire basée sur l'enrichissement et l'appauvrissement correspondant. À mon avis, il est essentiel, dans l'un et l'autre cas, qu'il y ait un lien entre la contribution et l'accumulation de la richesse ou, pour reprendre les propos de la juge McLachlin dans *Peter*, entre la « valeur reçue » et la « valeur accumulée ». Lorsque ce lien est établi, et qu'une réparation fondée sur le droit de propriété est inappropriée ou inutile, la réparation pécuniaire devrait être adaptée pour refléter la nature véritable de l'enrichissement et de l'appauvrissement correspondant.

[79] Le professeur McCamus a avancé que la réparation en equity que constitue la reddition de compte relative aux profits pourrait s'avérer un remède approprié : p. 377. Bien que je ne nie pas cette possibilité, je doute que la complexité et les subtilités procédurales de cette réparation soient adaptées aux situations familiales, lesquelles sont, la plupart du temps, assez simples. Le principe de l'enrichissement injustifié est fondamentalement souple et, à mon avis, le calcul d'une indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié devrait être tout aussi souple. Cela est nécessaire pour répondre à l'enrichissement en question, dans la mesure où une somme d'argent peut le faire. À mon sens, le professeur Fridman avait raison de dire que [TRADUCTION] « dans les cas où le demandeur a démontré l'enrichissement injustifié, la cour peut accorder la réparation la plus appropriée de manière à faire en sorte que le demandeur obtienne ce à quoi il a droit, indépendamment de la question de savoir si la situation aurait été du ressort de la common law ou de l'equity ou si elle aurait autrefois donné ouverture à une réparation personnelle ou fondée sur le droit de propriété » (p. 398).

(4) L'approche applicable en matière de réparation pécuniaire

[80] L'étape suivante de l'évolution jurisprudentielle devrait consister à s'éloigner de la fausse dichotomie entre le *quantum meruit* et la fiducie

constructive trust, and to return to the underlying principles governing the law of unjust enrichment. These underlying principles focus on properly characterizing the nature of the unjust enrichment giving rise to the claim. As I have mentioned above, not all unjust enrichments arising between domestic partners fit comfortably into either a “fee-for-services” or “a share of specific property” mold. Where the unjust enrichment is best characterized as an unjust retention of a disproportionate share of assets accumulated during the course of what McLachlin J. referred to in *Peter* (at p. 1001) as a “joint family venture” to which both partners have contributed, the monetary remedy should reflect that fact.

[81] In such cases, the basis of the unjust enrichment is the retention of an inappropriately disproportionate amount of wealth by one party when the parties have been engaged in a joint family venture and there is a clear link between the claimant’s contributions to the joint venture and the accumulation of wealth. Irrespective of the status of legal title to particular assets, the parties in those circumstances are realistically viewed as “creating wealth in a common enterprise that will assist in sustaining their relationship, their well-being and their family life” (McCamus, at p. 366). The wealth created during the period of cohabitation will be treated as the fruit of their domestic and financial relationship, though not necessarily by the parties in equal measure. Since the spouses are domestic and financial partners, there is no need for “dueling *quantum meruits*”. In such cases, the unjust enrichment is understood to arise because the party who leaves the relationship with a disproportionate share of the wealth is denying to the claimant a reasonable share of the wealth accumulated in the course of the relationship through their joint efforts. The monetary award for unjust enrichment should be assessed by determining the proportionate contribution of the claimant to the accumulation of the wealth.

[82] This flexible approach to the money remedy in unjust enrichment cases is fully consistent with

constructoire, pour revenir aux principes qui sous-tendent les règles relatives à l’enrichissement injustifié. Ces principes portent principalement sur la qualification appropriée de la nature de l’enrichissement injustifié à l’origine de la réclamation. Comme je l’ai déjà dit, tous les enrichissements injustifiés entre conjoints non mariés ne se rangent pas aisément dans la catégorie de la « rémunération des services rendus » ou dans celle relative à « une partie d’un bien déterminé ». Dans les cas où la meilleure façon de qualifier l’enrichissement injustifié est de le considérer comme une rétention injuste d’une part disproportionnée des biens accumulés dans le cadre de ce que la juge McLachlin a appelé, dans *Peter* (p. 1001), une « coentreprise familiale » à laquelle les deux conjoints ont contribué, la réparation pécuniaire devrait refléter ce fait.

[81] Dans de tels cas, le fondement de l’enrichissement injustifié est la rétention d’une part excessive et disproportionnée de la richesse par une partie quand les deux parties ont participé à une coentreprise familiale et qu’il existe un lien évident entre les contributions du demandeur et l’accumulation de la richesse. Indépendamment du titulaire du titre de propriété sur certains biens déterminés, on peut considérer que les parties, dans de telles circonstances, [TRADUCTION] « créent la richesse dans le cadre d’une entreprise commune qui les aidera à maintenir leur relation, leur bien-être et leur vie de famille » (McCamus, p. 366). La richesse créée durant la période de cohabitation sera considérée comme étant le fruit de leur relation conjugale et financière, sans nécessairement que les deux parties y aient contribué en parts égales. Comme les conjoints sont des partenaires conjugaux et financiers, il n’est nul besoin d’un « duel de *quantum meruit* ». Dans de tels cas, l’allégation d’enrichissement injustifié naît de ce que la partie qui quitte avec une part disproportionnée de la richesse prive le demandeur d’une part raisonnable de la richesse accumulée pendant la relation grâce à leurs efforts conjoints. Il faudrait évaluer la réparation pécuniaire en déterminant la contribution proportionnée du demandeur à l’accumulation de la richesse.

[82] Cette souplesse dans la détermination de la réparation pécuniaire dans les cas d’enrichissement

Walsh. While that case was focused on constitutional issues that are not before us in this case, the majority judgment was clearly not intended to freeze the law of unjust enrichment in domestic cases; the judgment indicates that the law of unjust enrichment, including the remedial constructive trust, is the preferable method of responding to the inequities brought about by the breakdown of a common law relationship, since the remedies for unjust enrichment “are tailored to the parties’ specific situation and grievances” (para. 61). In short, while emphasizing respect for autonomy as an important value, the Court at the same time approved of the continued development of the law of unjust enrichment in order to respond to the plethora of forms and functions of common law relationships.

[83] A similar approach was taken in *Peter*. Mr. Beblow argued that the law of unjust enrichment should not provide a share of property to unmarried partners because the legislature had chosen to exclude them from the rights accorded to married spouses under matrimonial property legislation. This argument was succinctly — and flatly — rejected with the remark that it is “precisely where an injustice arises without a legal remedy that equity finds a role”: p. 994.

[84] It is not the purpose of the law of unjust enrichment to replicate for unmarried partners the legislative presumption that married partners are engaged in a joint family venture. However, there is no reason in principle why remedies for unjust enrichment should fail to reflect that reality in the lives and relationships of unmarried partners.

[85] I conclude, therefore, that the common law of unjust enrichment should recognize and respond to the reality that there are unmarried domestic arrangements that are partnerships; the remedy in such cases should address the disproportionate retention of assets acquired through joint efforts

injustifié est tout à fait conforme à l’arrêt *Walsh*. Même si cette affaire soulevait des questions constitutionnelles dont nous ne sommes pas saisis en l’espèce, le jugement majoritaire ne cherchait manifestement pas à figer les règles relatives à l’enrichissement injustifié en matière familiale; l’arrêt indique que ces règles, y compris la fiducie constructive de nature réparatoire, constituent la meilleure façon de remédier aux iniquités susceptibles de survenir au moment de la rupture d’une union de fait puisque la réparation pour enrichissement injustifié « est adaptée à la situation et aux revendications particulières des parties » (par. 61). En résumé, tout en soulignant l’importance du respect de l’autonomie, la Cour a reconnu que les règles relatives à l’enrichissement injustifié devaient toujours évoluer pour s’adapter à la myriade de formes et fonctions des unions de fait.

[83] Une approche semblable a été appliquée dans *Peter*. Monsieur Beblow soutenait que les conjoints non mariés ne devaient pas se voir attribuer une part des biens en vertu des règles de l’enrichissement injustifié parce que le législateur avait choisi de ne pas leur accorder les droits conférés aux conjoints mariés en vertu de la législation sur les biens matrimoniaux. La Cour a laconiquement — et catégoriquement — rejeté cet argument en affirmant que c’est « précisément dans les cas où une injustice ne peut pas être réparée en vertu de la loi que l’*equity* joue un rôle » : p. 994.

[84] Les règles relatives à l’enrichissement injustifié ne visent pas à reproduire, pour les conjoints non mariés, la présomption législative voulant que les conjoints mariés soient associés dans une coentreprise familiale. Cependant, rien ne s’oppose en principe à ce que les réparations applicables en cas d’enrichissement injustifié ne tiennent pas compte de cette réalité dans la vie et les relations des conjoints non mariés.

[85] Je conclus donc que les règles de la common law relatives à l’enrichissement injustifié devraient reconnaître et prendre en compte cette réalité, à savoir que certaines ententes conjugales conclues entre conjoints non mariés sont des partenariats; dans de tels cas, la réparation devrait remédier à la

with another person. This sort of sharing, of course, should not be presumed, nor will it be presumed that wealth acquired by mutual effort will be shared equally. Cohabitation does not, in itself, under the common law of unjust enrichment, entitle one party to a share of the other's property or any other relief. However, where wealth is accumulated as a result of joint effort, as evidenced by the nature of the parties' relationship and their dealings with each other, the law of unjust enrichment should reflect that reality.

[86] Thus the rejection of the remedial dichotomy leads us to consider in what circumstances an unjust enrichment may be appropriately characterized as a failure to share equitably assets acquired through the parties' joint efforts. While this approach will need further refinement in future cases, I offer the following as a broad outline of when this characterization of an unjust enrichment will be appropriate.

(5) Identifying Unjust Enrichment Arising From a Joint Family Venture

[87] My view is that when the parties have been engaged in a joint family venture, and the claimant's contributions to it are linked to the generation of wealth, a monetary award for unjust enrichment should be calculated according to the share of the accumulated wealth proportionate to the claimant's contributions. In order to apply this approach, it is first necessary to identify whether the parties have, in fact, been engaged in a joint family venture. In the preceding section, I reviewed the many occasions on which the existence of a joint family venture has been recognized. From this rich set of factual circumstances, what emerge as the hallmarks of such a relationship?

[88] It is critical to note that cohabiting couples are not a homogeneous group. It follows that the analysis must take into account the particular circumstances of each particular relationship.

rétention disproportionnée des avoirs acquis avec une autre personne grâce aux efforts conjoints. Évidemment, ce genre de partage ne doit pas être présumé, non plus qu'il sera présumé que la richesse accumulée grâce à l'effort des deux conjoints sera partagée également. Suivant les règles de la common law relatives à l'enrichissement injustifié, la cohabitation, en soi, ne confère pas à une personne le droit à une part des biens de l'autre personne ou à toute autre forme de réparation. Toutefois, lorsqu'une certaine richesse a été accumulée grâce à un effort conjoint, comme en témoigne la nature de la relation des parties et leurs rapports réciproques, le droit de l'enrichissement injustifié devrait refléter cette réalité.

[86] Par conséquent, le rejet de la dichotomie des mesures de réparation nous amène à examiner les circonstances dans lesquelles un enrichissement injustifié peut être considéré comme le résultat d'un partage inéquitable des biens acquis grâce aux efforts conjoints des parties. Il faudra certes raffiner cette approche, mais voici un aperçu des cas où cette qualification sera appropriée.

(5) Enrichissement injustifié découlant d'une coentreprise familiale

[87] Selon moi, quand les parties ont été engagées dans une coentreprise familiale, et que les contributions du demandeur sont liées à l'accumulation de la richesse, il convient de calculer une indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié en fonction de la part proportionnelle de la contribution du demandeur à cette accumulation de la richesse. Pour appliquer cette approche, il faut d'abord déterminer si les parties ont, de fait, été engagées dans une coentreprise familiale. Dans la partie précédente, j'ai passé en revue les nombreuses occasions où l'existence d'une coentreprise familiale a été reconnue. De cet ensemble de faits bien étoffé, à quoi peut-on reconnaître les marques distinctives d'une telle relation?

[88] Il est essentiel de souligner que les couples qui cohabitent ne forment pas un groupe homogène. Par conséquent, l'analyse doit tenir compte des circonstances particulières de chaque relation.

Furthermore, as previously stated, there can be no presumption of a joint family venture. The goal is for the law of unjust enrichment to attach just consequences to the way the parties have lived their lives, not to treat them as if they ought to have lived some other way or conducted their relationship on some different basis. A joint family venture can only be identified by the court when its existence, in fact, is well grounded in the evidence. The emphasis should be on how the parties actually lived their lives, not on their *ex post facto* assertions or the court's view of how they ought to have done so.

[89] In undertaking this analysis, it may be helpful to consider the evidence under four main headings: mutual effort, economic integration, actual intent and priority of the family. There is, of course, overlap among factors that may be relevant under these headings and there is no closed list of relevant factors. What follows is not a checklist of conditions for finding (or not finding) that the parties were engaged in a joint family venture. These headings, and the factors grouped under them, simply provide a useful way to approach a global analysis of the evidence and some examples of the relevant factors that may be taken into account in deciding whether or not the parties were engaged in a joint family venture. The absence of the factors I have set out, and many other relevant considerations, may well negate that conclusion.

(a) *Mutual Effort*

[90] One set of factors concerns whether the parties worked collaboratively towards common goals. Indicators such as the pooling of effort and team work, the decision to have and raise children together, and the length of the relationship may all point towards the extent, if any, to which the parties have formed a true partnership and jointly worked towards important mutual goals.

[91] Joint contributions, or contributions to a common pool, may provide evidence of joint effort. For instance, in *Murdoch*, central to Laskin J.'s

De plus, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas présumer l'existence d'une coentreprise familiale. Il s'agit donc d'attacher des conséquences équitables à la façon dont les parties ont vécu, de ne pas les traiter comme si elles auraient dû vivre autrement ou établir leur relation sur une base différente. L'existence d'une coentreprise familiale ne peut être reconnue par la cour que lorsqu'elle est, en fait, bien appuyée par la preuve. L'accent devrait porter sur la façon dont les parties ont réellement vécu, et non sur leurs allégations *ex post facto* ou sur l'opinion de la cour quant à la façon dont elles auraient dû vivre.

[89] Pour procéder à cette analyse, il peut être utile d'examiner la preuve sous quatre rubriques principales : l'effort commun, l'intégration économique, l'intention réelle et la priorité accordée à la famille. De toute évidence, il y a un chevauchement des facteurs qui pourraient se révéler pertinents sous ces rubriques et la liste de ces facteurs n'est pas définitive. Ce qui suit n'est pas une liste des conditions requises pour pouvoir conclure (ou ne pas conclure) que les parties étaient engagées dans une coentreprise familiale. Ces rubriques, et les facteurs qui y sont regroupés, servent simplement à faciliter l'analyse globale de la preuve et à donner quelques exemples d'éléments à prendre en considération pour décider si les parties étaient engagées dans une coentreprise familiale. L'absence de ces facteurs, et plusieurs autres considérations pertinentes, pourrait fort bien écarter cette conclusion.

a) *Effort commun*

[90] Le premier ensemble de facteurs porte sur la question de savoir si les parties collaboraient en vue d'atteindre des buts communs. Les efforts conjoints et le travail d'équipe, la décision d'avoir et d'éduquer des enfants ensemble, ainsi que la durée de la relation peuvent tous indiquer la mesure dans laquelle, le cas échéant, les parties constituaient véritablement une association et ont collaboré à la réalisation d'objectifs communs importants.

[91] Les contributions conjointes, ou les contributions à un fonds commun, peuvent constituer la preuve d'un effort conjoint. Par exemple, dans

constructive trust analysis was that the parties had pooled their efforts to establish themselves in a ranch operation. Joint contributions were also an important aspect of the Court's analyses in *Peter, Sorochan*, and *Pettkus*. Pooling of efforts and resources, whether capital or income, has also been noted in the appellate case law (see, e.g., *Birmingham v. Ferguson*, 2004 CanLII 4764 (Ont. C.A.); *McDougall v. Gesell Estate*, 2001 MBCA 3, 153 Man. R. (2d) 54, at para. 14). The use of parties' funds entirely for family purposes may be indicative of the pooling of resources: *McDougall*. The parties may also be said to be pooling their resources where one spouse takes on all, or a greater proportion, of the domestic labour, freeing the other spouse from those responsibilities, and enabling him or her to pursue activities in the paid workforce (see *Nasser v. Mayer-Nasser* (2000), 5 R.F.L. (5th) 100 (Ont. C.A.); *Panara v. Di Ascenzo*, 2005 ABCA 47, 361 A.R. 382, at para. 27).

(b) *Economic Integration*

[92] Another group of factors, related to those in the first group, concerns the degree of economic interdependence and integration that characterized the parties' relationship (*Birmingham*; *Pettkus*; *Nasser*). The more extensive the integration of the couple's finances, economic interests and economic well-being, the more likely it is that they should be considered as having been engaged in a joint family venture. For example, the existence of a joint bank account that was used as a "common purse", as well as the fact that the family farm was operated by the family unit, were key factors in Dickson J.'s analysis in *Rathwell*. The sharing of expenses and the amassing of a common pool of savings may also be relevant considerations (see *Wilson*; *Panara*).

[93] The parties' conduct may further indicate a sense of collectivity, mutuality, and prioritization of the overall welfare of the family unit over

Murdoch, le fait que les parties avaient uni leurs efforts dans le but de réaliser leur établissement dans une exploitation d'élevage était au cœur de l'analyse du juge Laskin sur la fiducie constructive. Les contributions conjointes sont aussi un aspect important des analyses de la Cour dans *Peter, Sorochan* et *Pettkus*. La mise en commun des efforts et des ressources, à titre de capital ou de revenu, a également été soulignée dans des affaires jugées en appel (voir, par exemple, *Birmingham c. Ferguson*, 2004 CanLII 4764 (C.A. Ont.); *McDougall c. Gesell Estate*, 2001 MBCA 3, 153 Man. R. (2d) 54, par. 14). Le fait que les fonds des parties soient entièrement consacrés à la famille peut indiquer une mise en commun des ressources : *McDougall*. On peut aussi affirmer que les parties mettent leurs ressources en commun quand un conjoint s'acquitte de la totalité, ou de la plus grande partie, des travaux domestiques, libérant l'autre de ces responsabilités et lui permettant de se consacrer à ses activités rémunérées à l'extérieur (voir *Nasser c. Mayer-Nasser* (2000), 5 R.F.L. (5th) 100 (C.A. Ont.), et *Panara c. Di Ascenzo*, 2005 ABCA 47, 361 A.R. 382, par. 27).

b) *Intégration économique*

[92] Le deuxième ensemble de facteurs, liés à ceux du premier ensemble, a trait au degré d'interdépendance et d'intégration économiques caractérisant la relation des parties (*Birmingham*; *Pettkus*; *Nasser*). Plus le niveau d'intégration des finances, des intérêts économiques et du bien-être économique des conjoints est élevé, plus il est probable que ceux-ci soient considérés comme ayant été engagés dans une coentreprise familiale. Par exemple, l'existence d'un compte de banque conjoint utilisé comme une « bourse commune », ainsi que le fait que l'unité familiale exploitait la ferme, constituaient des facteurs clés dans l'analyse effectuée par le juge Dickson dans *Rathwell*. Le partage des dépenses et la mise en commun des économies peuvent aussi être des facteurs pertinents (voir *Wilson*; *Panara*).

[93] La conduite des parties peut aussi indiquer un sentiment d'appartenance, de réciprocité et de priorité du bien-être de l'unité familiale par rapport

the individual interests of the individual members (McCamus, at p. 366). These and other factors may indicate that the economic well-being and lives of the parties are largely integrated (see, e.g., *Pettkus*, at p. 850).

(c) *Actual Intent*

[94] Underpinning the law of unjust enrichment is an appropriate concern for the autonomy of the parties, and this is a particularly important consideration in relation to domestic partnerships. While domestic partners might not marry for a host of reasons, one of them may be the deliberate choice not to have their lives economically intertwined. Thus, in considering whether there is a joint family venture, the actual intentions of the parties must be given considerable weight. Those intentions may have been expressed by the parties or may be inferred from their conduct. The important point, however, is that the quest is for their actual intent as expressed or inferred, not for what in the court's view "reasonable" parties *ought* to have intended in the same circumstances. Courts must be vigilant not to impose their own views, under the guise of inferred intent, in order to reach a certain result.

[95] Courts may infer from the parties' conduct that they intended to share in the wealth they jointly created (P. Parkinson, "Beyond *Pettkus v. Becker*: Quantifying Relief for Unjust Enrichment" (1993), 43 *U.T.L.J.* 217, at p. 245). The conduct of the parties may show that they intended the domestic and professional spheres of their lives to be part of a larger, common venture (*Pettkus*; *Peter*; *Sorochan*). In some cases, courts have explicitly labelled the relationship as a "partnership" in the social and economic sense (*Panara*, at para. 71; *McDougall*, at para. 14). Similarly, the intention to engage in a joint family venture may be inferred where the parties accepted that their relationship was "equivalent to marriage" (*Birmingham*, at para. 1), or where the parties held themselves out to the public as married (*Sorochan*). The stability of the relationship may be a relevant factor as may the length of cohabitation (*Nasser*; *Sorochan*; *Birmingham*). When parties have lived together in a stable relationship for

aux intérêts individuels de chacun des membres (McCamus, p. 366). Ces facteurs, parmi d'autres, peuvent indiquer que le bien-être économique et la vie des parties sont bien intégrés (voir, par exemple, *Pettkus*, p. 850).

c) *Intention réelle*

[94] Un souci du respect de l'autonomie des parties sous-tend les règles relatives à l'enrichissement injustifié, et il s'agit d'un élément particulièrement important dans les unions libres. Les conjoints de fait peuvent décider de ne pas se marier pour une foule de raisons, mais l'une d'elles peut être le choix délibéré de ne pas être financièrement liés. Par conséquent, pour savoir s'il existe une coentreprise familiale, il faut accorder une importance considérable aux intentions réelles des parties. Ces intentions peuvent avoir été exprimées par les parties ou inférées de leur conduite. Cependant, ce qui importe, c'est que l'on recherche leur intention réelle, expresse ou inférée, et non ce que, selon la cour, des parties « raisonnables » *auraient dû* vouloir dans les mêmes circonstances. Les tribunaux doivent, en invoquant l'intention inférée, veiller à ne pas imposer leurs points de vue dans le but d'arriver à un certain résultat.

[95] Les tribunaux peuvent déduire de la conduite des parties qu'elles avaient l'intention de partager la richesse qu'elles ont créée ensemble (P. Parkinson, « Beyond *Pettkus v. Becker* : Quantifying Relief for Unjust Enrichment » (1993), 43 *U.T.L.J.* 217, p. 245). La conduite des parties peut démontrer qu'elles voulaient que leurs vies familiale et professionnelle fassent partie d'un tout, d'une entreprise commune (*Pettkus*; *Peter*; *Sorochan*). Dans certains cas, les tribunaux ont expressément défini la relation comme étant une [TRADUCTION] « association » d'un point de vue social et économique (*Panara*, par. 71; *McDougall*, par. 14). De même, l'intention de s'engager dans une coentreprise familiale peut être déduite quand les parties ont reconnu que leur relation était [TRADUCTION] « équivalente au mariage » (*Birmingham*, par. 1), ou quand les parties se présentaient auprès d'autrui comme un couple marié (*Sorochan*). La stabilité de la relation peut constituer un facteur pertinent, tout comme

a lengthy period, it may be nearly impossible to engage in a precise weighing of the benefits conferred within the relationship (*McDougall; Nasser*).

[96] The title to property may also reflect an intent to share wealth, or some portion of it, equitably. This may be the case where the parties are joint tenants of property. Even where title is registered to one of the parties, acceptance of the view that wealth will be shared may be evident from other aspects of the parties' conduct. For example, there may have been little concern with the details of title and accounting of monies spent for household expenses, renovations, taxes, insurance, and so on. Plans for property distribution on death, whether in a will or a verbal discussion, may also indicate that the parties saw one another as domestic and economic partners.

[97] The parties' actual intent may also negate the existence of a joint family venture, or support the conclusion that particular assets were to be held independently. Once again, it is the parties' actual intent, express or inferred from the evidence, that is the relevant consideration.

(d) *Priority of the Family*

[98] A final category of factors to consider in determining whether the parties were in fact engaged in a joint family venture is whether and to what extent they have given priority to the family in their decision making. A relevant question is whether there has been in some sense detrimental reliance on the relationship, by one or both of the parties, for the sake of the family. As Professor McCamus puts it, the question is whether the parties have been "[p]roceeding on the basis of understandings or assumptions about a shared future which may or may not be articulated" (p. 365). The focus is on contributions to the domestic and financial partnership, and particularly financial sacrifices made by the parties for the welfare

la durée de la cohabitation (*Nasser; Sorochan; Birmingham*). Si les parties ont vécu une relation stable pendant une longue période, il est presque impossible de soupeser précisément les avantages conférés dans le cadre de la relation (*McDougall; Nasser*).

[96] Le titre de propriété peut aussi refléter une intention de partager équitablement la richesse, ou une partie de celle-ci. Ce peut être le cas lorsque les parties possèdent des biens en commun. Même quand le titre est enregistré au nom d'une des parties, d'autres aspects de la conduite des parties peuvent indiquer que la richesse sera partagée. Par exemple, les parties peuvent être très peu intéressées par tout ce qui entoure le titre et l'état des sommes dépensées pour la résidence, les rénovations, les taxes, les assurances et tout le reste. Les plans de répartition des biens au décès, que ce soit dans un testament ou une déclaration verbale, peuvent aussi indiquer que les parties se considéraient comme des partenaires conjugaux et économiques.

[97] L'intention réelle des parties pourrait aussi permettre d'écarter l'existence d'une coentreprise familiale ou étayer la conclusion selon laquelle des biens déterminés devaient être détenus de façon indépendante. Encore une fois, c'est l'intention réelle des parties, expresse ou inférée de la preuve, qui est le facteur pertinent.

d) *Priorité accordée à la famille*

[98] Le dernier ensemble de facteurs à considérer pour déterminer si les parties participaient à une coentreprise familiale consiste à savoir si elles avaient donné la priorité à la famille dans le processus décisionnel, et ce, dans quelle mesure. Une question pertinente est de savoir si, dans une certaine mesure, une des parties ou les deux se sont fiés sur la relation à leur détriment, mais pour le bien-être de la famille. Comme l'indique le professeur McCamus, la question est de savoir si les parties ont [TRADUCTION] « [a]lgi en sachant ou en supposant qu'elles mèneraient une vie commune, peu importe que cela ait été dit ou non » (p. 365). L'accent est mis sur les contributions au partenariat domestique et financier, et particulièrement sur les

of the collective or family unit. Whether the roles of the parties fall into the traditional wage earner/homemaker division, or whether both parties are employed and share domestic responsibilities, it is frequently the case that one party relies on the success and stability of the relationship for future economic security, to his or her own economic detriment (Parkinson, at p. 243). This may occur in a number of ways including: leaving the workforce for a period of time to raise children; relocating for the benefit of the other party's career (and giving up employment and employment-related networks as a result); foregoing career or educational advancement for the benefit of the family or relationship; and accepting underemployment in order to balance the financial and domestic needs of the family unit.

[99] As I see it, giving priority to the family is not associated exclusively with the actions of the more financially dependent spouse. The spouse with the higher income may also make financial sacrifices (for example, foregoing a promotion for the benefit of family life), which may be indicative that the parties saw the relationship as a domestic and financial partnership. As Professor Parkinson puts it, the joint family venture may be identified where

[o]ne party has encouraged the other to rely to her detriment by leaving the workforce or forgoing other career opportunities for the sake of the relationship, and the breakdown of the relationship leaves her in a worse position than she would otherwise have been had she not acted in this way to her economic detriment. [p. 256]

(6) Summary of *Quantum Meruit Versus Constructive Trust*

[100] I conclude:

1. The monetary remedy for unjust enrichment is not restricted to an award based on a fee-for-services approach.

sacrifices financiers consentis par les parties pour le bien-être de l'unité collective ou familiale. Que les rôles des parties correspondent à la répartition traditionnelle des tâches entre le salarié et la femme au foyer, ou que les deux parties aient un emploi et partagent les responsabilités domestiques, il arrive souvent qu'une des parties se fie à la réussite et à la stabilité de la relation pour en assurer la sécurité économique, à son propre détriment économique (Parkinson, p. 243). Cela peut survenir de nombreuses façons, notamment lorsqu'une partie quitte le marché du travail pendant un certain temps pour élever les enfants; en déménageant pour aider la carrière de l'autre partie (et, par conséquent, en abandonnant son emploi et les réseaux liés à l'emploi); en renonçant à une carrière ou à une formation pour le bien de la famille ou de la relation; et en acceptant un sous-emploi dans le but d'équilibrer les besoins financiers et domestiques de l'unité familiale.

[99] Selon moi, accorder la priorité à la famille n'est pas exclusivement le fait du conjoint le plus dépendant financièrement. Le conjoint ayant le revenu le plus élevé peut aussi faire des sacrifices financiers (par exemple, en renonçant à une promotion au profit de la vie familiale), ce qui peut indiquer que les parties considéraient la relation comme un partenariat domestique et financier. Comme l'indique le professeur Parkinson, il y a une coentreprise familiale quand

[TRADUCTION] [u]ne partie a encouragé l'autre à se fier à elle à son détriment en quittant le marché du travail ou en renonçant à d'autres possibilités d'avancement pour le bien de la relation, et la rupture la laisse dans une situation pire que si elle n'avait pas agi de cette façon à son détriment économique. [p. 256]

(6) *Quantum meruit* plutôt que *fiducie constructive* : résumé

[100] En conclusion :

1. La réparation pécuniaire pour enrichissement injustifié ne se limite pas à une indemnité calculée en fonction de la rémunération des services rendus.

2. Where the unjust enrichment is most realistically characterized as one party retaining a disproportionate share of assets resulting from a joint family venture, and a monetary award is appropriate, it should be calculated on the basis of the share of those assets proportionate to the claimant's contributions.
3. To be entitled to a monetary remedy of this nature, the claimant must show both (a) that there was, in fact, a joint family venture, and (b) that there is a link between his or her contributions to it and the accumulation of assets and/or wealth.
4. Whether there was a joint family venture is a question of fact and may be assessed by having regard to all of the relevant circumstances, including factors relating to (a) mutual effort, (b) economic integration, (c) actual intent and (d) priority of the family.

F. *Mutual Benefit Conferral*

(1) Introduction

[101] As discussed earlier, the unjust enrichment analysis in domestic situations is often complicated by the fact that there has been a mutual conferral of benefits; each party in almost all cases confers benefits on the other: Parkinson, at p. 222. Of course, a claimant cannot expect both to get back something given to the defendant and retain something received from him or her: Birks, at p. 415. The unjust enrichment analysis must take account of this common sense proposition. How and where in the analysis should this be done?

[102] The answer is fairly straightforward when the essence of the unjust enrichment claim is that one party has emerged from the relationship with a disproportionate share of assets accumulated through their joint efforts. These are the cases of a joint family venture in which the mutual efforts of the parties have resulted in an accumulation of wealth. The remedy is a share of that wealth

2. Dans les cas où l'enrichissement injustifié est, de façon très réaliste, défini comme étant le fait pour une partie de conserver une part disproportionnée des biens provenant d'une coentreprise familiale, et qu'une réparation pécuniaire est appropriée, il faut calculer cette réparation en fonction de la part de ces biens qui est proportionnelle aux contributions du demandeur.
3. Pour avoir droit à une réparation pécuniaire de cette nature, le demandeur doit prouver : a) qu'une coentreprise familiale existait effectivement, et b) qu'il existe un lien entre ses contributions à la coentreprise et l'accumulation de l'avoir ou de la richesse.
4. La question de savoir s'il existait une coentreprise familiale est une question de fait et on peut l'apprécier en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les facteurs relatifs : a) à l'effort commun, b) à l'intégration économique, c) à l'intention réelle et d) à la priorité accordée à la famille.

F. *Avantages réciproques*

(1) Introduction

[101] Comme je l'ai déjà mentionné, l'analyse de l'enrichissement injustifié en matière familiale se complique souvent du fait qu'il y a eu des avantages réciproques; dans presque tous les cas, chaque partie confère des avantages à l'autre partie : Parkinson, p. 222. Bien entendu, le demandeur ne peut pas s'attendre tout à la fois à récupérer quelque chose qu'il a donné au défendeur et à conserver une chose que lui a donnée le défendeur : Birks, p. 415. L'analyse doit tenir compte de cette proposition sensée. Comment et à quel moment dans l'analyse faut-il prendre en compte les avantages réciproques?

[102] La réponse est assez simple si l'allégation d'enrichissement injustifié veut essentiellement qu'une partie ait quitté la relation avec une part disproportionnée des avoirs accumulés grâce aux efforts conjoints. C'est le cas des coentreprises familiales dans lesquelles les efforts communs des parties ont permis d'accumuler une richesse. La réparation consiste en une part de cette richesse

proportionate to the claimant's contributions. Once the claimant has established his or her contribution to a joint family venture, and a link between that contribution and the accumulation of wealth, the respective contributions of the parties are taken into account in determining the claimant's proportionate share. While determining the proportionate contributions of the parties is not an exact science, it generally does not call for a minute examination of the give and take of daily life. It calls, rather, for the reasoned exercise of judgment in light of all of the evidence.

[103] Mutual benefit conferral, however, gives rise to more practical problems in an unjust enrichment claim where the appropriate remedy is a money award based on a fee-for-services-provided approach. The fact that the defendant has also provided services to the claimant may be seen as a factor relevant at all stages of the unjust enrichment analysis. Some courts have considered benefits received by the claimant as part of the benefit/detriment analysis (for example, at the Court of Appeal in *Peter v. Beblow* (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266). Others have looked at mutual benefits as an aspect of the juristic reason inquiry (for example, *Ford v. Werden* (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 169 (C.A.), and the Court of Appeal judgment in *Kerr*). Still others have looked at mutual benefits in relation to both juristic reason and at the remedy stage (for example, as proposed in *Wilson*). It is apparent that some clarity and consistency is necessary with respect to this issue.

[104] In my view, there is much to be said about the approach to the mutual benefit analysis mapped out by Huddart J.A. in *Wilson*. Specifically, I would adopt her conclusions that mutual enrichments should mainly be considered at the defence and remedy stages, but that they may be considered at the juristic reason stage to the extent that the provision of reciprocal benefits constitutes relevant evidence of the existence (or non-existence) of juristic reason for the enrichment (para. 9). This approach is consistent with the authorities from this Court,

proportionnée aux contributions du demandeur. Une fois que le demandeur a démontré sa contribution à la coentreprise familiale ainsi que le lien entre cette contribution et l'accumulation de la richesse, les contributions respectives des parties sont prises en considération pour déterminer la part proportionnelle du demandeur. Bien que le calcul des contributions proportionnelles des parties ne soit pas une science exacte, il n'est généralement pas nécessaire d'effectuer un examen détaillé des contributions et des concessions quotidiennes. Il faut plutôt porter un jugement raisonné à la lumière de l'ensemble de la preuve.

[103] Cependant, les avantages réciproques entraînent des problèmes pratiques particuliers lorsque la réparation appropriée consiste en une indemnité pécuniaire calculée en fonction de la valeur de la rémunération des services rendus. Le fait que le défendeur ait aussi fourni des services au demandeur peut être considéré comme un facteur pertinent à toutes les étapes de l'analyse de l'enrichissement injustifié. Certains tribunaux ont examiné les avantages reçus par le demandeur dans le cadre de l'analyse des avantages et des désavantages (par exemple, la Cour d'appel dans *Peter c. Beblow* (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266). D'autres ont considéré les avantages réciproques comme un aspect de l'analyse du motif juridique (par exemple, *Ford c. Werden* (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 169 (C.A.), et le jugement de la Cour d'appel dans l'affaire *Kerr*). D'autres encore ont examiné les avantages réciproques tant à l'étape de l'analyse du motif juridique qu'à celle de la réparation (par exemple, tel que proposé dans *Wilson*). De toute évidence, une certaine clarté et une certaine cohérence s'imposent sur ce point.

[104] À mon avis, il y a beaucoup à dire sur la méthode d'analyse des avantages réciproques élaborée par la juge Huddart de la cour d'appel dans l'affaire *Wilson*. Plus particulièrement, je ferais miennes ses conclusions selon lesquelles les enrichissements mutuels devraient être examinés principalement au stade de la défense ou à celui de la réparation, mais qu'il est aussi possible de le faire au stade de l'analyse du motif juridique dans la mesure où l'octroi d'avantages réciproques constitue une preuve pertinente de l'existence (ou de

and provides a straightforward and just method of ensuring that mutual benefit conferral is fully taken into account without short-circuiting the proper unjust enrichment analysis. I will briefly set out why, in my view, this approach is sound.

[105] At the outset, however, I should say that this Court's decision in *Peter* does not mandate consideration of mutual benefits at the juristic reason stage of the analysis: see, e.g., *Ford*, at para. 14; *Thomas v. Fenton*, 2006 BCCA 299, 269 D.L.R. (4th) 376, at para. 18. Rather, *Peter* made clear that mutual benefit conferral should generally not be considered at the benefit and detriment stages; the Court also approved the trial judge's decision to take mutual benefits into account at the remedy stage of the unjust enrichment analysis.

[106] In *Peter*, the trial judge found that all three elements of unjust enrichment had been established. Before Ms. Peter and Mr. Beblow started living together, he had a housekeeper whom he paid \$350 per month. When Ms. Peter moved in with her children and assumed the housekeeping and child-care responsibilities, the housekeeper was no longer required. The trial judge valued Ms. Peter's contribution by starting with the amount Mr. Beblow had paid his housekeeper, but then discounting this figure by one half to reflect the benefits Ms. Peter received in return. The trial judge then used that discounted figure to value Ms. Peter's services over the 12 years of the relationship: [1988] B.C.J. No. 887 (QL).

[107] The Court of Appeal, at (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266, set aside the judge's finding on the basis that Ms. Peter had failed to establish that she had suffered a deprivation corresponding to the benefits she had conferred on Mr. Beblow. The court reasoned that, although she had performed the services of a housekeeper and homemaker, she had

l'absence) d'un motif juridique justifiant l'enrichissement (par. 9). Cette approche est conforme à la jurisprudence de notre Cour, et elle offre un moyen simple et juste de faire en sorte que l'octroi d'avantages réciproques soit dûment pris en considération sans court-circuiter l'analyse de l'enrichissement injustifié. Je vais expliquer brièvement pourquoi, à mon avis, cette approche est bien fondée.

[105] D'entrée de jeu, toutefois, je souligne que l'arrêt *Peter* de notre Cour n'exige pas que l'on prenne en considération les avantages réciproques à l'étape de l'analyse du motif juridique : voir, par exemple, *Ford*, par. 14; *Thomas c. Fenton*, 2006 BCCA 299, 269 D.L.R. (4th) 376, par. 18. Au contraire, il ressort clairement de *Peter* qu'on ne devrait généralement pas tenir compte des avantages réciproques au stade de l'analyse avantages-désavantages; la Cour a aussi approuvé la décision du juge de première instance de prendre en considération les avantages réciproques au moment de déterminer la réparation à accorder au titre de l'enrichissement injustifié.

[106] Dans *Peter*, le juge de première instance a conclu que les trois éléments de l'enrichissement injustifié avaient été prouvés. Avant que M. Beblow n'habite avec M^{me} Peter, il avait une aide ménagère qu'il payait 350 \$ par mois. Lorsque M^{me} Peter a emménagé chez lui avec ses enfants et qu'elle a assumé les tâches ménagères en plus de s'occuper des enfants, l'aide ménagère n'était plus nécessaire. Le juge de première instance a déterminé la valeur de la contribution de M^{me} Peter en partant du montant que M. Beblow donnait à l'aide ménagère, puis en soustrayant la moitié pour refléter les avantages que M^{me} Peter a reçus en retour. Le juge de première instance a ensuite utilisé ce montant réduit pour déterminer la valeur des services rendus par M^{me} Peter pendant les 12 années qu'a duré la relation : [1988] B.C.J. No. 887 (QL).

[107] La Cour d'appel, dans (1990), 50 B.C.L.R. (2d) 266, a écarté cette conclusion au motif que M^{me} Peter n'avait pas réussi à prouver qu'elle avait subi un appauvrissement correspondant aux avantages qu'elle avait conférés à M. Beblow. La cour a conclu que, bien qu'elle ait rendu les services d'une aide ménagère et d'une personne au foyer, elle avait

received compensation because she and her children lived in Mr. Beblow's home rent free and he contributed more for groceries than she had.

[108] This Court reversed the Court of Appeal and restored the trial judge's award. The Court was unanimous that Ms. Peter had established all of the elements of unjust enrichment, including deprivation. Cory J. (with whom McLachlin J. agreed on this point) made short work of Mr. Beblow's submission that Ms. Peter had not shown deprivation. He observed, "As a general rule, if it is found that the defendant has been enriched by the efforts of the plaintiff there will, almost as a matter of course be deprivation suffered by the plaintiff": at p. 1013. The Court also unanimously upheld the trial judge's approach of taking account of the benefits Ms. Peter had received at the remedy stage of his decision. As noted, the trial judge had reduced the monthly amount used to calculate Ms. Peter's award by 50 percent to reflect benefits she had received from Mr. Beblow. McLachlin J. did not disagree with this approach, holding at p. 1003 that the figure arrived at by the judge fairly reflected the value of Ms. Peter's contribution to the family assets. Cory J., at p. 1025, referred to the trial judge's approach as "a fair means of calculating the amount due to the appellant". Thus, the Court approved the approach of taking the mutual benefit issue into account at the remedy stage of the analysis. *Peter* therefore does not support the view that mutual benefits should be considered at the benefit/detriment or juristic reason stages of the analysis.

(2) The Correct Approach

[109] As I noted earlier, my view is that mutual benefit conferral can be taken into account at the juristic reason stage of the analysis, but only to the extent that it provides relevant evidence of the existence of a juristic reason for the enrichment. Otherwise, the mutual exchange of benefits should

reçu une compensation parce que ses enfants et elle vivaient chez M. Beblow sans avoir à payer de loyer et que celui-ci contribuait plus qu'elle à payer l'épicerie.

[108] Notre Cour a infirmé la décision de la Cour d'appel et a rétabli la décision du juge de première instance. La Cour a décidé à l'unanimité que M^{me} Peter avait prouvé tous les éléments de l'enrichissement injustifié, y compris l'appauvrissement. Le juge Cory (la juge McLachlin partageait son avis sur ce point) est passé rapidement sur la prétention de M. Beblow selon laquelle M^{me} Peter n'avait pas démontré l'appauvrissement. Il a fait remarquer que, « [e]n règle générale, si l'on constate que le défendeur s'est enrichi du fait des efforts de la demanderesse, cette dernière subira presque certainement un appauvrissement » : p. 1013. La Cour a aussi confirmé à l'unanimité l'approche du juge de première instance selon laquelle il faut tenir compte des avantages reçus par M^{me} Peter au moment de déterminer la réparation à accorder. Comme je l'ai déjà indiqué, le juge de première instance avait réduit de moitié le montant mensuel utilisé pour calculer la somme accordée à M^{me} Peter pour refléter les avantages que celle-ci avait reçus de M. Beblow. La juge McLachlin n'a pas rejeté cette approche, concluant à la p. 1003 que le montant auquel était arrivé le juge reflétait bien la valeur de la contribution de M^{me} Peter à l'avoir familial. À la page 1025, le juge Cory a qualifié l'approche du juge de première instance de « façon équitable de calculer le montant dû à l'appelante ». Ainsi, la Cour a souscrit à l'approche selon laquelle il faut, dans l'analyse, tenir compte de la question des avantages réciproques à l'étape de la réparation. L'arrêt *Peter* n'étaye donc pas le point de vue selon lequel il convient, dans l'analyse, d'examiner les avantages réciproques à l'étape de l'examen des avantages et des désavantages ou à celle du motif juridique.

(2) La bonne approche

[109] Comme je l'ai déjà dit, je suis d'avis que les avantages réciproques peuvent être pris en considération à l'étape de l'analyse du motif juridique, mais seulement dans la mesure où ils offrent une preuve pertinente de l'existence d'un tel motif. Autrement, il faut en tenir compte à l'étape de la défense ou de

be taken into account at the defence and/or remedy stage. It is important to note that this can, and should, take place whether or not the defendant has made a formal counterclaim or pleaded set-off.

[110] I turn first to why mutual benefits should not be addressed at the benefit/detriment stage of the analysis. In my view, refusing to address mutual benefits at that point is consistent with the *quantum meruit* origins of the fee-for-services approach and, as well, with the straightforward economic approach to the benefit/detriment analysis which has been consistently followed by this Court.

[111] An unjust enrichment claim based on a fee-for-services approach is analogous to the traditional claim for *quantum meruit*. In *quantum meruit* claims, the fact that some benefit had flowed from the defendant to the claimant is taken into account by reducing the claimant's recovery by the amount of the countervailing benefit provided. For example, in a *quantum meruit* claim where the plaintiff is seeking to recover money paid pursuant to an unenforceable contract, but received some benefit from the defendant already, the claim will succeed but the award will be reduced by an amount corresponding to the value of that benefit: Maddaugh and McCamus (loose-leaf ed.), vol. II, at §13:200. The authors offer as an example *Giles v. McEwan* (1896), 11 Man. R. 150 (Q.B. *en banc*). In that case, two employees recovered in *quantum meruit* for services provided to the defendant under an unenforceable agreement, but the amount of the award was reduced to reflect the value of benefits the defendant had provided to them. Thus, taking the benefits conferred by the defendant into account at the remedy stage is consistent with general principles of *quantum meruit* claims. Of course, if the defendant has pleaded a counterclaim or set-off, the mutual benefit issue must be resolved in the course of considering that defence or claim.

la réparation. Il est important de souligner que cela peut, et devrait, avoir lieu peu importe que le défendeur ait présenté une demande reconventionnelle formelle ou invoqué la compensation.

[110] Je vais d'abord expliquer pourquoi les avantages réciproques ne devraient pas être examinés, dans l'analyse, à l'étape de l'examen des avantages et des désavantages. À mon avis, refuser de traiter de la question des avantages réciproques à cette étape est conforme à la notion du *quantum meruit* dont l'approche fondée sur la rémunération des services rendus tire son origine et aussi à l'analyse économique simple des avantages et des désavantages, que notre Cour a toujours utilisée.

[111] L'action pour enrichissement injustifié fondée sur la rémunération des services rendus est analogue à la réclamation traditionnelle fondée sur le *quantum meruit*. Dans ces réclamations, le fait que le défendeur ait conféré un avantage au demandeur est pris en considération pour réduire le recouvrement du demandeur du montant de l'avantage ainsi reçu. Par exemple, s'agissant d'une réclamation fondée sur le *quantum meruit* où le demandeur cherche à recouvrer les sommes payées en vertu d'un contrat inexécutable alors qu'il a déjà reçu un avantage du défendeur, la réclamation sera accueillie, mais l'indemnité sera réduite du montant correspondant à la valeur de cet avantage : Maddaugh et McCamus (éd. feuilles mobiles), vol. II, §13:200. Les auteurs citent, à titre d'exemple, l'affaire *Giles c. McEwan* (1896), 11 Man. R. 150 (B.R. *in banco*). Dans cette affaire, deux employés avaient présenté une réclamation fondée sur le *quantum meruit* afin de recouvrer la valeur des services rendus au défendeur en vertu d'un contrat inexécutable, mais le montant de l'indemnité a été réduit pour refléter la valeur des avantages conférés par le défendeur. Ainsi, prendre en considération à l'étape de la réparation les avantages conférés par le défendeur est conforme aux principes généraux s'appliquant aux réclamations fondées sur le *quantum meruit*. Bien entendu, si le défendeur a déposé une demande reconventionnelle ou a invoqué la compensation, la question des avantages mutuels doit être tranchée au moment de considérer ce moyen de défense ou cette demande.

[112] Refusing to take mutual benefits into account at the benefit/detriment stage is also supported by a straightforward economic approach to the benefit/detriment analysis which the Court has consistently followed. *Garland* is a good example. The class action plaintiffs claimed in unjust enrichment to seek restitution for late payment penalties that had been imposed but that this Court (in an earlier decision) found had been charged at a criminal rate of interest: see *Garland v. Consumers' Gas Co.*, [1998] 3 S.C.R. 112. The company argued that it had not been enriched because its rates were set by a regulatory mechanism out of its control, and that the rates charged would have been even higher had the company not received the late payment penalties as part of its revenues. That argument was accepted by the Court of Appeal, but rejected on the further appeal to this Court. Iacobucci J., for the Court, held that the payment of money, under the “straightforward economic approach” adopted in *Peter*, was a benefit: para. 32. He stated at para. 36: “There simply is no doubt that Consumers’ Gas received the monies represented by the [late payment penalties] and had that money available for use in the carrying on of its business. . . . We are not, at this stage, concerned with what happened to this benefit in the ongoing operation of the regulatory scheme.” The Court held that the company was in fact asserting the “change of position” defence (that is, the defence that is available when “an innocent defendant demonstrates that it has materially changed its position as a result of an enrichment such that it would be inequitable to require the benefit to be returned”: para. 63). This defence is considered only after the three elements of an unjust enrichment claim have been established: para. 37. Thus the Court declined to get into a detailed consideration at the benefit/detriment stage of the defendant’s submissions that it had not benefitted because of the regulatory scheme.

[113] While *Garland* dealt with the payment of money, my view is that the same approach should be applied where the alleged enrichment consists

[112] Suivant l’analyse économique simple des avantages et des désavantages que la Cour a toujours utilisée, il faut refuser de prendre les avantages réciproques en considération à cette étape. L’arrêt *Garland* en offre un bon exemple. Dans un recours collectif, les demandeurs réclamaient la restitution, pour enrichissement injustifié, des pénalités pour paiement en retard imposées mais que notre Cour (dans une décision antérieure) avait déclaré constituer des intérêts à un taux criminel : voir *Garland c. Consumers’ Gas Co.*, [1998] 3 R.C.S. 112. L’entreprise a soutenu qu’elle ne s’était pas enrichie parce que ses taux étaient fixés par un mécanisme de réglementation indépendant, et que les taux auraient été encore plus élevés si l’entreprise n’avait pas reçu les pénalités pour paiement en retard à titre de recettes. Cet argument a été accepté par la Cour d’appel, mais a été rejeté lors du pourvoi devant notre Cour. Le juge Iacobucci, rédigeant pour la Cour, a conclu que les paiements, dans le cadre de l’« analyse économique simple » adoptée dans *Peter*, constituaient un avantage : par. 32. Voici ce qu’il a affirmé au par. 36 : « Il n’y a simplement aucun doute que Consumers’ Gas a reçu les sommes d’argent représentées par les [pénalités pour paiement en retard] et qu’elle pouvait utiliser cet argent pour exploiter son entreprise. [. . .] À ce stade, nous ne nous intéressons pas à la question de savoir où est passé cet avantage dans le cadre de l’application du régime de réglementation. » La Cour a conclu que l’entreprise invoquait en fait le moyen de défense fondé sur « le changement de situation » (c.-à-d., le moyen de défense que peut faire valoir « un défendeur innocent démontre qu’à la suite d’un enrichissement il a modifié sa situation à un point tel qu’il serait inéquitable de l’obliger à rendre l’avantage qu’il a reçu » : par. 63). Ce moyen de défense est pris en considération seulement une fois remplies les trois conditions de l’action pour enrichissement injustifié : par. 37. La Cour a donc refusé de procéder, à l’étape de l’examen des avantages et des désavantages, à un examen détaillé des prétentions du défendeur selon lesquelles il n’avait bénéficié d’aucun avantage à cause du régime de réglementation.

[113] L’arrêt *Garland* portait sur le paiement d’une somme d’argent, mais j’estime qu’il faut appliquer la même méthode quand l’enrichissement

of services. Provided that they confer a tangible benefit on the defendant, the services will generally constitute an enrichment and a corresponding deprivation. Whether the deprivation was counter-balanced by benefits flowing to the claimant from the defendant should not be addressed at the first two steps of the analysis. I turn now to the limited role that mutual benefit conferral may have at the juristic reason stage of the analysis.

[114] As previously set out, juristic reason is the third of three parts to the unjust enrichment analysis. As McLachlin J. put it in *Peter*, at p. 990, “It is at this stage that the court must consider whether the enrichment and detriment, morally neutral in themselves, are ‘unjust.’” The juristic reason analysis is intended to reveal whether there is a reason for the defendant to retain the enrichment, not to determine its value or whether the enrichment should be set off against reciprocal benefits: *Wilson*, at para. 30. *Garland* established that claimants must show that there is no juristic reason falling within any of the established categories, such as whether the benefit was a gift or pursuant to a legal obligation. If that is established, it is open to the defendant to show that a different juristic reason for the enrichment should be recognized, having regard to the parties’ reasonable expectations and public policy considerations.

[115] The fact that the parties have conferred benefits on each other may provide relevant evidence of their reasonable expectations, a subject that may become germane when the defendant attempts to show that those expectations support the existence of a juristic reason outside the settled categories. However, given that the purpose of the juristic reason step in the analysis is to determine whether the enrichment was just, not its extent, mutual benefit conferral should only be considered at the juristic reason stage for that limited purpose.

(3) Summary

[116] I conclude that mutual benefits may be considered at the juristic reason stage, but only to

allégué consiste en des services. Dans la mesure où ils confèrent un avantage tangible au défendeur, les services constituent généralement un enrichissement et un appauvrissement correspondant. La question de savoir si l’appauvrissement était contrebalancé par des avantages conférés au demandeur par le défendeur ne devrait pas être traitée aux deux premières étapes de l’analyse. J’examinerai maintenant le rôle limité que peuvent jouer les avantages réciproques à l’étape de l’analyse du motif juridique.

[114] Comme je l’ai déjà dit, le motif juridique est la troisième des trois parties de l’analyse de l’enrichissement injustifié. Comme l’a dit le juge McLachlin à la p. 990 de l’arrêt *Peter*, « [c]’est à cette étape que le tribunal doit vérifier si l’enrichissement et le désavantage, moralement neutres en soi, sont “injustes” ». L’analyse du motif juridique vise à indiquer si le défendeur est justifié de conserver l’enrichissement, et non pas à en déterminer la valeur ou à déterminer s’il convient d’opérer compensation après examen des avantages réciproques : *Wilson*, par. 30. Selon *Garland*, les demandeurs doivent démontrer qu’aucun motif juridique ne se retrouve dans l’une ou l’autre des catégories établies, par exemple si l’avantage était un don ou s’il découlait d’une obligation légale. Si cette preuve est faite, le défendeur peut alors démontrer qu’un motif juridique différent justifiant l’enrichissement devrait être reconnu, compte tenu des attentes raisonnables des parties et des considérations d’intérêt public.

[115] Le fait que les parties se soient mutuellement conféré des avantages peut constituer une preuve pertinente de leurs attentes raisonnables, ce qui peut devenir pertinent au moment où le défendeur essaie de prouver que ces attentes appuient l’existence d’un motif juridique que l’on ne retrouve dans aucune des catégories établies. Cependant, comme l’analyse du motif juridique cherche à déterminer si l’enrichissement était équitable et non à en mesurer l’ampleur, les avantages réciproques ne devraient être pris en considération à cette étape que pour cette fin précise.

(3) Résumé

[116] Je conclus que les avantages réciproques peuvent être examinés à l’étape de l’analyse du motif

the extent that they provide evidence relevant to the parties' reasonable expectations. Otherwise, mutual benefit conferrals are to be considered at the defence and/or remedy stage. I will have more to say in the next section about how mutual benefit conferral and the parties' reasonable expectations may come into play in the juristic reason analysis.

G. Reasonable or Legitimate Expectations

[117] The final point that requires some clarification relates to the role of the parties' reasonable expectations in the domestic context. My conclusion is that, while in the early domestic unjust enrichment cases the parties' reasonable expectations played an important role in the juristic reason analysis, the development of the law, and particularly the Court's judgment in *Garland*, has led to a more limited and clearly circumscribed role for those expectations.

[118] In the early cases of domestic unjust enrichment claims, the reasonable expectations of the claimant and the defendant's knowledge of those expectations were central to the juristic reason analysis. For example, in *Pettkus*, when Dickson J. came to the juristic reason step in the analysis, he said that "where one person in a relationship tantamount to spousal prejudices herself in the reasonable expectation of receiving an interest in property and the other person in the relationship freely accepts benefits conferred by the first person in circumstances where he knows or ought to have known of that reasonable expectation, it would be unjust to allow the recipient of the benefit to retain it" (p. 849). Similarly, in *Sorochan*, at p. 46, precisely the same reasoning was invoked to show that there was no juristic reason for the enrichment.

[119] In these cases, central to the Court's concern was whether it was just to require the defendant to pay — in fact to surrender an interest in property — for services not expressly requested. The Court's answer was that it would indeed be unjust for the defendant to retain the benefits, given

juridique, mais seulement dans la mesure où ils fournissent une preuve pertinente relativement aux attentes raisonnables des parties. Sinon, ils doivent être pris en considération au stade de la défense ou à celui de la réparation. J'en dirai davantage dans la prochaine partie sur la façon dont les avantages réciproques et les attentes raisonnables des parties peuvent entrer en jeu dans l'analyse du motif juridique.

G. Attentes raisonnables ou légitimes

[117] Le dernier point qui requiert quelques précisions concerne le rôle des attentes raisonnables des parties en matière familiale. Je conclus que, bien que les attentes raisonnables des parties aient joué un rôle important dans l'analyse du motif juridique dans les premières affaires familiales d'enrichissement injustifié, avec l'évolution du droit, et en particulier depuis l'arrêt *Garland* de notre Cour, l'importance que l'on accorde à ces attentes est plus limitée et clairement circonscrite.

[118] Dans les premières affaires où l'enrichissement injustifié était allégué en situation familiale, les attentes raisonnables du demandeur et le fait que le défendeur connaissait ces attentes étaient au cœur de l'analyse du motif juridique. Par exemple, dans *Pettkus*, quand le juge Dickson est arrivé dans son analyse à l'étape de l'examen du motif juridique, il a affirmé que « lorsqu'une personne, liée à une autre dans une relation qui équivaut à une union conjugale, se cause un préjudice dans l'expectative raisonnable de recevoir un droit de propriété et que l'autre personne accepte librement les avantages que lui procure la première, alors qu'elle connaît ou devrait connaître cette expectative, il serait injuste de permettre au bénéficiaire de conserver cet avantage » (p. 849). De même, dans *Sorochan*, à la p. 46, exactement le même raisonnement a été suivi pour montrer qu'il n'y avait aucun motif juridique justifiant l'enrichissement.

[119] Dans ces affaires, la question de savoir s'il était équitable d'obliger le défendeur à payer — en fait de céder un droit de propriété — pour des services qu'il n'avait pas expressément demandés constituait l'une des préoccupations majeures de la Cour. La Cour a répondu qu'il serait effectivement

that he had continued to accept the services when he knew or ought to have known that the claimant was providing them with the reasonable expectation of reward.

[120] The Court's resort to reasonable expectations and the defendant's knowledge of them in these cases is analogous to the "free acceptance" principle. The notion of free acceptance has been invoked to extend restitutionary recovery beyond the traditional sorts of *quantum meruit* claims in which services had either been requested or provided under an unenforceable agreement. The law's traditional reluctance to provide a remedy for claims where no request was made was based on the tenet that a person should generally not be required, in effect, to pay for services that he or she did not request, and perhaps did not want. However, this concern carries much less weight when the person receiving the services knew that they were being provided, had no reasonable belief that they were a gift, and yet continued to freely accept them: see P. Birks, *Unjust Enrichment* (2nd ed. 2005), at pp. 56-57.

[121] The need to engage in this analysis of the claimant's reasonable expectations and the defendant's knowledge thereof with respect to domestic services has, in my view, now been overtaken by developments in the law. *Garland*, as noted, mandated a two-step approach to the juristic reason analysis. The first step requires the claimant to show that the benefit was not conferred for any existing category of juristic reasons. Significantly, the fact that the defendant also provided services to the claimant is not one of the existing categories. Nor is the fact that the services were provided pursuant to the parties' reasonable expectations. However, the fact that the parties reasonably expected the services to be provided might afford relevant evidence in relation to whether the case falls within one of the traditional categories, for example a contract or gift. Other than in that way, mutual benefit conferral and the parties' reasonable expectations have a very limited role to play at the

injuste pour le défendeur de conserver les avantages, étant donné qu'il avait continué à accepter les services alors qu'il savait ou aurait dû savoir que le demandeur les rendait dans l'expectative raisonnable de recevoir une récompense.

[120] La prise en considération par la Cour des attentes raisonnables et de la connaissance qu'en avait, dans ces affaires, le défendeur rejoint le principe de l'« acceptation libre ». On a eu recours à la notion d'acceptation libre pour étendre la portée du recouvrement aux fins de restitution au-delà des catégories traditionnelles de demandes fondées sur le *quantum meruit* où l'on faisait valoir que des services avaient été demandés ou fournis en vertu d'une entente inexécutable. La réticence traditionnelle de la common law à accorder une réparation dans les cas où il n'y a eu aucune demande reposait sur le principe qu'une personne n'est généralement pas tenue de payer les services qu'elle n'a pas demandés, et ne voulait peut-être pas. Toutefois, cette préoccupation revêt une importance bien moindre quand la personne qui reçoit les services savait qu'ils étaient rendus, n'avait aucun motif raisonnable de penser qu'il s'agissait d'une donation et a tout de même continué à les accepter librement : voir P. Birks, *Unjust Enrichment* (2^e éd. 2005), p. 56-57.

[121] La nécessité de procéder à cette analyse des attentes raisonnables du demandeur et de la connaissance qu'en avait le défendeur relativement aux services domestiques est à mon avis dépassée du fait de l'évolution du droit. L'arrêt *Garland*, comme je l'ai indiqué plus haut, a établi une méthode en deux étapes pour guider l'analyse du motif juridique. La première étape oblige le demandeur à prouver que l'avantage ne correspond pas à l'une des catégories établies de motifs juridiques. Il importe de souligner que le fait que le défendeur ait aussi rendu des services au demandeur n'entre dans aucune de ces catégories établies de motifs juridiques, pas plus que le fait que les services aient été fournis conformément aux attentes raisonnables des parties. Cependant, le fait que les parties s'attendaient raisonnablement à ce que les services soient fournis peut constituer une preuve pertinente relativement à la question de savoir si l'affaire entre dans une des catégories traditionnelles, par exemple, un contrat ou une donation.

first step in the juristic reason analysis set out in *Garland*.

[122] However, different considerations arise at the second step. Following *Peter* and *Garland*, the parties' reasonable or legitimate expectations have a critical role to play when the defendant seeks to establish a new juristic reason, whether case-specific or categorical. As Iacobucci J. put it in *Garland*, this introduces a category of residual situations in which "courts can look to all of the circumstances of the transaction in order to determine whether there is another reason to deny recovery" (para. 45). Specifically, it is here that the court should consider the parties' reasonable expectations and questions of policy.

[123] It will be helpful in understanding how *Peter* and *Garland* fit together to apply the *Garland* approach to an issue touched on, but not resolved, in *Peter*. In *Peter*, an issue was whether a claim based on the provision of domestic services could be defeated on the basis that the services had been provided as part of the bargain between the parties in deciding to live together. While the Court concluded that the claim failed on the facts, it did not hold that such a claim would inevitably fail in all circumstances: p. 991. It seems to me that, in light of *Garland*, where a "bargain" which does not constitute a binding contract is alleged, the issue will be considered at the stage when the defendant seeks to show that there is a juristic reason for the enrichment that does not fall within any of the existing categories; the claim is that the "bargain" represents the parties' reasonable expectations, and evidence about their reasonable expectations would be relevant evidence of the existence (or not) of such a bargain.

[124] To summarize:

1. The parties' reasonable or legitimate expectations have little role to play in deciding whether

Sinon, les avantages réciproques et les attentes raisonnables des parties ont un rôle très limité à jouer dans la première étape de l'analyse du motif juridique énoncée dans *Garland*.

[122] Cependant, des considérations différentes entrent en jeu à la deuxième étape. Suivant les arrêts *Peter* et *Garland*, les attentes raisonnables ou légitimes des parties jouent un rôle essentiel quand le défendeur cherche à établir un nouveau motif juridique, que ce soit au cas par cas ou à l'égard d'une catégorie. Comme le dit le juge Iacobucci dans *Garland*, cela introduit des situations résiduelles qui permettent « aux tribunaux d'examiner toutes les circonstances de l'opération afin de déterminer s'il existe un autre motif de refuser le recouvrement » (par. 45). Plus particulièrement, c'est à cette étape que le tribunal devrait tenir compte des attentes raisonnables des parties et des considérations d'intérêt public.

[123] Pour comprendre de quelle façon les arrêts *Peter* et *Garland* vont de pair, il sera utile d'appliquer la méthode énoncée dans *Garland* à une question abordée, mais non réglée, dans *Peter*. Dans *Peter*, on cherchait à savoir si une demande fondée sur la prestation de services domestiques pouvait être rejetée au motif que les services avaient été fournis dans le cadre d'une entente intervenue entre les parties lorsqu'elles ont décidé de vivre ensemble. Bien que la Cour ait conclu que la demande n'était pas fondée dans les faits, elle n'a pas statué qu'une telle demande était vouée à l'échec dans tous les cas : p. 991. Il me semble que, au vu de l'arrêt *Garland*, lorsque l'existence d'une « entente » qui ne constitue pas un contrat obligatoire est alléguée, la question sera examinée à l'étape à laquelle le défendeur tente de prouver qu'il existe un motif juridique justifiant l'enrichissement qui n'entre dans aucune des catégories existantes; il invoquera que l'« entente » représente les attentes raisonnables des parties, et une preuve relative à ces attentes sera une preuve pertinente de l'existence (ou de l'absence) d'une telle entente.

[124] En résumé :

1. Les attentes raisonnables ou légitimes des parties jouent un rôle négligeable au moment

the services were provided for a juristic reason within the existing categories.

2. In some cases, the fact that mutual benefits were conferred or that the benefits were provided pursuant to the parties' reasonable expectations may be relevant evidence of whether one of the existing categories of juristic reasons is present. An example might be whether there was a contract for the provision of the benefits. However, generally the existence of mutual benefits flowing from the defendant to the claimant will not be considered at the juristic reason stage of the analysis.
3. The parties' reasonable or legitimate expectations have a role to play at the second step of the juristic reason analysis, that is, where the defendant bears the burden of establishing that there is a juristic reason for retaining the benefit which does not fall within the existing categories. It is the mutual or legitimate expectations of both parties that must be considered, and not simply the expectations of either the claimant or the defendant. The question is whether the parties' expectations show that retention of the benefits is just.

[125] I will now turn to the two cases at bar.

IV. The Vanasse Appeal

A. *Introduction*

[126] In the *Vanasse* appeal, the main issue is how to quantify a monetary award for unjust enrichment. The trial judge awarded a share of the net increase in the family's wealth during the period of unjust enrichment. The Court of Appeal held that this was the wrong approach, finding that the trial judge ought to have performed a *quantum meruit* calculation in which the value that each party received from the other was assessed and set off. This required an evaluation of the defendant

de décider si les services ont été fournis pour un motif juridique appartenant à une catégorie établie.

2. Dans certains cas, le fait que des avantages réciproques aient été conférés ou le fait que les avantages aient été fournis conformément aux attentes raisonnables des parties peut constituer une preuve pertinente pour déterminer si l'une des catégories établies de motifs juridiques s'applique. On pourrait citer comme exemple l'existence d'un contrat stipulant la prestation des avantages. Cependant, en général, l'existence d'avantages conférés par le défendeur au demandeur ne sera pas prise en considération à l'étape de l'analyse qui porte sur l'examen du motif juridique.
3. Les attentes raisonnables ou légitimes des parties jouent un rôle à la deuxième étape de l'analyse du motif juridique, où il incombe au défendeur d'établir qu'il existe un motif juridique de conserver l'avantage n'appartenant pas aux catégories établies. Ce sont les attentes mutuelles ou légitimes des deux parties qui doivent être prises en considération, et non uniquement les attentes du demandeur ou celles du défendeur. La question est de savoir si les attentes des parties prouvent qu'il est équitable de conserver les avantages.

[125] Je vais maintenant examiner les deux présents pourvois.

IV. Le pourvoi Vanasse

A. *Introduction*

[126] Dans le pourvoi *Vanasse*, la principale question consiste à savoir comment établir la valeur d'une indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié. La juge de première instance a accordé une part de l'augmentation nette de la richesse familiale pendant la période de l'enrichissement injustifié. La Cour d'appel a conclu que ce n'était pas la bonne façon de procéder et que la juge de première instance aurait dû effectuer un calcul fondé sur le *quantum meruit* où la valeur que

Mr. Seguin's non-financial contributions to the relationship which, in the view of the Court of Appeal, the trial judge failed to perform. As the record did not permit the court to apply the correct legal principles to the facts, it ordered a new hearing with respect to compensation and consequential changes to spousal support.

[127] In this Court, the appellant Ms. Vanasse raises two issues:

1. Did the Court of Appeal err by insisting on a strict *quantum meruit* (i.e. "value received") approach to quantify the monetary award for unjust enrichment?
2. Did the Court of Appeal err in finding that the trial judge had failed to consider relevant evidence of Mr. Seguin's contributions?

[128] In my view, the appeal should be allowed and the trial judge's order restored. For the reasons I have developed above, my view is that money compensation for unjust enrichment need not always, as a matter of principle, be calculated on a *quantum meruit* basis. The trial judge here, although not labelling it as such, found that there was a joint family venture and that there was a link between Ms. Vanasse's contribution to it and the substantial accumulation of wealth which the family achieved. In my view, the trial judge made a reasonable assessment of the monetary award appropriate to reverse this unjust enrichment, taking due account of Mr. Seguin's undoubted and substantial contributions.

B. *Brief Overview of the Facts and Proceedings*

[129] The background facts of this case are largely undisputed. The parties lived together in

chacune des parties a reçue de l'autre est évaluée et défalquée. Il fallait évaluer les contributions non financières du défendeur M. Seguin, ce qui, selon la Cour d'appel, n'a pas été fait par la juge de première instance. Comme le dossier ne permettait pas à la cour d'appliquer aux faits les principes juridiques appropriés, elle a ordonné la tenue d'une nouvelle audience relativement à la question de l'indemnité et de la modification corrélative de la pension alimentaire.

[127] Devant notre Cour, l'appelante M^{me} Vanasse soulève deux questions :

1. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en imposant une approche stricte fondée sur le *quantum meruit* (c.-à-d. la « valeur reçue ») pour établir la valeur de l'indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié?
2. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que la juge de première instance avait omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents aux contributions de M. Seguin?

[128] À mon avis, il convient d'accueillir le pourvoi et de rétablir la décision de la juge de première instance. Pour les motifs exposés ci-dessus, j'estime qu'il n'est pas toujours nécessaire, en principe, de calculer une indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié en fonction du *quantum meruit*. En l'espèce, la juge de première instance a conclu qu'il y avait une coentreprise familiale, bien qu'elle ne l'ait pas qualifiée ainsi, et qu'il existait un lien entre la contribution de M^{me} Vanasse à la coentreprise et l'accumulation importante de la richesse familiale. À mon avis, la juge de première instance a raisonnablement évalué l'indemnité pécuniaire appropriée pour permettre l'annulation de cet enrichissement injustifié, en tenant dûment compte des contributions incontestées et importantes de M. Seguin.

B. *Bref aperçu des faits et des décisions des juridictions inférieures*

[129] Le contexte de l'espèce n'est essentiellement pas contesté. Les parties ont vécu en union de

a common law relationship for approximately 12 years, from 1993 until March 2005. Together, they had two children who were aged 8 and 10 at the time of trial.

[130] During approximately the first four years of their relationship (1993 to 1997), the parties diligently pursued their respective careers, Ms. Vanasse with the Canadian Security Intelligence Service (“CSIS”) and Mr. Seguin with Fastlane Technologies Inc., marketing a network operating system he had developed.

[131] In March of 1997, Ms. Vanasse took a leave of absence to move with Mr. Seguin to Halifax, where Fastlane had relocated for important business reasons. During the next three and one-half years, the parties had two children; Ms. Vanasse took care of the domestic labour, while Mr. Seguin devoted himself to developing Fastlane. The family moved back to Ottawa in 1998, where Mr. Seguin purchased a home and registered it in the names of both parties as joint tenants. In September 2000, Fastlane was sold and Mr. Seguin netted approximately \$11 million. He placed the funds in a holding company, with which he continued to develop business and investment opportunities.

[132] After the sale of Fastlane, Ms. Vanasse continued to assume most of the domestic responsibilities, although Mr. Seguin was more available to assist. He continued to manage the finances.

[133] The parties separated on March 27, 2005. At that time, they were in starkly contrasting financial positions: Ms. Vanasse’s net worth had gone from about \$40,000 at the time she and Mr. Seguin started living together, to about \$332,000 at the time of separation; Mr. Seguin had come into the relationship with about \$94,000, and his net worth at the time of separation was about \$8,450,000.

[134] Ms. Vanasse brought proceedings in the Superior Court of Justice. In addition to seeking orders with respect to spousal support and child

fait pendant environ 12 ans, de 1993 à mars 2005. Ensemble, ils ont eu deux enfants qui étaient âgés de 8 et 10 ans au moment du procès.

[130] Pendant environ les quatre premières années de leur relation (de 1993 à 1997), les parties ont diligemment continué leur carrière respective, M^{me} Vanasse avec le Service canadien du renseignement de sécurité (« SCRS ») et M. Seguin avec Fastlane Technologies Inc., où il commercialisait un système d’exploitation de réseau qu’il avait mis sur pied.

[131] En mars 1997, M^{me} Vanasse a pris un congé pour pouvoir s’installer avec M. Seguin à Halifax, où Fastlane avait déménagé pour des raisons d’affaires importantes. Au cours des trois années et demie qui ont suivi, les parties ont eu deux enfants. Madame Vanasse s’occupait des travaux domestiques pendant que M. Seguin se consacrait à la croissance de Fastlane. La famille est revenue à Ottawa en 1998, où M. Seguin a acheté une maison qu’il a enregistré au nom des deux parties en tant que copropriétaires. En septembre 2000, Fastlane a été vendue et M. Seguin a reçu environ 11 millions de dollars. Il a placé les fonds dans une société de portefeuille, grâce à laquelle il a continué de profiter d’occasions d’affaires et de placement.

[132] Après la vente de Fastlane, M^{me} Vanasse a continué de s’acquitter de la plupart des obligations familiales, bien que M. Seguin ait été davantage disponible pour l’aider. Il a continué de gérer les finances.

[133] Les parties se sont séparées le 27 mars 2005. À ce moment-là, leur situation financière était diamétralement opposée : l’avoir net de M^{me} Vanasse était passé d’environ 40 000 \$ au début de leur vie commune à près de 332 000 \$ au moment de la séparation; M. Seguin avait environ 94 000 \$ au début de la relation et son avoir net s’élevait à environ 8 450 000 \$ au moment de la séparation.

[134] Madame Vanasse a intenté une action devant la Cour supérieure de justice. En plus de demander une pension alimentaire et la garde des

custody, Ms. Vanasse claimed unjust enrichment. She argued that Mr. Seguin had been unjustly enriched because he retained virtually all of the funds from the sale of Fastlane, even though she had contributed to their acquisition through benefits she conferred in the form of domestic and childcare services. She alleged her contributions allowed Mr. Seguin to dedicate most of his time and energy to Fastlane. She sought relief by way of constructive trust in Mr. Seguin's remaining one half interest in the family home, and a one-half interest in the investment assets held by Mr. Seguin's holding company.

[135] Mr. Seguin contested the unjust enrichment claim. While conceding he had been enriched during the roughly three-year period where he was working outside the home full time and Ms. Vanasse was working at home full time (May 1997 to September 2000), he argued there was no corresponding deprivation because he had given her a one-half interest in the family home and approximately \$44,000 in Registered Retirement Savings Plans ("RRSPs"). In the alternative, Mr. Seguin submitted that a constructive trust remedy was inappropriate because there was no link between Ms. Vanasse's contributions and the property of Fastlane.

[136] The trial judge, Blishen J., concluded that the relationship of the parties could be divided into three distinct periods: (1) From the commencement of cohabitation in 1993 until March 1997 when Ms. Vanasse left her job at CSIS; (2) From March 1997 to September 2000, during which both children were born and Fastlane was sold; and (3) From September 2000 to the separation of the parties in March 2005. She concluded that neither party had been unjustly enriched in the first or third periods; she held that their contributions to the relationship during these periods had been proportionate. In the first period, there were no children of the relationship and both parties were focused on their careers; in the third period, both parents were home and their contributions had been proportionate.

enfants, elle a invoqué l'enrichissement injustifié. Elle a soutenu que M. Seguin s'était injustement enrichi parce qu'il avait conservé la quasi-totalité de la somme provenant de la vente de Fastlane, bien qu'elle ait contribué à son acquisition grâce aux avantages qu'elle conférait sous forme de services domestiques et de soins des enfants. Elle a affirmé que ses contributions ont permis à M. Seguin de consacrer la majeure partie de son temps et de son énergie à l'entreprise. Elle a invoqué l'existence d'une fiducie constructive sur la moitié de la résidence familiale revenant à M. Seguin et un intérêt bénéficiaire de moitié dans les placements de la société de portefeuille de M. Seguin.

[135] Monsieur Seguin a contesté la demande pour enrichissement injustifié. Il a admis s'être enrichi pendant la période d'environ trois ans où il travaillait à temps plein à l'extérieur de la maison et que M^{me} Vanasse restait à la maison à temps plein (de mai 1997 à septembre 2000), mais il a soutenu qu'il n'y avait pas eu un appauvrissement correspondant parce qu'il lui avait donné la moitié de la résidence familiale et environ 44 000 \$ dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite (« REER »). À titre subsidiaire, M. Seguin a fait valoir qu'une fiducie constructive était inappropriée en raison de l'absence de lien entre les contributions de M^{me} Vanasse et la propriété de Fastlane.

[136] En première instance, la juge Blishen a conclu que la relation des parties pouvait se diviser en trois périodes distinctes : (1) du début de la cohabitation en 1993 jusqu'en mars 1997 quand M^{me} Vanasse a laissé son emploi au SCRS; (2) de mars 1997 à septembre 2000, période pendant laquelle les deux enfants sont nés et Fastlane a été vendue; et (3) de septembre 2000 à la séparation des parties en mars 2005. Elle a conclu que ni l'une ni l'autre des parties ne s'était injustement enrichie au cours de la première et de la troisième périodes; elle était d'avis que leurs contributions à la relation pendant ces périodes avaient été proportionnées. Durant la première période, les parties n'avaient pas d'enfant et elles se concentraient sur leur carrière; durant la troisième période, les deux parents étaient à la maison et leurs contributions étaient proportionnées.

[137] In the second period, however, the trial judge concluded that Mr. Seguin had been unjustly enriched by Ms. Vanasse. Ms. Vanasse had been in charge of the domestic side of the household, including caring for their two children. She had not been a “nanny/housekeeper” and, as the trial judge held, throughout the relationship she had been at least “an equal contributor to the family enterprise”. The trial judge concluded that Ms. Vanasse’s contributions during this second period “significantly benefited Mr. Seguin and were not proportional” (para. 139).

[138] The trial judge found as a fact that Ms. Vanasse’s efforts during this second period were directly linked to Mr. Seguin’s business success. She stated, at para. 91, that

Mr. Seguin was enriched by Ms. Vanasse’s running of the household, providing child care for two young children and looking after all the necessary appointments and needs of the children. Mr. Seguin could not have made the efforts he did to build up the company but for Ms. Vanasse’s assumption of these responsibilities. Mr. Seguin reaped the benefits of Ms. Vanasse’s efforts by being able to focus his time, energy and efforts on Fastlane. [Emphasis added.]

Again at para. 137, the trial judge found that

Mr. Seguin was unjustly enriched and Ms. Vanasse deprived for three and one-half years of their relationship, during which time Mr. Seguin often worked day and night and traveled frequently while in Halifax. Mr. Seguin could not have succeeded, as he did, and built up the company, as he did, without Ms. Vanasse assuming the vast majority of childcare and household responsibilities. Mr. Seguin could not have devoted his time to Fastlane but for Ms. Vanasse’s assumption of those responsibilities. . . . Mr. Seguin reaped the benefit of Ms. Vanasse’s efforts by being able to focus all of his considerable energies and talents on making Fastlane a success. [Emphasis added.]

[137] Cependant, durant la deuxième période, la juge de première instance a conclu que M. Seguin s’était injustement enrichi grâce à M^{me} Vanasse. Cette dernière s’occupait des travaux domestiques, ainsi que de leurs deux enfants. Elle n’était pas une [TRADUCTION] « gouvernante/femme de ménage » et, comme l’a dit la juge de première instance, elle a « contribué au moins autant à la coentreprise familiale » pendant la relation. La juge de première instance a conclu que les contributions de M^{me} Vanasse pendant la deuxième période « avaient grandement avantage M. Seguin et n’étaient pas proportionnées » (par. 139).

[138] La juge de première instance a conclu que les efforts déployés par M^{me} Vanasse pendant cette deuxième période étaient directement liés au succès professionnel de M. Seguin. Elle a affirmé ce qui suit au par. 91 :

[TRADUCTION] Monsieur Seguin s’était enrichi du fait que M^{me} Vanasse gérât la maisonnée, s’occupait de deux jeunes enfants et veillait à prendre tous les rendez-vous nécessaires pour ceux-ci et à répondre à tous leurs besoins. Monsieur Seguin n’aurait pas pu faire tous les efforts qu’il a faits pour créer l’entreprise si M^{me} Vanasse n’avait pas assumé ces responsabilités. Monsieur Seguin a tiré un avantage des efforts de M^{me} Vanasse, car il a été en mesure de concentrer son temps, son énergie et ses efforts sur Fastlane. [Je souligne.]

Encore au par. 137, la juge du procès a conclu comme suit :

[TRADUCTION] Monsieur Seguin s’était injustement enrichi et M^{me} Vanasse s’est appauvrie pendant trois ans et demi de leur relation, période pendant laquelle M. Seguin travaillait souvent jour et nuit et voyageait fréquemment quand ils habitaient à Halifax. Monsieur Seguin n’aurait pas pu avoir le même succès et développer l’entreprise comme il l’a fait si M^{me} Vanasse n’avait pas assumé la majeure partie des responsabilités parentales et domestiques. Il n’aurait pas pu consacrer son temps à Fastlane si M^{me} Vanasse n’avait pas assumé ces responsabilités. [. . .] Monsieur Seguin a bénéficié des efforts déployés par M^{me} Vanasse puisqu’il était en mesure de concentrer toute son énergie et son talent sur la réussite de Fastlane. [Je souligne.]

[139] The trial judge concluded that a monetary award in this case was appropriate, given Mr. Seguin's ability to pay, and lack of a sufficiently direct and substantial link between Ms. Vanasse's contributions and Fastlane or Mr. Seguin's holding company, as required to impose a remedial constructive trust.

[140] With respect to quantification, Blishen J. noted that Ms. Vanasse had received a one-half interest in the family home, but concluded that this was not adequate compensation for her contributions. The trial judge compared the net worths of the parties and determined that Ms. Vanasse was entitled to a one-half interest in the prorated increase in Mr. Seguin's net worth during the period of the unjust enrichment. She reasoned that his net worth had increased by about \$8.4 million dollars over the 12 years of the relationship. Although she noted that the most significant increase took place when Fastlane was sold towards the end of the period of unjust enrichment, she nonetheless prorated the increase over the full 12 years of the relationship, yielding a figure of about \$700,000 per year. Starting with the \$2.45 million increase attributable to the three and one-half years of unjust enrichment, the trial judge awarded Ms. Vanasse 50 per cent of that amount, less the value of her interest in the family home and her RRSPs. This produced an award of just under \$1 million.

[141] Mr. Seguin did not appeal Blishen J.'s unjust enrichment finding, and conceded unjust enrichment between 1997 and 2000 on appeal. Therefore, the trial judge's findings that there had been an unjust enrichment during that period and that there was no unjust enrichment during the other periods are not in issue. The sole issue for determination in this Court is the propriety of the trial judge's monetary award for the unjust enrichment which she found to have occurred.

[139] La juge du procès a conclu qu'une indemnité pécuniaire était appropriée, compte tenu de la capacité de payer de M. Seguin et de l'absence d'un lien suffisamment direct et important entre les contributions de M^{me} Vanasse et Fastlane ou la société de portefeuille de M. Seguin, comme cela est requis pour imposer une fiducie constructive de nature réparatoire.

[140] Quant au montant de cette indemnité, la juge Blishen a fait remarquer que M^{me} Vanasse avait reçu une part de 50 pour cent dans la résidence familiale, mais a conclu que cela ne constituait pas une compensation adéquate pour ses contributions. Après avoir comparé les avoirs nets des parties, elle a décidé que M^{me} Vanasse avait droit à la moitié de l'augmentation proportionnelle de l'avoir net de M. Seguin pendant la période de l'enrichissement injustifié. Selon elle, son avoir net avait augmenté d'environ 8,4 millions de dollars au cours des 12 années de la relation. Elle a certes souligné que l'augmentation la plus importante a eu lieu quand Fastlane a été vendue vers la fin de la période de l'enrichissement injustifié, mais elle a tout de même réparti l'augmentation sur les 12 années qu'a duré la relation, arrivant à un montant d'environ 700 000 \$ par année. En commençant avec l'augmentation de 2,45 millions de dollars attribuable à la période de trois ans et demi d'enrichissement injustifié, la juge de première instance a accordé à M^{me} Vanasse la moitié de ce montant, moins la valeur de sa part dans la résidence familiale et ses REER. Le montant accordé était donc d'un peu moins de 1 million de dollars.

[141] En appel, M. Seguin n'a pas attaqué la conclusion de la juge Blishen relative à l'enrichissement injustifié et a admis cet enrichissement entre 1997 et 2000. Par conséquent, les conclusions de la juge de première instance, suivant lesquelles il y a eu enrichissement injustifié durant cette période et non durant les autres périodes, ne sont pas en cause. La seule question que notre Cour est appelée à trancher concerne la justesse de l'indemnité pécuniaire accordée pour l'enrichissement injustifié.

C. *Analysis*

- (1) Was the Trial Judge Required to Use a Quantum Meruit Approach to Calculate the Monetary Award?

[142] I agree with the appellant that a monetary award for unjust enrichment need not, as a matter of principle, always be calculated on a fee-for-services basis. As I have set out earlier, an unjust enrichment is best characterized as one party leaving the relationship with a disproportionate share of wealth that accumulated as a result of the parties' joint efforts. This will be so when the parties were engaged in a joint family venture and where there is a link between the contributions of the claimant and the accumulation of wealth. When this is the case, the amount of the enrichment should be assessed by determining the claimant's proportionate contribution to that accumulated wealth. As the trial judge saw it, this was exactly the situation of Ms. Vanasse and Mr. Seguin.

- (2) Existence of a Joint Family Venture

[143] The trial judge, after a six-day trial, concluded that "Ms. Vanasse was not a nanny/housekeeper". She found that Ms. Vanasse had been at least "an equal contributor to the family enterprise" throughout the relationship and that, during the period of unjust enrichment, her contributions "significantly benefited Mr. Seguin" (para. 139).

[144] The trial judge, of course, did not review the evidence under the headings that I have suggested will be helpful in identifying a joint family venture, namely "mutual effort", "economic integration", "actual intent" and "priority of the family". However, her findings of fact and analysis indicate that the unjust enrichment of Mr. Seguin at the expense of Ms. Vanasse ought to be characterized as the retention by Mr. Seguin of a disproportionate share of the wealth generated from a joint family

C. *Analyse*

- (1) La juge du procès était-elle tenue d'appliquer une méthode fondée sur le quantum meruit pour calculer l'indemnité pécuniaire?

[142] Je suis d'accord avec l'appelante pour dire qu'il n'est pas nécessaire, en principe, de toujours calculer l'indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié en fonction de la valeur des services. Comme je l'ai déjà dit, la meilleure façon de définir l'enrichissement injustifié est de considérer ce qui se produit lorsqu'une partie quitte la relation avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce aux efforts communs des parties. Il y a un enrichissement injustifié quand les parties étaient engagées dans une coentreprise familiale et qu'il existe un lien entre les contributions du demandeur et l'accumulation de la richesse. Quand c'est le cas, il convient d'évaluer la valeur de l'enrichissement en déterminant la contribution proportionnelle du demandeur à cette richesse. Selon la juge de première instance, telle était la situation de M^{me} Vanasse et de M. Seguin.

- (2) Existence d'une coentreprise familiale

[143] Après un procès de six jours, la juge de première instance a conclu que [TRADUCTION] « M^{me} Vanasse n'était ni une gouvernante ni une femme de ménage ». La juge était d'avis que M^{me} Vanasse avait « contribué au moins autant à la coentreprise familiale » pendant la relation et que, pendant la période d'enrichissement injustifié, ses contributions « avaient grandement avantagé M. Seguin » (par. 139).

[144] Évidemment, la juge de première instance n'a pas examiné la preuve en fonction des rubriques qui, selon moi, permettront de reconnaître l'existence d'une coentreprise familiale, à savoir « l'effort commun », « l'intégration économique », « l'intention réelle » et « la priorité accordée à la famille ». Toutefois, selon ses conclusions de fait et son analyse, l'enrichissement injustifié de M. Seguin au détriment de M^{me} Vanasse tient à la conservation, par M. Seguin, d'une part disproportionnée de la

venture. The judge's findings fit conveniently under the headings I have suggested.

(a) *Mutual Effort*

[145] There are several factors in this case which suggest that, throughout their relationship, the parties were working collaboratively towards common goals. First, as previously mentioned, the trial judge found that Ms. Vanasse's role was not as a "nanny/housekeeper" but rather as at least an equal contributor throughout the relationship. The parties made important decisions keeping the overall welfare of the family at the forefront: the decision to move to Halifax, the decision to move back to Ottawa, and the decision that Ms. Vanasse would not return to work after the sale of Fastlane are all clear examples. The parties pooled their efforts for the benefit of their family unit. As the trial judge found, during the second stage of their relationship from March 1997 to September 2000, the division of labour was such that Ms. Vanasse was almost entirely responsible for running the home and caring for the children, while Mr. Seguin worked long hours and managed the family finances. The trial judge found that it was through their joint efforts that they were able to raise a young family and acquire wealth. As she put it, "Mr. Seguin could not have made the efforts he did to build up the company but for Ms. Vanasse's assumption of these responsibilities" (para. 91). While Mr. Seguin's long hours and extensive travel reduced somewhat in September 1998 when the parties returned to Ottawa, the basic division of labour remained the same.

[146] Notably, the period of unjust enrichment corresponds to the time during which the parties had two children together (in 1997 and 1999), a further indicator that they were working together to achieve common goals. The length of the relationship is also relevant, and their 12-year cohabitation is a significant period of time. Finally, the trial

richesse générée par la coentreprise familiale. Les conclusions de la juge entrent parfaitement dans les rubriques que j'ai suggérées.

a) *Effort conjoint*

[145] En l'espèce, plusieurs facteurs donnent à penser que, pendant toute la durée de leur relation, les parties collaboraient en vue d'atteindre des buts communs. Premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, la juge de première instance a conclu que M^{me} Vanasse n'avait pas un rôle de [TRADUCTION] « gouvernante ni de femme de ménage », mais qu'elle avait contribué au moins autant pendant la relation. Les parties ont pris des décisions importantes en gardant le bien-être de la famille au premier plan : la décision de déménager à Halifax, la décision de revenir s'établir à Ottawa et la décision selon laquelle M^{me} Vanasse ne retournerait pas travailler après la vente de Fastlane en sont des exemples clairs. Les parties ont uni leurs efforts pour le bien-être de l'unité familiale. Comme l'a conclu la juge de première instance, pendant la deuxième étape de leur relation de mars 1997 à septembre 2000, la répartition des tâches était telle que M^{me} Vanasse était presque entièrement responsable de la maison et des enfants, alors que M. Seguin travaillait de longues heures et gérait les finances familiales. La juge de première instance a conclu que les parties ont été en mesure d'élever une famille et d'acquérir une richesse grâce à leurs efforts communs. Pour reprendre ses propos, [TRADUCTION] « M. Seguin n'aurait pas pu faire tous les efforts qu'il a faits pour créer l'entreprise si M^{me} Vanasse n'avait pas assumé ces responsabilités » (par. 91). Bien que les longues heures de travail et les déplacements de M. Seguin aient quelque peu diminué en septembre 1998 quand les parties sont retournées à Ottawa, la répartition fondamentale des tâches est demeurée la même.

[146] Il convient de souligner que la période d'enrichissement injustifié correspond à la période pendant laquelle les parties ont eu leurs deux enfants (en 1997 et 1999), un autre indice qu'elles travaillaient ensemble dans le but de réaliser des objectifs communs. La durée de la relation est aussi pertinente, et 12 ans de cohabitation se veut

judge described the arrangement between the parties as a “family enterprise”, to which Ms. Vanasse was “at least, an equal contributor” (paras. 138-39).

(b) *Economic Integration*

[147] The trial judge found that “[t]his was not a situation of economic interdependence” (para. 105). That said, there was a pooling of resources. Ms. Vanasse was not employed and did not contribute financially to the family after the children were born, and thus was financially dependent on Mr. Seguin. The family home was registered jointly, and the parties had a joint chequing account. As the trial judge put it, “She was ‘the C.E.O. of the kids’ and he was ‘the C.E.O. of the finances’” (para. 105).

(c) *Actual Intent*

[148] The actual intent of the parties in a domestic relationship, as expressed by the parties or inferred from their conduct, must be given considerable weight in determining whether there was a joint family venture. There are a number of findings of fact that indicate these parties considered their relationship to be a joint family venture.

[149] While a promise to marry or the discussion of legal marriage is by no means a prerequisite for the identification of a joint family venture, in this case the parties’ intentions with respect to marriage strongly suggest that they viewed themselves as the equivalent of a married couple. Mr. Seguin proposed to Ms. Vanasse in July 1996 and they exchanged rings. While they were “devoted to one another and still in love”, a wedding date was never set (para. 14). Mr. Seguin raised the topic of marriage again when Ms. Vanasse found out she was pregnant with their first child. Although they never married, the trial judge found that there had been “mutual expectations [of marriage] during the first few years of their 12 year relationship” (para. 64). Mr. Seguin continued to address Ms. Vanasse

une période assez longue. Enfin, la juge de première instance a décrit l’entente entre les parties comme une [TRADUCTION] « entreprise familiale », à laquelle M^{me} Vanasse « contribuait au moins autant » (par. 138-139).

b) *Intégration économique*

[147] La juge du procès a conclu que [TRADUCTION] « [c]e n’était pas une situation d’interdépendance économique » (par. 105). Cela dit, il y avait une mise en commun des ressources. Madame Vanasse ne travaillait pas et ne contribuait pas financièrement à la famille après la naissance des enfants; elle était donc financièrement dépendante de M. Seguin. La résidence familiale était enregistrée aux deux noms et les parties avaient un compte chèque conjoint. Comme l’a dit la juge de première instance, [TRADUCTION] « [e]lle était “PDG des enfants” et il était “PDG des finances” » (par. 105).

c) *Intention réelle*

[148] Dans une relation conjugale, il faut accorder beaucoup d’importance à l’intention réelle des parties, exprimée par elles ou inférée de leur conduite, au moment de déterminer s’il existait une coentreprise familiale. Un certain nombre de conclusions de fait indiquent que ces parties considéraient leur relation comme une coentreprise familiale.

[149] Bien qu’une promesse de mariage ou un projet de mariage ne soit absolument pas une condition préalable pour conclure à l’existence d’une coentreprise familiale, en l’espèce, les intentions des parties à l’égard du mariage portent fortement à croire qu’elles se considéraient elles-mêmes comme un couple marié. Monsieur Seguin a demandé M^{me} Vanasse en mariage en juillet 1996 et ils ont échangé des anneaux. Bien qu’ils aient été [TRADUCTION] « très attachés l’un à l’autre et en amour », ils n’ont jamais fixé une date de mariage (par. 14). Monsieur Seguin a soulevé à nouveau le sujet du mariage quand M^{me} Vanasse a su qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Ils ne se sont jamais mariés, mais la juge de première instance a conclu que les parties [TRADUCTION] « entendaient

as “my future wife”, and she was viewed by the outside world as such (para. 33).

[150] The trial judge also referred to statements made by Mr. Seguin that were strongly indicative of his view that there was a joint family venture. As the trial judge put it, at para. 28, upon the sale of Fastlane

Mr. Seguin became a wealthy man. He told Ms. Vanasse that they would never have to worry about finances as their parents did; their children could go to the best schools and they could live a good life without financial concerns.

Again, at para. 98:

After the sale of the company, Mr. Seguin indicated they could retire, the children could go to the best schools and the family would be well cared for. The family took travel vacations, enjoyed luxury cars, bought a large cabin cruiser which they used for summer vacations and purchased condominiums at Mont-Tremblant.

[151] While the trial judge viewed Mr. Seguin’s promises and reassurances as contributing to a reasonable expectation on the part of Ms. Vanasse that she was to share in the increase of his net worth during the period of unjust enrichment, in my view these comments are more appropriately characterized as a reflection of the reality that there was a joint family venture, to which the couple jointly contributed for their mutual benefit and the benefit of their children.

(d) *Priority of the Family*

[152] There is a strong inference from the factual findings that, to Mr. Seguin’s knowledge, Ms. Vanasse relied on the relationship to her detriment. As the trial judge found, in 1997 Ms. Vanasse gave up a lucrative and exciting career with CSIS, where she was training to be an intelligence officer, to move to Halifax with Mr. Seguin. In many ways this was a sacrifice on her part; she left her career,

[se marier] pendant les premières années de leur relation de 12 ans » (par. 64). Monsieur Seguin a continué d’appeler M^{me} Vanasse [TRADUCTION] « ma future femme » et c’est ainsi que les autres la percevaient (par. 33).

[150] La juge de première instance a aussi fait référence à certaines déclarations de M. Seguin qui donnaient fortement à penser que lui-même estimait qu’il existait une coentreprise familiale. Comme l’a dit la juge de première instance au par. 28, après la vente de Fastlane,

[TRADUCTION] M. Seguin est devenu riche. Il a affirmé à M^{me} Vanasse qu’ils n’auraient jamais à se préoccuper de leurs finances comme c’était le cas de leurs parents; leurs enfants pourraient fréquenter les meilleures écoles et ils pourraient mener une belle vie sans soucis financiers.

Et au par. 98 :

[TRADUCTION] Après la vente de l’entreprise, M. Seguin a affirmé qu’ils pouvaient prendre leur retraite, que les enfants pourraient fréquenter les meilleures écoles et que la famille serait bien traitée. La famille a voyagé, roulé en voitures de luxe, acheté un grand bateau de croisière pour les vacances d’été ainsi que des condominiums à Mont-Tremblant.

[151] La juge de première instance était d’avis que, à cause des promesses et des paroles rassurantes de M. Seguin, M^{me} Vanasse s’attendait raisonnablement à profiter de l’augmentation de l’avoir net pendant la période d’enrichissement injustifié, mais à mon avis, ces remarques reflètent davantage le fait qu’il existait une coentreprise familiale à laquelle le couple a contribué conjointement pour leur bénéfice et le bénéfice de leurs enfants.

d) *Priorité accordée à la famille*

[152] Il y a de fortes raisons d’inférer des conclusions de fait que, à la connaissance de M. Seguin, M^{me} Vanasse s’est fiée sur la relation à son détriment. Comme l’a dit la juge de première instance, M^{me} Vanasse a renoncé, en 1997, à une carrière lucrative et excitante au SCRS, où elle était en formation pour devenir agente du renseignement, afin de suivre M. Seguin à Halifax. À bien des

gave up her own income, and moved away from her family and friends. Mr. Seguin had moved to Halifax in order to relocate Fastlane for business reasons. Ms. Vanasse then stayed home and cared for their two small children. As I have already explained, during the period of the unjust enrichment, Ms. Vanasse was responsible for a disproportionate share of the domestic labour. It was these domestic contributions that, in part, permitted Mr. Seguin to focus on his work with Fastlane. Later, in 2003, the “family’s decision” was for Ms. Vanasse to remain home after her leave from CSIS had expired (para. 198). Ms. Vanasse’s financial position at the breakdown of the relationship indicates she relied on the relationship to her economic detriment. This is all evidence supporting the conclusion that the parties were, in fact, operating as a joint family venture.

[153] As a final point, I would refer to the arguments made by Mr. Seguin, which were accepted by the Court of Appeal, that the trial judge failed to give adequate weight to sacrifices Mr. Seguin made for the benefit of the relationship. Later in my reasons, I will address the question of whether the trial judge actually failed in this regard. However, the points raised by Mr. Seguin to support this argument actually serve to reinforce the conclusion that there was a joint family venture. Mr. Seguin specifically notes a number of factors, including: agreeing to step down as CEO of Fastlane in September 1997 to make himself more available to Ms. Vanasse, causing friction with his co-workers and partners, and reducing his remuneration; agreeing to relocate to Ottawa at Ms. Vanasse’s request in 1998; and making increased efforts to work at home more and travel less after moving back to Ottawa. These facts are indicative of the sense of mutuality in the parties’ social and financial relationship. In short, they support the identification of a joint family venture.

égards, elle a fait un sacrifice : elle a quitté sa carrière, renoncé à son salaire et déménagé loin de sa famille et de ses amis. Monsieur Seguin s’était installé à Halifax dans le but d’y relocaliser Fastlane pour des raisons d’affaires. Madame Vanasse est donc restée à la maison et s’est occupée de leurs deux jeunes enfants. Comme je l’ai déjà expliqué, pendant la période d’enrichissement injustifié, M^{me} Vanasse assumait une part disproportionnée des travaux domestiques. Ce sont ces contributions domestiques qui ont permis, en partie, à M. Seguin de se concentrer sur son travail avec Fastlane. Plus tard, en 2003, la [TRADUCTION] « famille a décidé » que M^{me} Vanasse allait rester à la maison après la fin de son congé du SCRS (par. 198). La situation financière de M^{me} Vanasse au moment de leur rupture indique qu’elle s’est fiée sur la relation à son détriment économique. Tous ces éléments de preuve étayaient la conclusion que les parties formaient, dans les faits, une coentreprise familiale.

[153] Enfin, je renvoie aux arguments de M. Seguin, qui ont été acceptés par la Cour d’appel, selon lesquels la juge de première instance n’a pas accordé l’importance qui convenait aux sacrifices faits par M. Seguin au bénéfice de la relation. Plus loin dans mes motifs, je vais aborder la question de savoir si la juge de première instance a effectivement commis une erreur à cet égard. Cependant, les points soulevés par M. Seguin pour appuyer cet argument servent en fait à renforcer la conclusion selon laquelle il existait une coentreprise familiale. Monsieur Seguin mentionne expressément un certain nombre de facteurs, y compris : accepter de démissionner de son poste de PDG de Fastlane en septembre 1997 pour se rendre plus disponible pour M^{me} Vanasse, créant ainsi des frictions avec ses collègues et ses partenaires et réduisant sa rémunération; accepter de déménager à Ottawa en 1998 à la demande de M^{me} Vanasse; et redoubler d’efforts pour travailler plus souvent à la maison et voyager moins souvent après le déménagement à Ottawa. Ces faits révèlent un accord mutuel dans la relation sociale et financière des parties. En résumé, ils appuient l’existence d’une coentreprise familiale.

(c) *Conclusion on Identification of the Joint Family Venture*

[154] In my view, the trial judge's findings of fact clearly show that Ms. Vanasse and Mr. Seguin engaged in a joint family venture. The remaining question is whether there was a link between Ms. Vanasse's contributions to it and the accumulation of wealth.

(3) Link to Accumulation of Wealth

[155] The trial judge made a clear finding that there was a link between Ms. Vanasse's contributions and the family's accumulation of wealth.

[156] I have referred earlier, in some detail, to the trial judge's findings in this regard. However, to repeat, her conclusion is expressed particularly clearly at para. 91 of her reasons:

Mr. Seguin could not have made the efforts he did to build up the company but for Ms. Vanasse's assumption of these [household and child-rearing] responsibilities. Mr. Seguin reaped the benefits of Ms. Vanasse's efforts by being able to focus his time, energy and efforts on Fastlane.

[157] Given that and similar findings, I conclude that not only were these parties engaged in a joint family venture, but that there was a clear link between Ms. Vanasse's contribution to it and the accumulation of wealth. The unjust enrichment is thus best viewed as Mr. Seguin leaving the relationship with a disproportionate share of the wealth accumulated as a result of their joint efforts.

(4) Calculation of the Award

[158] The main focus of the appeal was on whether the award ought to have been calculated on a *quantum meruit* basis. Very little was argued before this Court regarding the way the trial judge approached her calculation of a proportionate share of the parties' accumulated wealth. I conclude that

e) *Conclusion sur l'existence de la coentreprise familiale*

[154] À mon avis, dans ses conclusions de fait, la juge de première instance montre clairement que M^{me} Vanasse et M. Seguin étaient engagés dans une coentreprise familiale. Il reste à savoir s'il y avait un lien entre les contributions de M^{me} Vanasse à la coentreprise et l'accumulation de la richesse.

(3) Lien avec l'accumulation de la richesse

[155] La juge de première instance a clairement conclu qu'il y avait un lien entre les contributions de M^{me} Vanasse et l'accumulation de la richesse familiale.

[156] J'ai déjà fait état, d'une manière assez détaillée, des conclusions de la juge de première instance à cet égard. Je reprends toutefois ses propos particulièrement clairs au par. 91 de ses motifs :

[TRADUCTION] Monsieur Seguin n'aurait pas pu faire tous les efforts qu'il a faits pour créer l'entreprise si M^{me} Vanasse n'avait pas assumé ces responsabilités [liées à l'entretien de la maison et à l'éducation des enfants]. Monsieur Seguin a tiré un avantage des efforts de M^{me} Vanasse, car il a été en mesure de concentrer son temps, son énergie et ses efforts sur Fastlane.

[157] Compte tenu de cette conclusion et d'autres semblables, je conclus que non seulement ces parties étaient engagées dans une coentreprise familiale, mais aussi qu'il y avait un lien clair entre la contribution de M^{me} Vanasse et l'accumulation de la richesse. Il convient donc de considérer qu'il y a un enrichissement injustifié du fait que M. Seguin quitte la relation avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce à leurs efforts conjoints.

(4) Calcul de l'indemnité

[158] Le pourvoi visait principalement à savoir s'il aurait fallu calculer l'indemnité en fonction du *quantum meruit*. Devant notre Cour, la façon dont la juge de première instance a déterminé la part proportionnelle de la richesse accumulée des parties a été très peu débattue. J'estime que l'approche

the trial judge's approach was reasonable in the circumstances, but I stress that I do not hold out her approach as necessarily being a template for future cases. Within the legal principles I have outlined, there may be many ways in which an award may be quantified reasonably. I prefer not to make any more general statements about the quantification process in the context of this appeal, except this. Provided that the correct legal principles are applied, and the findings of fact are not tainted by clear and determinative error, a trial judge's assessment of damages is treated with considerable deference on appeal: see, e.g., *Nance v. British Columbia Electric Railway Co.*, [1951] A.C. 601 (P.C.). A reasoned and careful exercise of judgment by the trial judge as to the appropriate monetary award to remedy an unjust enrichment should be treated with the same deference. There are two final specific points that I must address.

[159] Mr. Seguin submits, very briefly, that a proper application of the "value survived" approach in this case would require a careful determination of the contributions by third parties to the growth of Fastlane during the period his own contributions were diminished, as a result of what counsel characterizes as Ms. Vanasse's "demands" that he reduce his hours and move back to Ottawa. This argument is premised on the notion that the money he received from the sale was not justly his to share with Ms. Vanasse. I cannot accept this premise. Unexplained is why he received more than his share when the company was sold or why, having received more than he was due, Ms. Vanasse is still not entitled to an equitable share of what he actually received.

[160] Second, there is the finding of the Court of Appeal that the trial judge failed to take into account evidence of Mr. Seguin's numerous and significant non-financial contributions to the family. I respectfully cannot accept this view. The trial judge specifically alluded to these contributions in her reasons. Moreover, by confining the period of

adoptée par la juge de première instance était raisonnable dans les circonstances, mais je souligne qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un modèle à suivre. Selon les principes juridiques que j'ai exposés, il y a peut-être de nombreuses façons de quantifier raisonnablement une indemnité. Je préfère ne pas faire d'autres commentaires généraux sur le processus de quantification dans le contexte du présent pourvoi, sauf celui-ci. Dans la mesure où les bons principes juridiques sont appliqués, et que les conclusions de fait ne sont pas entachées d'une erreur manifeste et déterminante, la cour d'appel doit faire preuve d'une grande retenue envers l'appréciation des dommages-intérêts par un juge de première instance : voir, par exemple, *Nance c. British Columbia Electric Railway Co.*, [1951] A.C. 601 (C.P.). Il convient de faire preuve de la même retenue envers le jugement motivé et minutieux du juge de première instance quant à l'indemnité pécuniaire appropriée pour corriger un enrichissement injustifié. Il me faut aborder deux derniers points précis.

[159] Monsieur Seguin prétend, très brièvement, qu'une application juste de la méthode fondée sur la « valeur accumulée » commanderait que l'on fasse une analyse attentive afin de déterminer la valeur des contributions des tiers à la croissance de Fastlane pendant la période où il avait réduit ses propres contributions, à la suite de ce que l'avocat appelle les « exigences » de M^{me} Vanasse, qui voulait qu'il diminue ses heures de travail et qu'ils retournent à Ottawa. Cet argument postule qu'il n'avait pas à partager l'argent provenant de la vente avec M^{me} Vanasse. Je ne peux pas accepter ce postulat. La raison pour laquelle il a reçu plus que sa part à la vente de l'entreprise ou pour laquelle, ayant reçu plus qu'il ne le devait, M^{me} Vanasse n'a toujours pas droit à une part équitable de ce qu'il a reçu, demeure inexpliquée.

[160] Aussi, il y a la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle la juge de première instance n'a pas pris en considération la preuve des nombreuses et importantes contributions non financières de M. Seguin au bien-être de la famille. Avec égards, je ne peux pas souscrire à cette conclusion. La juge de première instance a expressément mentionné ces

unjust enrichment to the three and one-half year period, the trial judge took into account the periods during which Ms. Vanasse's contributions were not disproportionate to Mr. Seguin's. In my view, the trial judge took a realistic and practical view of the evidence before her and gave sufficient consideration to Mr. Seguin's contributions.

D. *Disposition*

[161] I would allow the appeal, set aside the order of the Court of Appeal, and restore the order of the trial judge. The appellant should have her costs throughout.

V. The Kerr Appeal

A. *Introduction*

[162] When their common law relationship of more than 25 years ended, Ms. Kerr sued her former partner, Mr. Baranow, advancing claims for unjust enrichment, resulting trust, and spousal support. Mr. Baranow counterclaimed that Ms. Kerr had been unjustly enriched by his housekeeping services provided between 1991 and 2006, and by his early retirement in order to provide her personal assistance. The trial judge awarded Ms. Kerr \$315,000, holding that she was entitled to this amount both by way of resulting trust (to reflect her contribution to the acquisition of property) and by way of remedial constructive trust (as a remedy for her successful claim in unjust enrichment). He also awarded Ms. Kerr \$1,739 per month in spousal support effective the date she commenced proceedings. Although the trial judge rejected Mr. Baranow's assertion that Ms. Kerr had been unjustly enriched at his expense, the reasons for judgment and the order after trial do not otherwise address Mr. Baranow's counterclaim.

contributions dans ses motifs. En outre, en limitant la période d'enrichissement injustifié à une période de trois ans et demi, la juge de première instance a tenu compte des périodes pendant lesquelles les contributions de M^{me} Vanasse n'étaient pas disproportionnées par rapport à celles de M. Seguin. À mon avis, la juge de première instance s'est prononcée de manière réaliste et pratique quant à la preuve dont elle disposait et a suffisamment tenu compte des contributions de M. Seguin.

D. *Dispositif*

[161] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir l'ordonnance de la juge de première instance. L'appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

V. Le pourvoi Kerr

A. *Introduction*

[162] Quand leur union de fait a pris fin après plus de 25 ans, M^{me} Kerr a intenté une action contre son ancien conjoint, M. Baranow, concluant à l'enrichissement injustifié, à l'imposition d'une fiducie résultoire et à l'octroi d'une pension alimentaire. Par une demande reconventionnelle, M. Baranow a cherché à faire reconnaître que M^{me} Kerr s'était injustement enrichie grâce aux services d'entretien ménager qu'il lui avait rendus entre 1991 et 2006, grâce aussi à la retraite anticipée prise pour lui apporter une aide personnelle. Le juge de première instance a accordé 315 000 \$ à M^{me} Kerr, estimant qu'elle avait droit à ce montant par application de la fiducie résultoire (pour refléter sa contribution à l'acquisition de biens) et par application de la fiducie constructoire de nature réparatoire (comme réparation pour enrichissement injustifié). Il a également accordé à M^{me} Kerr une pension alimentaire mensuelle de 1 739 \$, rétroactive à la date d'introduction de l'instance. Bien que le juge de première instance ait rejeté l'affirmation de M. Baranow selon laquelle M^{me} Kerr s'était injustement enrichie à ses dépens, les motifs du jugement et l'ordonnance rendue n'abordent pas par ailleurs la question de la demande reconventionnelle de M. Baranow.

[163] Mr. Baranow appealed. The Court of Appeal allowed the appeal, concluding that Ms. Kerr's claims for a resulting trust and in unjust enrichment should be dismissed, that Mr. Baranow's claim for unjust enrichment should be remitted to the trial court for determination, and that the order for spousal support should be effective as of the first day of the trial, not as of the date proceedings were commenced.

[164] Ms. Kerr appeals, submitting that the Court of Appeal erred by setting aside the trial judge's findings that:

- (1) a resulting trust arose in her favour;
- (2) she had unjustly enriched Mr. Baranow; and
- (3) spousal support should begin as of the date she instituted proceedings.

[165] In my view, the Court of Appeal was right to set aside the trial judge's findings of resulting trust and unjust enrichment. It also did not err in directing that Mr. Baranow's counterclaim be returned to the Supreme Court of British Columbia for hearing. However, my view is that Ms. Kerr's unjust enrichment claim should not have been dismissed, but rather a new trial ordered. While the trial judge's errors certainly were not harmless, it is not possible to say on this record, which includes findings of fact tainted by clear error, that her unjust enrichment claim would inevitably fail if analyzed using the clarified legal framework set out above. With respect to the commencement date of the spousal support order, I would set aside the order of the Court of Appeal and restore the trial judge's order.

B. *Overview of the Facts*

[166] The trial judge's disposition of both the resulting trust and unjust enrichment claims

[163] Monsieur Baranow a interjeté appel. La Cour d'appel a accueilli l'appel, concluant que les demandes de M^{me} Kerr relatives à une fiducie résultoire et un enrichissement injustifié devaient être rejetées, que la demande de M. Baranow fondée sur l'enrichissement injustifié devait être renvoyée au juge de première instance pour qu'il tranche à nouveau la question et que l'ordonnance de pension alimentaire devait rétroagir à la date du premier jour du procès, et non à la date d'introduction de l'instance.

[164] Madame Kerr fait appel de cette décision et plaide que la Cour d'appel a commis une erreur en écartant les conclusions du juge de première instance selon lesquelles :

- (1) une fiducie résultoire a été créée en sa faveur;
- (2) M. Baranow s'est injustement enrichi grâce à elle;
- (3) la pension alimentaire devait être versée à compter de la date d'introduction de l'action.

[165] À mon avis, la Cour d'appel a eu raison d'écarter les conclusions de première instance en ce qui concerne la fiducie résultoire et l'enrichissement injustifié. Elle n'a pas non plus commis d'erreur en ordonnant le renvoi de la demande reconventionnelle de M. Baranow à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cependant, j'estime qu'au lieu de rejeter la demande de M^{me} Kerr fondée sur l'enrichissement injustifié, la cour d'appel aurait dû ordonner la tenue d'un nouveau procès. Les erreurs du juge de première instance n'étaient certes pas inoffensives, mais il est impossible de dire au vu du dossier, qui comprend des conclusions de fait clairement erronées, que la demande fondée sur l'enrichissement injustifié était vouée à l'échec si elle avait été analysée à l'aide du cadre juridique précisé ci-dessus. En ce qui concerne la date d'exécution de l'ordonnance alimentaire, je suis d'avis d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir l'ordonnance de première instance.

B. *Aperçu des faits*

[166] La conclusion du juge de première instance en ce qui concerne les allégations de fiducie

turned on his conclusion that Ms. Kerr had provided \$60,000 worth of equity and assets at the beginning of the relationship. This fact, in the trial judge's view, supported awarding her one-third of the value of the home she shared with Mr. Baranow at the time of separation. According to the trial judge, this \$60,000 of equity and assets consisted of three elements: her \$37,000 of equity in the Coleman Street home she had shared with her former husband; the value of an automobile; and the value of furniture which she brought into her relationship with Mr. Baranow. The trial judge did not make specific findings of fact about the value of either Ms. Kerr's or Mr. Baranow's non-monetary contributions to the relationship. As previously noted, while the judge rejected in a single sentence Mr. Baranow's contention that Ms. Kerr had been unjustly enriched at his expense, the judge did not explain the basis of that conclusion. Mr. Baranow's counterclaim was not otherwise addressed.

[167] The trial judge's findings of fact, of course, must be accepted unless tainted with clear and determinative error. In this case, however, the Court of Appeal's intervention on some of the judge's key findings was justified, because those findings simply were not supported by the record. I will have to delve into the facts, more than might otherwise be required, to explain why.

[168] The parties began to live together in Mr. Baranow's home on Wall Street in Vancouver in May 1981. Shortly afterward, they moved into Ms. Kerr's former matrimonial home on Coleman Street. They had met at their mutual place of work, the Port of Vancouver, where she worked as a secretary and he as a longshoreman. Ms. Kerr was in midst of a divorce. Through her separation agreement, Ms. Kerr received her husband's interest in their former matrimonial home on Coleman Street in North Vancouver, all of the furniture in the house, and a 1979 Cadillac Eldorado. However,

résultaire et d'enrichissement injustifié reposait sur le fait que M^{me} Kerr avait fourni des capitaux et des actifs d'une valeur de 60 000 \$ au début de la relation. Ce fait, selon le juge de première instance, justifiait de lui accorder un tiers de la valeur de la maison qu'elle partageait avec M. Baranow au moment de la séparation. Selon le juge de première instance, ces capitaux et actifs de 60 000 \$ englobaient trois éléments : 37 000 \$ en valeur nette de la maison de la rue Coleman qu'elle a partagée avec son ex-époux; la valeur d'une automobile; et la valeur des meubles qu'elle possédait avant de rencontrer M. Baranow. Le juge de première instance n'a tiré aucune conclusion de fait précise à propos de la valeur des contributions non financières de M^{me} Kerr ou de M. Baranow. Comme je l'ai déjà dit, bien que le juge ait rejeté en une seule phrase la prétention de M. Baranow voulant que M^{me} Kerr se soit injustement enrichie à ses dépens, il n'a pas expliqué le fondement de cette conclusion. La demande reconventionnelle de M. Baranow n'a pas été considérée.

[167] Les conclusions de fait du juge de première instance doivent évidemment être acceptées à moins qu'elles ne soient entachées d'une erreur manifeste et déterminante. Cependant, en l'espèce, l'intervention de la Cour d'appel à l'égard de quelques-unes des principales conclusions du juge était justifiée parce que ces conclusions n'étaient pas étayées par le dossier. Je vais devoir étudier les faits, plus qu'il ne serait habituellement nécessaire, pour expliquer ma conclusion.

[168] Les parties ont commencé à habiter ensemble dans la maison de M. Baranow sur la rue Wall, à Vancouver, en mai 1981. Peu de temps après, ils ont déménagé dans l'ancien domicile conjugal de M^{me} Kerr sur la rue Coleman. Ils s'étaient rencontrés au port de Vancouver, leur lieu de travail, où elle occupait un poste de secrétaire et lui, un poste de débardeur. Madame Kerr était en instance de divorce. Aux termes de l'accord de séparation, elle a reçu l'intérêt de son mari dans leur ancienne résidence familiale de la rue Coleman, à North Vancouver, tous les meubles et une Cadillac

Ms. Kerr's ex-husband owed more than \$400,000 and Ms. Kerr was guarantor of some of that debt.

[169] In the summer of 1981, the Coleman Street property was the subject of foreclosure proceedings and, according to the evidence, was about to be foreclosed on July 29, 1981. Ms. Kerr testified at trial that, at the time, she had two teenage children, was earning under \$30,000 a year, and had no money to save the house.

[170] Ms. Kerr instructed her lawyer to place the titles to the Coleman Street property and the vehicle into Mr. Baranow's name. Mr. Baranow paid \$33,000 in cash to secure the property against outstanding debts, and guaranteed a \$100,000 mortgage at a rate of 22 percent. He then began to make the mortgage payments and eventually refinanced the mortgage, together with that on his Wall Street property, and assumed that new mortgage himself.

[171] The couple lived together for the next 25 years, first in the Wall Street property, then at Coleman Street, then in a temporary apartment, and finally in their "dream home" which they constructed on Mr. Baranow's Wall Street property.

[172] While the parties lived together in the Coleman Street property (from September 1981 to December 1985), Mr. Baranow retained the \$450 per month he received by renting out his Wall Street property. The trial judge found that, although the parties kept their financial affairs separate, there was an arrangement by which Mr. Baranow would pay the property taxes and mortgage payments on both the Coleman Street and the Wall Street properties. The mortgage on both properties was paid off before July 1985. However, Mr. Baranow took out a \$32,000 mortgage on the Wall Street property in July 1985, which was paid in full by August 1988.

[173] The Coleman Street property was sold in August 1985 for \$138,000. This sale was at a considerable loss, taking into account the real estate

Eldorado 1979. Cependant, son ex-époux devait plus de 400 000 \$ et M^{me} Kerr était garante d'une partie de cette dette.

[169] À l'été 1981, la maison de la rue Coleman faisait l'objet de procédures de forclusion et, selon la preuve, elle était sur le point d'être saisie le 29 juillet 1981. Madame Kerr a déclaré au procès que, à ce moment-là, elle avait deux adolescents, elle gagnait moins de 30 000 \$ par année et elle n'avait pas d'argent pour conserver la maison.

[170] Madame Kerr a demandé à son avocat de céder la maison et la voiture à M. Baranow, lequel a payé 33 000 \$ en argent pour protéger la maison contre les dettes impayées et a garanti un prêt hypothécaire de 100 000 \$ à un taux de 22 pour cent. Il a ensuite commencé à faire les paiements hypothécaires, plus tard, il a refinancé l'hypothèque avec celle de sa maison de la rue Wall, et il a assumé lui-même cette nouvelle hypothèque.

[171] Le couple a vécu ensemble pendant les 25 années qui ont suivi, d'abord dans la maison de la rue Wall, puis dans celle de la rue Coleman, ensuite dans un appartement temporaire et enfin dans leur « maison de rêve » qu'ils ont fait construire sur le terrain de la rue Wall appartenant à M. Baranow.

[172] Quand les parties habitaient la maison de la rue Coleman (de septembre 1981 à décembre 1985), M. Baranow conservait le revenu de 450 \$ par mois que lui procurait la location de sa maison de la rue Wall. Le juge de première instance a conclu que, bien que les parties aient toujours géré leurs finances personnelles séparément, il y avait une entente aux termes de laquelle M. Baranow payait les taxes foncières et les hypothèques des deux résidences, celle de la rue Coleman et celle de la rue Wall. Les hypothèques ont été entièrement remboursées avant juillet 1985. Cependant, M. Baranow a contracté un prêt hypothécaire de 32 000 \$ pour la maison de la rue Wall en juillet 1985, qui a été remboursé avant août 1988.

[173] La maison de la rue Coleman a été vendue en août 1985 pour un montant de 138 000 \$. Cette vente représentait une perte importante, compte

commission, the \$33,000 in cash Mr. Baranow had contributed at the time of the transfer to him, and the mortgage payments he alone had made between the transfer in the summer of 1981 and the sale in the summer of 1985.

[174] The parties moved into an apartment (from August 1985 until October 1986) while they constructed their “dream home” at the Wall Street location. The existing dwelling was torn down and replaced. Mr. Baranow spent somewhere between \$97,000 and \$105,000 on its construction, with additional amounts spent for materials, labour and permits. Ms. Kerr, the trial judge found, was involved with the planning, interior decorating and cleaning. She also planted sod, tended the flower garden, and paid for some wood paneling in the downstairs bedroom. In addition, she made contributions towards the purchase of furniture, appliances, and other chattels for the Wall Street property. Her son paid \$350 per month in rent, which Mr. Baranow retained. At one point in his reasons, the trial judge stated that Ms. Kerr paid “all of the household expenses and the insurance on the new house . . . even after the \$32,000.00 mortgage was paid off by [Mr. Baranow] in August 1988” (para. 24). However, at another point, the judge noted that Ms. Kerr paid the utilities and insurance and bought “some groceries” (para. 36). Mr. Baranow, he found, paid the property-related expenses, consisting of property taxes (less the disability benefit attributable to Ms. Kerr) and upkeep (which was minimal in the new house). The trial judge found that the current value of the Wall Street property was \$942,500, compared with \$205,000 in October of 1986. He then concluded that, given there were no mortgage payments after 1988, Ms. Kerr’s share of the expenses “was probably higher” than Mr. Baranow’s for approximately 18 years before they stopped living together.

[175] In 1991, Ms. Kerr suffered a massive stroke and cardiac arrest, leaving her paralyzed on her left side and unable to return to work. Her health steadily deteriorated, and relations between the couple became increasingly strained. Mr. Baranow took an

tenu de la commission de l’agent immobilier, du montant de 33 000 \$ payé par M. Baranow au moment du transfert, et des paiements hypothécaires qu’il a faits entre le transfert à l’été 1981 et la vente à l’été 1985.

[174] Les parties ont emménagé dans un appartement (d’août 1985 à octobre 1986) pendant la construction de leur « maison de rêve » sur la rue Wall. L’habitation existante a été démolie et remplacée. Monsieur Baranow a dépensé entre 97 000 \$ et 105 000 \$ pour la construction, plus les matériaux, la main-d’œuvre et les permis. Selon le juge de première instance, M^{me} Kerr s’occupait de la planification, de la décoration intérieure et du nettoyage. Elle a aussi semé du gazon, entretenu le jardin de fleurs et payé du lambris pour la chambre du sous-sol. De plus, elle a contribué à l’achat des meubles, des électroménagers et d’autres effets pour la maison de la rue Wall. Son fils payait un loyer mensuel de 350 \$, montant que M. Baranow conservait. Dans un passage de ses motifs, le juge de première instance a affirmé que M^{me} Kerr payait [TRADUCTION] « toutes les dépenses du ménage et les assurances de la nouvelle maison [. . .] même après que [M. Baranow] eût remboursé l’hypothèque de 32 000 \$ en août 1988 » (par. 24). Toutefois, ailleurs dans ses motifs, il a souligné que M^{me} Kerr payait les services publics et l’assurance et elle faisait « parfois le marché » (par. 36). Selon lui, M. Baranow payait les dépenses liées à la propriété, soit les taxes foncières (moins la prestation d’invalidité de M^{me} Kerr) et les frais d’entretien (qui étaient minimes dans la nouvelle maison). Le juge de première instance a conclu que la maison de la rue Wall valait 942 500 \$, comparativement à 205 000 \$ en octobre 1986. Il a ensuite conclu que, comme il n’y avait plus de paiements hypothécaires à faire après 1988, la part des dépenses de M^{me} Kerr [TRADUCTION] « a été probablement plus élevée » que celle de M. Baranow pendant environ 18 ans, jusqu’à ce qu’ils n’habitent plus ensemble.

[175] En 1991, M^{me} Kerr a été victime d’un grave accident vasculaire cérébral et d’un arrêt cardiaque, qui l’ont laissée paralysée du côté gauche et l’ont rendue inapte au travail. Sa santé s’est progressivement détériorée et la relation du couple est devenue

early retirement in 2002. The trial judge acknowledged that Mr. Baranow claimed to have done this to care for Ms. Kerr, but noted that early retirement was also favourable to him. The trial judge found that Mr. Baranow started to experience “caregiver fatigue” and began exploring institutional care alternatives in June 2005. The next summer, in August 2006, Ms. Kerr had to undergo surgery on her knee. After the surgery, Mr. Baranow made it clear to the hospital staff that he was not prepared to have her return home. Ms. Kerr was transferred to an extended care facility where she remained at the time of trial. The trial judge found that, in the last 18 months Ms. Kerr resided at the Wall Street property, Mr. Baranow did most of the housework and helped her with her bodily functions.

C. Analysis

(1) The Resulting Trust Issue

[176] The trial judge found that Mr. Baranow held a one-third interest in the Wall Street property by way of resulting trust for Ms. Kerr, on three bases. The Court of Appeal found that each of these holdings was erroneous. I respectfully agree.

(a) *Gratuitous Transfer*

[177] The trial judge found that the transfer of the Coleman Street property to Mr. Baranow was gratuitous, therefore raising the presumption of a resulting trust in Ms. Kerr’s favour. At the time of transfer to Mr. Baranow, roughly \$133,000 was required to save the property (it was subject to a first mortgage of just under \$80,000, a second mortgage of just under \$35,000, a judgment in favour of the Bank of Montreal of just under \$12,000, and other miscellaneous debts and charges, adding up to roughly \$133,000). There was also a \$26,500 judgment in favour of CIBC, which was of concern

de plus en plus tendue. Monsieur Baranow a pris une retraite anticipée en 2002. Le juge de première instance a reconnu que M. Baranow avait dit avoir pris sa retraite pour prendre soin de M^{me} Kerr, mais il a fait remarquer que cette retraite favorisait aussi M. Baranow. Selon le juge de première instance, M. Baranow a commencé à ressentir une certaine fatigue liée à son rôle d’aidant naturel et à chercher dès juin 2005 des solutions pour qu’elle reçoive des soins en établissement. L’été suivant, en août 2006, M^{me} Kerr a dû subir une chirurgie du genou. Après la chirurgie, M. Baranow a clairement indiqué au personnel hospitalier qu’il n’était pas prêt à la ramener à la maison. Madame Kerr a été transférée dans un établissement de soins prolongés où elle demeurait au moment du procès. Le juge de première instance a conclu que, dans les 18 derniers mois où M^{me} Kerr habitait la maison de la rue Wall, M. Baranow s’occupait de la majeure partie des tâches ménagères et lui prodiguait des soins personnels.

C. Analyse

(1) La question de la fiducie résultoire

[176] S’appuyant sur trois motifs, le juge de première instance est arrivé à la conclusion que M. Baranow détenait un tiers de la valeur de la maison de la rue Wall au titre d’une fiducie résultoire pour M^{me} Kerr. La Cour d’appel a conclu que chacun de ces motifs était erroné. Avec égards, je suis aussi de cet avis.

a) *Transfert à titre gratuit*

[177] Le juge de première instance a conclu que le transfert du titre de la maison de la rue Coleman à M. Baranow a été fait à titre gratuit, créant ainsi la présomption de fiducie résultoire en faveur de M^{me} Kerr. Au moment du transfert, il fallait environ 133 000 \$ pour conserver la propriété (elle était grevée d’une première hypothèque d’un peu moins de 80 000 \$ et d’une deuxième hypothèque d’un peu moins de 35 000 \$, d’un jugement en faveur de la Banque de Montréal d’un peu moins de 12 000 \$ et d’autres dettes et charges diverses, pour une dette totale d’environ 133 000 \$). Il y avait aussi

to Ms. Kerr, although it is not listed in the payouts required to close the transfer. We know that Ms. Kerr had guaranteed some of her former husband's debts, and that she declared bankruptcy in 1983 in relation to \$15,000 of debt for which she had co-signed with her former husband.

[178] The Court of Appeal reversed the trial judge's resulting trust finding, holding that the transfer was not gratuitous. The court pointed to the contributions and liabilities undertaken by Mr. Baranow to make the transfer possible, and concluded that the trial judge's finding in this regard constituted a palpable and overriding error.

[179] On this point, I respectfully agree with the Court of Appeal. There is no dispute that Mr. Baranow injected roughly \$33,000 in cash, and guaranteed a \$100,000 mortgage, so that the property would not be lost to the bank in the foreclosure proceedings. This constituted consideration, and the transfer therefore cannot reasonably be labelled gratuitous. The respondent would have us hold otherwise on the basis of technical arguments about the lack of a precise coincidence between the time of the transfer and payments, and the lack of payment directly to Ms. Kerr because Mr. Baranow's payments were made to her creditors. These arguments have no merit. An important element of the trial judge's finding of a resulting trust was his conclusion that there was "no evidence" that Mr. Baranow's payment of \$33,000 in cash and his guarantee of the \$100,000 mortgage "were in connection with the transfer or part of an agreement between the parties so as to constitute consideration for the transfer" (para. 76). Putting to one side for the moment whether this finding reflects a correct understanding of a gratuitous transfer, the judge clearly erred in making this statement; there was in fact much evidence to that precise effect. Mr. Baranow testified that Ms. Kerr had "tearfully asked" Mr. Baranow for help to save the property from the creditors. Ms. Kerr's solicitor recorded in his reporting letter that Ms. Kerr felt she had little choice but to convey the property to Mr. Baranow

un jugement de 26 500 \$ en faveur de la CIBC, qui préoccupait M^{me} Kerr, bien qu'il ne figure pas dans la liste des paiements à faire pour conclure le transfert. Nous savons que M^{me} Kerr était garante d'une partie des dettes de son ex-époux et qu'elle a fait faillite en 1983 relativement à une dette de 15 000 \$ dont elle était cosignataire avec son ex-époux.

[178] La Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance à propos de la fiducie résultoire, concluant que le transfert n'a pas été fait à titre gratuit. Elle a signalé les contributions et les responsabilités assumées par M. Baranow pour rendre le transfert possible, et a statué que la conclusion du juge de première instance à cet égard constituait une erreur manifeste et dominante.

[179] À cet égard, je partage l'opinion de la Cour d'appel. Nul ne conteste que M. Baranow a investi environ 33 000 \$ en argent et a garanti un prêt hypothécaire de 100 000 \$ pour éviter la saisie de la propriété par la banque. Cela constituait une contrepartie, et le transfert ne peut donc pas être raisonnablement considéré comme étant à titre gratuit. Selon l'intimé, il faudrait conclure le contraire en se fondant sur des arguments techniques à propos de l'absence de coïncidence précise entre le moment du transfert et des paiements et le fait que ceux-ci n'ont pas été faits directement à M^{me} Kerr, M. Baranow les ayant versés à ses créanciers. Ces arguments sont dénués de fondement. Un élément important de la conclusion du juge de première instance en ce qui a trait à l'existence d'une fiducie résultoire était le fait qu'il n'existait [TRADUCTION] « aucune preuve » selon laquelle le paiement en argent de 33 000 \$ effectué par M. Baranow et sa garantie de l'hypothèque de 100 000 \$ « étaient liés au transfert ou faisaient partie d'une entente entre les parties de sorte qu'ils constituaient une contrepartie au transfert » (par. 76). Si l'on fait abstraction pour le moment de la question de savoir si cette conclusion reflète bien la notion de transfert à titre gratuit, cette affirmation du juge est clairement erronée; il existait en effet de nombreux éléments de preuve en ce sens. Monsieur Baranow a affirmé que M^{me} Kerr lui avait [TRADUCTION] « demandé

“faced with the large outstanding debts of [her] husband which include[d] a Judgment taken by C.I.B.C. for a debt outstanding in the amount of \$26,500.00”. At trial, Ms. Kerr was asked whether she had requested Mr. Baranow to save the house; she responded, “I guess so.” Thus, contrary to the judge’s finding, there was in fact considerable evidence that Mr. Baranow’s paying off of the debts and guaranteeing the mortgage were in connection with the transfer of the property to him. This evidence shows that he accepted the transfer and assumed the financial obligations at Ms. Kerr’s request, and in order to further her purpose of preventing the creditors from foreclosing on the property.

[180] The Court of Appeal was correct to intervene on this point and conclude that the transfer was not gratuitous. The trial judge’s imposition of a resulting trust on one-third of the Wall Street property on this basis accordingly cannot be sustained.

(b) *Ms. Kerr’s Contributions*

[181] The trial judge also based his finding of resulting trust on Ms. Kerr’s financial and other contributions to the acquisition of the new home on the Wall Street property. He found Ms. Kerr had contributed a total of \$60,000: \$37,000 in equity from the transfer of the Coleman Street property to Mr. Baranow; \$20,000 for the value of the Cadillac also transferred to Mr. Baranow; and \$3,000 for the furniture in the Coleman Street property. In addition, the trial judge noted that, in obtaining the legal title of Coleman, Mr. Baranow was able to “re-mortgage both properties for \$116,000.00 and apply the \$16,000.00 toward the acquisition of the Wall Street Property” (para. 82). Furthermore, Mr. Baranow would not have been able to pay off the mortgages with the same efficiency but for Ms. Kerr’s contributions to household expenses. However, the trial judge did not attach any value to these last two matters in his determination of the

en pleurant » de l’aider à protéger la propriété des créanciers. L’avocat de M^{me} Kerr a noté dans sa lettre-rapport qu’elle avait l’impression de n’avoir d’autre choix que de céder la maison à M. Baranow [TRADUCTION] « compte tenu des lourdes dettes de [son] mari qui inclu[aient] un jugement en faveur de la CIBC pour une dette de 26 500 \$ ». Au procès, on a demandé à M^{me} Kerr si elle avait demandé à M. Baranow de sauver la maison et elle a répondu : [TRADUCTION] « Je suppose. » Ainsi, contrairement à la conclusion du juge, de nombreux éléments de preuve indiquaient que M. Baranow avait remboursé les dettes et garanti l’hypothèque parce que la maison lui avait été transférée. La preuve montre qu’il a accepté le transfert et assumé les obligations financières à la demande de M^{me} Kerr, et aussi dans le but d’éviter que les créanciers saisissent la propriété.

[180] La Cour d’appel a eu raison d’intervenir sur ce point et de conclure que le transfert n’avait pas été fait à titre gratuit. L’imposition, par le juge de première instance, d’une fiducie résultoire sur le tiers de la valeur de la maison de la rue Wall pour cette raison ne peut donc être maintenue.

b) *Les contributions de M^{me} Kerr*

[181] Le juge de première instance a aussi fondé sa conclusion relative à l’existence d’une fiducie résultoire sur les contributions financières et non financières de M^{me} Kerr à l’acquisition de la nouvelle maison sur la rue Wall. Selon lui, M^{me} Kerr avait versé un total de 60 000 \$: 37 000 \$ en valeur nette provenant du transfert de la résidence de la rue Coleman à M. Baranow; une Cadillac d’une valeur de 20 000 \$ aussi transférée à M. Baranow; et des meubles de la maison de la rue Coleman d’une valeur de 3 000 \$. De plus, le juge de première instance a fait remarquer que, en obtenant le titre légal de la maison de la rue Coleman, M. Baranow était en mesure de [TRADUCTION] « réhypothéquer les deux propriétés pour une valeur de 116 000 \$ et d’utiliser 16 000 \$ pour acquérir la maison de la rue Wall » (par. 82). En outre, M. Baranow n’aurait pas pu rembourser les prêts hypothécaires aussi diligemment sans les contributions de M^{me} Kerr

extent of the resulting trust which he imposed on the Wall Street property.

[182] The Court of Appeal reversed this finding as not being supported by the record. The court noted that Ms. Kerr did not have \$37,000 in equity in the Coleman Street property when Mr. Baranow took title, Mr. Baranow did not receive any beneficial interest in the vehicle, and there was no evidence of the value of the furnishings.

[183] I agree with the Court of Appeal's disposition of this issue. As it pointed out, the evidence showed that, in addition to Mr. Baranow paying cash and guaranteeing a mortgage, he paid the monthly mortgage payments, taxes and upkeep expenses on the Coleman property until it was sold in 1985 for \$138,000 (less real estate commission). Mr. Baranow received no beneficial interest in the vehicle and the judge made no finding about the value of the furnishings. There was not, in any meaningful sense of the word, any equity in the Coleman property for Ms. Kerr to contribute to the acquisition or improvement of the Wall Street property. I would affirm the conclusion of the Court of Appeal on this point.

(c) *Common Intention Resulting Trust*

[184] The trial judge also appears to have based his conclusions about the resulting trust on his finding of a common intention on the part of Ms. Kerr and Mr. Baranow to share in the Wall Street property. For the reasons I have given earlier, the "common intention" resulting trust has no further role to play in the resolution of disputes such as this one. I would hold that a resulting trust should not have been imposed on the Wall Street property on the basis of a finding of common intention between these parties.

aux dépenses du ménage. Cependant, le juge de première instance n'a attribué aucune valeur à ces deux derniers points dans sa décision quant à la portée de la fiducie résultoire qu'il a imposée relativement à la maison de la rue Wall.

[182] La Cour d'appel a écarté cette conclusion au motif qu'elle n'était pas étayée par le dossier. Elle a fait remarquer que M^{me} Kerr ne détenait pas 37 000 \$ en valeur nette de la maison de la rue Coleman au moment où M. Baranow en a acquis le titre, que M. Baranow n'a reçu aucun intérêt bénéficiaire dans le véhicule et qu'il n'y avait aucune preuve de la valeur des meubles.

[183] Je souscris à la façon dont la Cour d'appel a tranché ce point. Comme elle l'a souligné, la preuve démontrait que, outre le fait que M. Baranow a payé en argent et garanti une hypothèque, il a versé les paiements hypothécaires mensuels, a payé les taxes et les frais d'entretien de la maison de la rue Coleman jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 1985 pour un montant de 138 000 \$ (moins la commission de l'agent immobilier). Monsieur Baranow n'a reçu aucun intérêt bénéficiaire dans le véhicule et le juge ne s'est pas prononcé sur la valeur des meubles. En réalité, M^{me} Kerr n'a retiré de la maison de la rue Coleman aucune valeur nette lui permettant de contribuer à l'acquisition ou à l'amélioration de la maison de la rue Wall. Je suis d'avis de confirmer la conclusion de la Cour d'appel sur ce point.

c) *Fiducie résultoire fondée sur l'intention commune*

[184] Le juge de première instance semble aussi avoir fondé ses conclusions relatives à la fiducie résultoire sur l'existence d'une intention commune, de la part de M^{me} Kerr et de M. Baranow, de partager la propriété de la rue Wall. Pour les motifs que j'ai déjà exposés, la fiducie résultoire fondée sur « l'intention commune » n'a plus aucun rôle à jouer dans le règlement d'un litige tel que celui-ci. J'estime qu'une fiducie résultoire n'aurait pas dû être imposée à l'égard de la propriété de la rue Wall sur la base de l'intention commune des parties.

(d) *Conclusion With Respect to Resulting Trust*

[185] In my view the Court of Appeal was correct to set aside the trial judge's conclusions with respect to the resulting trust issues.

(2) Unjust Enrichment

[186] The trial judge also found that Mr. Baranow had been unjustly enriched by Ms. Kerr to the extent of \$315,000, the value of the one-third interest in the Wall Street property determined during the resulting trust analysis. The judge found that Ms. Kerr had provided the following benefits to Mr. Baranow:

- a. \$37,000 equity in the Coleman Street property;
- b. the automobile;
- c. the furnishings;
- d. \$16,000 in refinancing permitted by the Coleman transfer and applied to the Wall Street property;
- e. \$22,000 gained on the resale of the Coleman Street property;
- f. household expenses and insurance paid on both properties;
- g. spousal services such as housework, entertaining guests and preparing meals until Ms. Kerr's disability made it impossible to continue;
- h. assistance with planning and decoration of the Wall Street house;
- i. financial contributions towards the purchase of chattels for the new home;
- j. a disability tax exemption;

d) *Conclusion relative à la fiducie résultoire*

[185] À mon avis, la Cour d'appel a eu raison d'écarter les conclusions du juge de première instance à l'égard des questions relatives à la fiducie résultoire.

(2) Enrichissement injustifié

[186] Le juge de première instance a aussi conclu que M. Baranow s'était injustement enrichi de 315 000 \$ grâce à M^{me} Kerr, soit un tiers de la valeur de la maison de la rue Wall déterminée dans le cadre de l'analyse concernant la fiducie résultoire. Il était d'avis que M^{me} Kerr avait apporté les avantages suivants à M. Baranow :

- a. une valeur nette de 37 000 \$ dans la maison de la rue Coleman;
- b. l'automobile;
- c. les meubles;
- d. 16 000 \$ au titre du refinancement provenant du transfert de la maison de la rue Coleman et utilisés pour l'acquisition de la maison de la rue Wall;
- e. 22 000 \$ tirés de la revente de la maison de la rue Coleman;
- f. les dépenses ménagères et les assurances liées aux deux résidences;
- g. des services tels que les tâches ménagères, accueillir des invités et préparer les repas jusqu'à ce que l'invalidité de M^{me} Kerr l'empêche de continuer;
- h. l'aide à la planification et à la décoration de la maison de la rue Wall;
- i. les contributions financières à l'achat de biens pour la nouvelle maison;
- j. une exemption d'impôt pour personnes handicapées;

k. approximately five years' worth of rental income from Ms. Kerr's son.

[187] Turning to the element of corresponding deprivation, the trial judge noted that it was “unlikely” that Ms. Kerr had given up any career or educational opportunities over the course of the relationship. Furthermore, her income remained unchanged, even following her stroke, due to her receipt of disability pensions and other benefits. The judge found that she had lived rent-free for the entire relationship. He concluded, however, that she had suffered a deprivation because, had she not contributed her equity in the Coleman Street property, it was “reasonable to infer that she would have used it to purchase an asset in her own name, invest for her own benefit, use it for some personal interest, or otherwise avail herself of beneficial financial opportunity”: para. 92. He also concluded, without elaboration, that the benefits that she received from the relationship did not overtake her contributions.

[188] The Court of Appeal set aside the trial judge's finding of unjust enrichment. It found that Mr. Baranow's direct and indirect contributions, by which Ms. Kerr was enriched and for which he was not compensated, constituted a juristic reason for any enrichment which he experienced at her expense. The court found that, for reasons mentioned earlier, there was no \$60,000 contribution by Ms. Kerr and therefore her claim rested on her indirect contributions. The court also concluded that the trial judge's analysis failed to assess the extent of Mr. Baranow's direct and indirect contributions to Ms. Kerr, including: his payment of accommodation expenses for the duration of the relationship; his contribution to the purchase price of the van which Ms. Kerr still possesses; her receipt of almost half of his lifetime amount of union medical benefits, used to pay for her health care expenses; his taking early retirement with a reduced monthly pension to care for Ms. Kerr; and his provision of extensive personal caregiver and domestic services without compensation. Moreover, in the Court of Appeal's view, the trial judge had failed to note that Mr. Baranow's payment of her living expenses

k. l'équivalent du revenu de location du fils de M^{me} Kerr durant environ cinq ans.

[187] En ce qui concerne l'appauvrissement correspondant, le juge de première instance a souligné qu'il était [TRADUCTION] « peu probable » que M^{me} Kerr ait renoncé à une carrière ou à des possibilités de s'instruire pendant sa relation. De plus, son revenu est resté inchangé, même après son accident vasculaire cérébral, parce qu'elle touchait des prestations d'invalidité et d'autres avantages. Selon le juge, elle n'a pas eu à payer de loyer pendant toute la durée de la relation. Il est toutefois arrivé à la conclusion qu'elle avait subi un appauvrissement parce que, si elle n'avait pas investi la valeur nette de la maison de la rue Coleman, il était [TRADUCTION] « raisonnable d'inférer qu'elle l'aurait utilisée pour acheter un bien à son propre nom, investir pour elle-même, nourrir un intérêt personnel, ou autrement profiter d'une belle occasion d'affaires » : par. 92. Il a aussi conclu, sans plus d'explications, que les avantages qu'elle a tirés de la relation n'ont pas dépassé ses contributions.

[188] La Cour d'appel a écarté la conclusion du juge de première instance en ce qui concerne l'enrichissement injustifié. Elle a conclu que les contributions directes et indirectes de M. Baranow, grâce auxquelles M^{me} Kerr s'est enrichie et pour lesquelles il n'a pas été compensé, constituaient un motif juridique justifiant l'enrichissement, le cas échéant, de M. Baranow au détriment de M^{me} Kerr. Selon la Cour d'appel, pour les motifs exposés ci-dessus, M^{me} Kerr n'a pas versé une contribution de 60 000 \$ et, par conséquent, sa demande reposait sur ses contributions indirectes. Toujours selon la Cour d'appel, le juge de première instance n'a pas évalué l'étendue des contributions directes et indirectes versées par M. Baranow à M^{me} Kerr, y compris : les frais d'hébergement qu'il a payés pendant toute la durée de la relation; sa contribution à l'acquisition de la fourgonnette que M^{me} Kerr possède toujours; le fait qu'elle a bénéficié de près de la moitié de son régime viager d'assurance-maladie des employés, pour payer ses soins de santé; le fait qu'il ait pris une retraite anticipée avec une prestation mensuelle réduite pour prendre soin de M^{me} Kerr; et le fait qu'il ait fourni d'importants services de soins personnels

permitted her to save about \$272,000 over the course of the relationship.

[189] The appellant challenges the Court of Appeal's decision on two bases. First, she argues that the court improperly interfered with the trial judge's finding of fact with respect to Ms. Kerr's \$60,000 contribution to the relationship. Second, she submits that the court improperly considered the question of mutual benefits through the lens of juristic reason, and that this resulted in the court failing to consider globally who had been enriched and who deprived. Ms. Kerr's submission on this latter point is that consideration of mutual benefit conferral should occur during the first two steps of the unjust enrichment analysis: enrichment and corresponding deprivation. Once that has been established, she argues that the legitimate expectations of the parties may be considered as part of the analysis of whether there was a juristic reason for the enrichment. The main point is that, in the appellant's submission, it was open to the trial judge to conclude that the parties' legitimate expectation was that they would accumulate wealth in proportion to their respective incomes; without a share of the value of the real property acquired during the relationship, that reasonable expectation cannot be realized.

[190] More fundamentally, the appellant urges the Court to adopt what she calls the "family property approach" to unjust enrichment. In essence, the appellant submits that her contributions gave rise to a reasonable expectation that she would have an equitable share of the assets acquired during the relationship.

[191] I will deal with these submissions in turn.

(a) *Findings of Fact Regarding the \$60,000 Contribution*

[192] As noted earlier, the Court of Appeal was right to set aside the trial judge's conclusion that the

et des services domestiques sans compensation. De plus, la Cour d'appel est d'avis que le juge de première instance n'a pas pris en considération que le fait que M. Baranow a payé les frais de subsistance de M^{me} Kerr a permis à cette dernière d'économiser environ 272 000 \$ au cours de la relation.

[189] L'appelante conteste la décision de la Cour d'appel pour deux raisons. Premièrement, elle soutient que la Cour d'appel a eu tort de modifier la conclusion de fait du juge de première instance relativement à sa contribution de 60 000 \$. Deuxièmement, elle prétend que la Cour d'appel a eu tort d'examiner la question des avantages réciproques en fonction du motif juridique, et qu'elle n'a donc pas cherché à savoir globalement qui s'est enrichi et qui s'est appauvri. Sur ce dernier point selon M^{me} Kerr, il faudrait procéder à l'examen des avantages réciproques aux deux premières étapes de l'analyse de la question de l'enrichissement injustifié : l'enrichissement et l'appauvrissement correspondant. Une fois cette preuve faite, elle prétend que les attentes légitimes des parties peuvent être prises en considération dans le cadre de l'analyse de la question de savoir s'il y avait un motif juridique de l'enrichissement. L'essentiel, selon l'argument de l'appelante, est que le juge de première instance pouvait donc conclure que les parties s'attendaient légitimement à accumuler une richesse proportionnelle à leur revenu respectif; sans une part de la valeur de l'immeuble acquis pendant la relation, cette attente raisonnable ne peut se réaliser.

[190] Plus fondamentalement, l'appelante exhorte la Cour à adopter ce qu'elle appelle la « méthode fondée sur l'avoir familial » en matière d'enrichissement injustifié. Essentiellement, elle prétend que ses contributions lui permettaient de s'attendre raisonnablement à recevoir une part équitable des biens acquis pendant la relation.

[191] Je vais examiner chacune de ces prétentions.

a) *Conclusions de fait quant à la contribution de 60 000 \$*

[192] Comme je l'ai déjà mentionné, la Cour d'appel avait raison d'écarter la conclusion du

appellant had contributed \$60,000 to the couple's assets. There was, in no realistic sense of the word, any "equity" to contribute from the Coleman Street property to acquisition of the new Wall Street "dream home". Furthermore, the appellant retained the beneficial use of the motor vehicle, and there was no satisfactory evidence of the value of the furniture. The judge's findings on this point were the product of clear and determinative error.

(b) *Analysis of Offsetting Enrichments*

[193] On this issue, I cannot accept the conclusions of either the trial judge or the Court of Appeal. As noted, in his determination of the extent of Ms. Kerr's unjust enrichment, the trial judge largely ignored Mr. Baranow's contributions. However, for the reasons I have developed earlier, the Court of Appeal erred in assessing Mr. Baranow's contributions as part of the juristic reason analysis; this analysis prematurely truncated Ms. Kerr's *prima facie* case of unjust enrichment. I have set out the correct approach to this issue earlier in my reasons. As, in my view, there must be a new trial of both Ms. Kerr's unjust enrichment claim and Mr. Baranow's counterclaim, it is not necessary to say anything further. The principles set out above must accordingly be applied at the new trial of these issues.

(c) *The "Family Property Approach"*

[194] I turn finally to Ms. Kerr's more general point that her claim should be assessed using a "family property approach". As set out earlier in my reasons, for Ms. Kerr to show an entitlement to a proportionate share of the wealth accumulated during the relationship, she must establish that Mr. Baranow has been unjustly enriched at her expense, that their relationship constituted a joint family venture, and that her contributions are linked to the generation of wealth during the relationship.

juge de première instance selon laquelle l'appelante avait contribué à l'actif du couple pour une valeur de 60 000 \$. De façon réaliste, il n'y avait aucune « valeur nette » provenant de la maison de la rue Coleman qui pouvait servir à l'acquisition de la nouvelle « maison de rêve » de la rue Wall. De plus, l'appelante a conservé l'usage bénéficiaire du véhicule et il n'y avait aucune preuve valable de la valeur des meubles. Les conclusions du juge sur ce point résultaient d'une erreur claire et déterminante.

b) *Analyse des enrichissements compensatoires*

[193] Sur ce point, je ne peux pas accepter les conclusions du juge de première instance ni celles de la Cour d'appel. Je le répète, dans sa décision au sujet de l'enrichissement injustifié de M^{me} Kerr, le juge de première instance n'a guère tenu compte des contributions de M. Baranow. Cependant, pour les raisons exposées précédemment, la Cour d'appel a commis une erreur en évaluant les contributions de M. Baranow dans le cadre de l'analyse du motif juridique; cette analyse a prématurément tronqué la preuve *prima facie* d'enrichissement injustifié de M^{me} Kerr. J'ai énoncé précédemment dans mes motifs la façon dont il convient d'aborder cette question. Comme j'estime qu'un nouveau procès doit être tenu relativement à l'allégation d'enrichissement injustifié de M^{me} Kerr et à la demande reconventionnelle de M. Baranow, il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Les principes énoncés ci-dessus doivent donc s'appliquer lors du nouveau procès sur cette question.

c) *La « méthode fondée sur l'avoir familial »*

[194] J'aborde enfin l'argument de nature plus générale de M^{me} Kerr selon lequel il faudrait évaluer sa demande suivant une « méthode fondée sur l'avoir familial ». Comme je l'ai déjà dit, pour démontrer qu'elle a droit à une part proportionnelle de la richesse accumulée pendant la relation, M^{me} Kerr doit établir que M. Baranow s'est injustement enrichi à ses dépens, que leur relation constituait une coentreprise familiale et que ses contributions sont liées à l'accumulation de la richesse pendant

She would then have to show what proportion of the jointly accumulated wealth reflects her contributions. Of course, this clarified template was not available to the trial judge or to the Court of Appeal. However, these requirements are quite different than those advanced by the appellant and accordingly her “family property approach” must be rejected.

(d) *Disposition of the Unjust Enrichment Appeal*

[195] I conclude that the findings of the trial judge in relation to unjust enrichment cannot stand. The next question is whether, as the Court of Appeal decided, Ms. Kerr’s claim for unjust enrichment should be dismissed or whether it ought to be returned for a new trial. With reluctance, I have concluded the latter course is the more just one in all of the circumstances.

[196] The first consideration in support of a new trial is that the Court of Appeal directed a hearing of Mr. Baranow’s counterclaim. Given that the trial judge unfortunately did not address that claim in any meaningful way, the Court of Appeal’s order that it be heard and decided is unimpeachable. There was evidence that Mr. Baranow made very significant contributions to Ms. Kerr’s welfare such that his counterclaim cannot simply be dismissed. As I noted earlier, the trial judge also referred to various other monetary and non-monetary contributions which Ms. Kerr made to the couple’s welfare and comfort, but he did not evaluate them, let alone compare them with the contributions made by Mr. Baranow. In these circumstances, trying the counterclaim separately from Ms. Kerr’s claim would be an artificial and potentially unfair way of proceeding.

[197] More fundamentally, Ms. Kerr’s claim was not presented, defended or considered by the courts below pursuant to the joint family venture analysis that I have set out. Even assuming that Ms. Kerr

la relation. Elle devrait ensuite démontrer quelle proportion de la richesse accumulée conjointement correspond à ses contributions. Bien sûr, le juge de première instance et la Cour d’appel n’avaient pas accès à ce modèle clarifié. Cependant, ces exigences sont bien différentes de celles avancées par l’appelante, de sorte que sa « méthode fondée sur l’avoir familial » doit être rejetée.

d) *Décision sur la question de l’enrichissement injustifié*

[195] Je conclus que les conclusions du juge de première instance en matière d’enrichissement injustifié ne peuvent être maintenues. La question suivante est de savoir si, comme l’a jugé la Cour d’appel, il convient de rejeter la demande de M^{me} Kerr fondée sur l’enrichissement injustifié ou de la renvoyer pour qu’elle fasse l’objet d’un nouveau procès. Bien qu’à contrecœur, j’estime que la dernière option est la plus équitable dans les circonstances.

[196] La première considération à l’appui d’un nouveau procès est que la Cour d’appel a ordonné l’audition de la demande reconventionnelle de M. Baranow. Comme le juge de première instance n’a malheureusement pas examiné cette demande de manière significative, l’ordonnance de la Cour d’appel sur ce point est inattaquable. Certains éléments de preuve indiquaient que M. Baranow a contribué de façon importante au bien-être de M^{me} Kerr de sorte que sa demande reconventionnelle ne peut simplement pas être rejetée. Comme je l’ai déjà dit, le juge de première instance a aussi mentionné diverses autres contributions financières et non financières apportées par M^{me} Kerr au bien-être et au confort du couple, mais il ne les a pas évaluées et les a encore moins comparées à celles de M. Baranow. Dans ces circonstances, il serait artificiel et potentiellement injuste d’entendre la demande reconventionnelle de M. Baranow séparément de celle de M^{me} Kerr.

[197] Fondamentalement, la demande de M^{me} Kerr n’a pas été présentée, défendue ni examinée par les tribunaux d’instance inférieure suivant la méthode d’analyse de la coentreprise familiale que

made out her claim in unjust enrichment, it is not possible to fairly apply the joint family venture approach to this case on appeal, using the record available to this Court. There are few findings of fact relevant to the key question of whether the parties' relationship constituted a joint family venture. Moreover, even if one were persuaded that the evidence permitted resolution of the joint family venture issue, the record is unsatisfactory for deciding whether Ms. Kerr's contributions to a joint family venture were linked to the accumulation of wealth and, if so, in what proportion. The trial judge found that her payment of household expenses and insurance payments, along with the "proceeds" from the Coleman Street property, allowed Mr. Baranow to pay off the \$116,000 mortgage on both properties before July 1985. There is, thus, a finding that her contributions were linked to the accumulation of wealth, given that the Wall Street property was valued at \$942,500 at the time of trial. However, as the judge's findings with respect to Ms. Kerr's equity in the Coleman Street property cannot stand, this conclusion is considerably undermined. For much the same reason, there is no possibility on this record of evaluating the proportionate contributions to a joint family venture. In short, to attempt to resolve Ms. Kerr's unjust enrichment claim on its merits, using the record before this Court, involves too much uncertainty and risks injustice.

[198] In this respect, the *Kerr* appeal is in marked contrast to the *Vanasse* appeal. There, an unjust enrichment was conceded and the trial judge's findings of fact closely correspond to the analytical approach I have proposed. In the present appeal, while the findings made do not appear to demonstrate a joint family venture or a concomitant link to accumulated wealth, it would be unfair to reach that conclusion without giving an opportunity to the parties to present their evidence and arguments in light of the approach set out in these reasons.

j'ai exposée. Même si l'on suppose que M^{me} Kerr a établi le bien-fondé de sa demande relative à l'enrichissement injustifié, il est impossible en l'espèce d'appliquer équitablement cette méthode d'analyse sur la base du dossier soumis à notre Cour. Peu de conclusions de fait sont pertinentes en ce qui concerne la question clé de savoir si la relation des parties constituait une coentreprise familiale. De plus, même si l'on était convaincu que la preuve permettrait de trancher la question de la coentreprise familiale, le dossier ne permet pas de décider si les contributions de M^{me} Kerr à une coentreprise familiale étaient liées à l'accumulation de la richesse et, le cas échéant, dans quelle proportion. Le juge de première instance a estimé que le fait qu'elle ait payé les dépenses du ménage et les assurances, en plus du « produit » tiré de la maison de la rue Coleman, ont permis à M. Baranow de rembourser le prêt hypothécaire de 116 000 \$ sur les deux maisons avant juillet 1985. On peut donc dire que ses contributions étaient liées à l'accumulation de la richesse étant donné que la maison de la rue Wall était évaluée à 942 500 \$ au moment du procès. Cependant, comme les conclusions du juge relatives à la valeur nette que possédait M^{me} Kerr dans la maison de la rue Coleman ne peuvent être maintenues, cette conclusion est considérablement minée. Pour à peu près les mêmes raisons, il est impossible au vu du dossier d'évaluer les contributions proportionnelles apportées à la coentreprise familiale. Bref, tenter de trancher sur le fond la demande de M^{me} Kerr fondée sur l'enrichissement injustifié, sur la base du dossier soumis à la Cour, présente trop d'aléas et des risques d'injustice.

[198] À cet égard, le pourvoi *Kerr* diffère nettement du pourvoi *Vanasse*. Dans *Vanasse*, un enrichissement injustifié a été admis et les conclusions de fait de la juge de première instance correspondent étroitement à la méthode d'analyse que j'ai proposée. Dans *Kerr*, bien que les conclusions ne semblent pas établir l'existence d'une coentreprise familiale ou un lien concomitant avec la richesse accumulée, il serait injuste d'arriver à cette conclusion sans donner aux parties la possibilité de présenter leur preuve et leurs arguments selon la méthode énoncée dans les présents motifs.

[199] Reluctantly, therefore, I would order a new trial of Ms. Kerr's unjust enrichment claim, as well as affirm the Court of Appeal's order for a hearing of Mr. Baranow's counterclaim.

(3) Effective Date of Spousal Support

[200] The final issue is whether, as the Court of Appeal held, the trial judge erred in making his order for spousal support in favour of Ms. Kerr effective on the date she had commenced proceedings rather than on the first day of trial. In my respectful view, the Court of Appeal erred in its application of the relevant factors and ought not to have set aside the trial judge's order.

[201] The trial judge found that the appellant's income in 2006 was \$28,787 and the respondent's income was \$70,520, on the basis of their respective income tax returns. He then applied the Spousal Support Advisory Guidelines ("SSAG") to arrive at a range of \$1,304 to \$1,739 per month. He settled on an amount at the higher end of that range in order to assist Ms. Kerr in pursuing a private bed while waiting for a subsidized bed in a suitable facility closer to her family.

[202] The Court of Appeal agreed with the trial judge that Ms. Kerr was entitled to an award of spousal support given the length of the parties' relationship, her age, her fixed and limited income and her significant disability; she was entitled to a spousal support award that would permit her to live at a lifestyle that is closer to that which the parties enjoyed when they were together; and that the judge had properly determined the quantum of support. The Court of Appeal concluded, however, that the trial judge had erred in ordering support effective

[199] Ainsi, bien qu'à regret, je suis d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès relativement à la demande de M^{me} Kerr fondée sur l'enrichissement injustifié et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel prescrivant une audition de la demande reconventionnelle de M. Baranow.

(3) Date de prise d'effet de l'ordonnance alimentaire pour époux

[200] La dernière question est celle de savoir, comme l'a conclu la Cour d'appel, si le juge de première instance a commis une erreur en rendant en faveur de M^{me} Kerr une ordonnance alimentaire rétroactive à la date d'introduction de l'action plutôt qu'à la date du début du procès. À mon humble avis, la Cour d'appel a commis une erreur dans l'application des facteurs pertinents et n'aurait pas dû annuler l'ordonnance du juge de première instance.

[201] Le juge de première instance a conclu qu'en 2006, le revenu de l'appelante était de 28 787 \$ et que celui de l'intimé s'élevait à 70 520 \$, sur le fondement de leur déclaration de revenus respective. Il a ensuite appliqué les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux (« Lignes directrices ») pour arriver à une fourchette de 1 304 \$ à 1 739 \$ par mois. Il a accordé un montant se situant dans la partie supérieure de la fourchette pour que M^{me} Kerr soit en mesure de payer une chambre privée en attendant un lit subventionné dans un établissement approprié plus près de sa famille.

[202] La Cour d'appel était d'accord avec le juge de première instance pour dire que M^{me} Kerr avait droit à une pension alimentaire compte tenu de la durée de la relation des parties, de son âge, de son revenu fixe et limité et de l'importance de son invalidité, qu'elle avait droit à une pension alimentaire qui lui permettrait d'avoir un mode de vie se rapprochant davantage de celui qu'avaient les parties quand elles vivaient ensemble. La Cour d'appel était aussi d'avis que le juge avait bien déterminé le montant de la pension alimentaire.

the date Ms. Kerr had commenced proceedings. It faulted the judge in several respects: for apparently making the order as a matter of course rather than applying the relevant legal principles; for failing to consider that, during the interim period, Ms. Kerr had no financial needs beyond her means because she had been residing in a government-subsidized care facility and had not had to encroach on her capital; for failing to take account of the fact she had made no demand of Mr. Baranow to contribute to her interim support and had provided no explanation for not having done so; and for ordering retroactive support where, in light of the absence of an interim application, there was no blameworthy conduct on Mr. Baranow's part.

[203] The appellant submits that the decision to equate the principles pertaining to retroactive spousal support with those of retroactive child support has been done without any discussion or legal analysis. Furthermore, she argues that the Court of Appeal's reasoning places an untoward and inappropriate burden on applicants, essentially mandating that they apply for interim spousal support or lose their entitlement. Lastly, she argues that there is a legal distinction between retroactive support before and after the application is filed, and that in the latter circumstance there is less need for judicial restraint. I agree with the second and third of these submissions.

[204] There is no doubt that the trial judge had the discretion to award support effective the date proceedings had been commenced. This is clear from the British Columbia *Family*

Elle a toutefois conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en ordonnant que la pension alimentaire soit rétroactive à la date à laquelle M^{me} Kerr avait intenté les procédures. Elle a adressé au juge de première instance les reproches suivants : il a rendu l'ordonnance de façon automatique plutôt qu'en appliquant les principes juridiques pertinents; il n'a pas pris en compte le fait que, pendant la période transitoire, M^{me} Kerr n'avait aucun besoin financier au-delà de ses moyens car elle résidait dans un établissement de soins de santé subventionné par le gouvernement et elle n'avait pas eu à puiser dans son capital; il n'a pas pris en compte le fait qu'elle n'avait pas demandé à M. Baranow de lui verser une pension alimentaire provisoire et qu'elle n'avait pas expliqué pourquoi elle n'avait pas demandé une telle pension; il a ordonné la rétroactivité de la pension alors que, vu l'absence d'une demande provisoire, on n'avait rien à reprocher à M. Baranow.

[203] L'appelante soutient que la décision d'établir un parallèle entre les principes se rapportant à la pension alimentaire pour le conjoint avec effet rétroactif et ceux se rapportant à la pension alimentaire pour enfants avec effet rétroactif a été prise sans aucun examen ou analyse juridique. Elle soutient également que le raisonnement de la Cour d'appel impose un fardeau trop lourd et inapproprié aux demandeurs, les obligeant essentiellement à présenter une demande de pension alimentaire pour conjoint provisoire, sous peine de perdre leur droit aux aliments. Enfin, elle affirme que dans le cas de la pension alimentaire rétroactive, il faut en droit faire une distinction selon que la pension est rétroactive à une date antérieure ou postérieure au dépôt de la demande, et que dans ce dernier cas, il est moins nécessaire que le juge fasse preuve de retenue. Je suis d'accord avec l'appelante quant aux deuxième et troisième prétentions.

[204] Il ne fait aucun doute que le juge de première instance pouvait accorder une pension alimentaire devant prendre effet à la date d'institution des procédures. Cela ressort clairement de

Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128 (“*FRA*”), s. 93(5)(d):

93 . . .

- (5) An order under this section may also provide for one or more of the following:

. . . .

- (d) payment of support in respect of any period before the order is made;

[205] The appellant requested support effective the date her writ of summons and statement of claim were issued and served. She was and is not seeking support for the period before she commenced her proceedings, or for any period during which another court order for support was in effect. I note that she was obliged by statute to seek support within a year of the end of cohabitation: definition of “spouse”, s. 1(1)(b) of the *FRA*. Ms. Kerr made her application just over a month after the parties ceased living together.

[206] I will not venture into the semantics of the word “retroactive”: see *D.B.S. v. S.R.G.*, 2006 SCC 37, [2006] 2 S.C.R. 231, at paras. 2 and 69-70; *S. (L.) v. P. (E.)* (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254 (C.A.), at paras. 55-57. Rather, I prefer to follow the example of Bastarache J. in *D.B.S.* and consider the relevant factors that come into play where support is sought in relation to a period predating the order.

[207] While *D.B.S.* was concerned with child as opposed to spousal support, I agree with the Court of Appeal that similar considerations to those set out in the context of child support are also relevant to deciding the suitability of a “retroactive” award of spousal support. Specifically, these factors are the needs of the recipient, the conduct of the payor,

l'al. 93(5)d) de la *Family Relations Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 128, de la Colombie-Britannique (« *FRA* ») :

[TRADUCTION]

93 . . .

- (5) Une ordonnance rendue aux termes du présent article peut aussi prévoir au moins un des éléments suivants :

. . . .

- d) le paiement d'une pension alimentaire pour toute période antérieure à l'ordonnance;

[205] L'appelante a demandé une pension alimentaire à compter de la date à laquelle son bref d'assignation et sa déclaration ont été délivrés et signifiés. Elle n'a pas demandé, et ne demande toujours pas, de pension alimentaire pour la période antérieure au début des procédures, ou pour une période pendant laquelle une autre ordonnance alimentaire était en vigueur. Je remarque qu'elle était légalement tenue de présenter une demande de pension alimentaire dans l'année suivant la fin de la cohabitation : définition d'[TRADUCTION] « époux », al. 1(1)b) de la *FRA*. Madame Kerr a présenté sa demande à peine plus d'un mois après la fin de la cohabitation des parties.

[206] Je ne me risquerai pas dans les débats sémantiques sur la définition du mot « rétroacti[f] » : voir *D.B.S. c. S.R.G.*, 2006 CSC 37, [2006] 2 R.C.S. 231, par. 2, 69-70; *S. (L.) c. P. (E.)* (1999), 67 B.C.L.R. (3d) 254 (C.A.), par. 55-57. Je préfère plutôt suivre l'exemple du juge Bastarache dans *D.B.S.* et examiner les facteurs pertinents qui entrent en jeu lorsqu'une demande de pension alimentaire est présentée relativement à une période antérieure à l'ordonnance.

[207] Bien que l'arrêt *D.B.S.* porte sur la pension alimentaire pour enfants plutôt que pour le conjoint, je souscris à l'opinion de la Cour d'appel selon laquelle des considérations semblables à celles exposées dans le contexte de la pension alimentaire pour enfants sont également pertinentes pour décider de l'opportunité d'une pension

the reason for the delay in seeking support and any hardship the retroactive award may occasion on the payor spouse. However, in spousal support cases, these factors must be considered and weighed in light of the different legal principles and objectives that underpin spousal as compared with child support. I will mention some of those differences briefly, although certainly not exhaustively.

[208] Spousal support has a different legal foundation than child support. A parent-child relationship is a fiduciary relationship of presumed dependency and the obligation of both parents to support the child arises at birth. In that sense, the entitlement to child support is “automatic” and both parents must put their child’s interests ahead of their own in negotiating and litigating child support. Child support is the right of the child, not of the parent seeking support on the child’s behalf, and the basic amount of child support under the *Divorce Act*, R.S.C. 1985, c. 3 (2nd Supp.), (as well as many provincial child support statutes) now depends on the income of the payor and not on a highly discretionary balancing of means and needs. These aspects of child support reduce somewhat the strength of concerns about lack of notice and lack of diligence in seeking child support. With respect to notice, the payor parent is or should be aware of the obligation to provide support commensurate with his or her income. As for delay, the right to support is the child’s and therefore it is the child’s, not the other parent’s position that is prejudiced by lack of diligence on the part of the parent seeking child support: see *D.B.S.*, at paras. 36-39, 47-48, 59, 80 and 100-104. In contrast, there is no presumptive entitlement to spousal support and, unlike child support, the spouse is in general not under any legal obligation to look out for the separated spouse’s legal interests. Thus, concerns about notice, delay and misconduct generally carry more weight in relation to claims for spousal support: see, e.g., M. L. Gordon, “Blame Over: Retroactive Child and Spousal Support in the Post-Guideline Era”

alimentaire « rétroactive ». Plus précisément, ces facteurs incluent les besoins du bénéficiaire, le comportement du débiteur, la raison du retard dans la présentation de la demande de pension alimentaire et tout préjudice que peut causer une pension rétroactive au conjoint débiteur. Cependant, dans les cas de pension alimentaire pour conjoint, ces facteurs doivent être examinés et soupesés à la lumière de principes et objectifs juridiques qui diffèrent de ceux de la pension pour enfants. J’aborde brièvement certaines de ces différences, mais sans les approfondir.

[208] La pension alimentaire pour le conjoint n’a pas le même fondement juridique que la pension pour enfants. La relation parent-enfant est une relation fiduciaire de dépendance présumée et l’obligation du père et de la mère de subvenir aux besoins de leur enfant s’applique dès la naissance. En ce sens, l’enfant acquiert le droit aux aliments « automatiquement » et le père et la mère doivent privilégier les intérêts de leur enfant plutôt que les leurs au moment de négocier la pension et de la débattre en justice. Le droit aux aliments appartient à l’enfant, et non au parent qui demande la pension au nom de l’enfant, et le montant de base de la pension pour enfants en vertu de la *Loi sur le divorce*, L.R.C. 1985, ch. 3 (2^e suppl.), (ainsi que plusieurs lois provinciales en matière de pension alimentaire pour enfants) dépend maintenant du revenu du débiteur, et non d’une pondération hautement discrétionnaire des ressources et des besoins. Ces aspects de la pension alimentaire pour enfants apaisent quelque peu les préoccupations relatives à l’absence d’avis et au manque de diligence dans les demandes de pension alimentaire pour enfants. En ce qui concerne l’avis, le parent débiteur sait, ou devrait savoir, qu’il est tenu de payer des aliments proportionnellement à son revenu. En ce qui concerne le retard à agir, le droit aux aliments appartient à l’enfant et, par conséquent, c’est l’enfant, et non l’autre parent, qui subit un préjudice en raison du manque de diligence du parent demandant la pension : voir *D.B.S.*, par. 36-39, 47-48, 59, 80, 100-104. Par contre, le conjoint n’a aucun droit présomptif à la pension et, contrairement à la pension pour enfants, le conjoint n’est généralement pas tenu de protéger les intérêts

(2004-2005), 23 *C.F.L.Q.* 243, at pp. 281 and 291-92.

[209] Where, as here, the payor's complaint is that support could have been sought earlier, but was not, there are two underlying interests at stake. The first relates to the certainty of the payor's legal obligations; the possibility of an order that reaches back into the past makes it more difficult to plan one's affairs and a sizeable "retroactive" award for which the payor did not plan may impose financial hardship. The second concerns placing proper incentives on the applicant to proceed with his or her claims promptly (see *D.B.S.*, at paras. 100-103).

[210] Neither of these concerns carries much weight in this case. The order was made effective the date on which the proceedings seeking relief had been commenced, and there was no interim order for some different amount. Commencement of proceedings provided clear notice to the payor that support was being claimed and permitted some planning for the eventuality that it was ordered. There is thus little concern about certainty of the payor's obligations. Ms. Kerr diligently pursued her claim to trial and that being the case, there is little need to provide further incentives for her or others in her position to proceed with more diligence.

[211] In *D.B.S.*, Bastarache J. referred to the date of effective notice as the "general rule" and "default option" for the choice of effective date of the order (paras. 118 and 121; see also para. 125). The date of the initiation of proceedings for spousal support has been described by the Ontario Court of Appeal as the "usual commencement date", absent a reason not to make the order effective as of that date: *MacKinnon v. MacKinnon* (2005), 75 O.R. (3d) 175, at para. 24. While in my view, the decision

juridiques du conjoint séparé. Par conséquent, les préoccupations au sujet de l'avis, du retard et de la conduite répréhensible ont généralement plus de poids en ce qui concerne les demandes d'aliments pour conjoint : voir, par exemple, M. L. Gordon, « Blame Over : Retroactive Child and Spousal Support in the Post-Guideline Era » (2004-2005), 23 *C.F.L.Q.* 243, p. 281 et 291-292.

[209] Lorsque, comme en l'espèce, le débiteur se plaint de ce que la pension aurait pu être demandée plus tôt, mais ne l'a pas été, deux intérêts sous-jacents entrent en jeu. Le premier concerne la certitude des obligations juridiques du débiteur; la possibilité qu'une ordonnance s'applique rétroactivement complique la planification des finances personnelles et une forte ordonnance alimentaire « rétroactive » non prévue par le débiteur peut lui causer des difficultés financières. Le deuxième vise à inciter le demandeur à présenter sa demande promptement (voir *D.B.S.*, par. 100-103).

[210] Ni l'une ni l'autre de ces préoccupations n'a beaucoup d'importance en l'espèce. L'ordonnance était rétroactive à la date où les procédures visant à obtenir un redressement ont été intentées, et il n'y a eu aucune ordonnance provisoire pour un montant différent. L'introduction des procédures a clairement avisé le débiteur qu'une pension alimentaire était demandée et lui a permis de se préparer à l'éventualité qu'elle soit ordonnée. Il n'y a donc pas vraiment lieu de s'interroger sur la certitude des obligations du débiteur. Madame Kerr a poursuivi l'affaire avec diligence et, cela étant, il n'est pas vraiment nécessaire de mettre en place d'autres mesures propres à l'inciter, elle ou d'autres personnes dans sa situation, à procéder de façon plus diligente.

[211] Dans l'arrêt *D.B.S.*, le juge Bastarache a dit que la date de l'information réelle du parent débiteur devrait « généralement être retenue » comme étant, « de prime abord », la date d'application de l'ordonnance (par. 118, 121; voir également le par. 125). La Cour d'appel de l'Ontario a retenu la date de l'introduction de la demande de pension alimentaire pour conjoint comme étant la [TRADUCTION] « date de prise d'effet habituelle », en l'absence de toute raison de ne pas faire entrer l'ordonnance en

to order support for a period before the date of the order should be the product of the exercise of judicial discretion in light of the particular circumstances, the fact that the order is sought effective from the commencement of proceedings will often be a significant factor in how the relevant considerations are weighed. It is important to note that, in *D.B.S.*, all four litigants were requesting that child support payments reach back to a period in time preceding their respective applications; such is not the case here.

[212] Other relevant considerations noted in *D.B.S.* include the conduct of the payor, the circumstances of the child (or in the case of spousal support, the spouse seeking support), and any hardship occasioned by the award. The focus of concern about conduct must be on conduct broadly relevant to the support obligation, for example, concealing assets or failing to make appropriate disclosure: *D.B.S.*, at para. 106. Consideration of the circumstances of the spouse seeking support, by analogy to the *D.B.S.* analysis, will relate to the needs of the spouse both at the time the support should have been paid and at present. The comments of Bastarache J. at para. 113 of *D.B.S.* may be easily adapted to the situation of the spouse seeking support: “A [spouse] who underwent hardship in the past may be compensated for this unfortunate circumstance through a retroactive award. On the other hand, the argument for retroactive [spousal] support will be less convincing where the [spouse] already enjoyed all the advantages (s)he would have received [from that support]”. As for hardship, there is the risk that a retroactive award will not be fashioned having regard to what the payor can currently afford and may disrupt the payor’s ability to manage his or her finances. However, it is also critical to note that this Court in *D.B.S.* emphasized the need for flexibility and a holistic view of each matter on its own merits; the same flexibility is appropriate when dealing with “retroactive” spousal support.

vigueur à cette date : *MacKinnon c. MacKinnon* (2005), 75 O.R. (3d) 175, par. 24. Bien que, à mon avis, la décision de faire rétroagir le versement des aliments doive résulter du pouvoir discrétionnaire exercé à la lumière des circonstances particulières, le fait que l’ordonnance soit demandée à compter de l’introduction de la demande sera souvent un facteur important à considérer pour savoir quelle importance accorder aux considérations pertinentes. Il importe de souligner que, dans *D.B.S.*, les quatre parties demandaient que les paiements de pension alimentaire pour enfants remontent à une période antérieure au dépôt de leurs demandes respectives; ce n’est pas le cas en l’espèce.

[212] Parmi les autres facteurs pertinents signalés dans *D.B.S.*, mentionnons le comportement du débiteur, la situation de l’enfant (ou, dans le cas d’une pension alimentaire pour conjoint, la situation du conjoint qui réclame une pension), et toute difficulté occasionnée par l’ordonnance. Le comportement en question doit avoir un lien quelconque avec l’obligation alimentaire, par exemple, dissimuler certains biens ou ne pas communiquer l’information de manière appropriée : *D.B.S.*, par. 106. L’examen de la situation du conjoint qui demande la pension, par analogie avec l’analyse exposée dans *D.B.S.*, se rattachera aux besoins du conjoint au moment où la pension aurait dû être versée et au moment présent. Les commentaires formulés par le juge Bastarache au par. 113 de *D.B.S.* s’adaptent facilement à la situation du conjoint qui demande une pension alimentaire : « [le conjoint] qui a connu des difficultés dans le passé peut obtenir réparation grâce à une ordonnance rétroactive. Par contre, une telle ordonnance est plus difficile à justifier dans le cas où [le conjoint] a bénéficié de tous les avantages qu’il aurait obtenus [de cette pension] ». En ce qui concerne les difficultés, il y a le risque qu’une ordonnance rétroactive ne tienne pas compte de ce que le débiteur peut se permettre et que cela nuise à la capacité du débiteur de gérer ses finances. Cependant, il est aussi essentiel de souligner que, dans *D.B.S.*, notre Cour a mis l’accent sur le besoin de souplesse et a considéré l’affaire dans sa globalité en fonction des faits de l’espèce; la même souplesse est appropriée dans le cas des pensions alimentaires pour conjoint « rétroactives ».

[213] In light of these principles, my view is that the Court of Appeal made two main errors.

[214] First, it erred by finding that the circumstances of the appellant were such that there was no need prior to the trial. The trial judge found, and the Court of Appeal did not dispute, that the appellant was entitled to non-compensatory spousal support, at the high end of the range suggested by the SSAG, for an indefinite duration. Entitlement, quantum, and the indefinite duration of the order were not appealed before this Court. It is clear that Ms. Kerr was in need of support from the respondent at the date she started her proceedings and remained so at the time of trial. The Court of Appeal rightly noted the relevant factors, such as her age, disability, and fixed income. However, the Court of Appeal did not describe how Ms. Kerr's circumstances had changed between the commencement of proceedings and the date of trial, nor is any such change apparent in the trial judge's findings of fact. As I understand the record, one of the objectives of the support order was to permit Ms. Kerr to have access to a private pay bed while waiting for her name to come up for a subsidized bed in a suitable facility closer to her son's residence. From the date she commenced her proceedings until the date of trial, she resided in the Brock Fahrni Pavilion in a government-funded extended care bed in a room with three other people. In my respectful view, her need was constant throughout the period. If the Court of Appeal's rationale was that Ms. Kerr's need would only arise once she actually had secured the private pay bed, its decision to make the order effective the first day of trial seems inconsistent with that approach. The Court of Appeal did not suggest that her need was any different on that day than on the day she had commenced her proceedings. Nor did the court point to any financial hardship that the trial judge's award would have on Mr. Baranow.

[213] À la lumière de ces principes, j'estime que la Cour d'appel a commis deux erreurs principales.

[214] Premièrement, elle a commis une erreur en concluant que la situation de l'appelante était telle qu'elle n'avait pas besoin de soutien avant le procès. Le juge de première instance a conclu, et la Cour d'appel n'a pas contesté cette conclusion, que l'appelante avait droit à une pension alimentaire non compensatoire pour conjoint, dans la partie supérieure de la fourchette proposée dans les Lignes directrices, pour une période indéfinie. Le droit à la pension, le montant de celle-ci et la période indéfinie de l'ordonnance ne font pas l'objet du présent pourvoi. Il est clair que M^{me} Kerr avait besoin que l'intimé lui verse une pension alimentaire à la date où elle a introduit les procédures et qu'elle en avait toujours besoin lors du procès. La Cour d'appel a signalé à juste titre les facteurs pertinents, tels que son âge, son invalidité et son revenu fixe. Cependant, la Cour d'appel n'a pas expliqué de quelle façon la situation de M^{me} Kerr avait changé entre le début de l'instance et la date du procès et le changement ne ressort pas non plus clairement des conclusions de fait du juge de première instance. Si je comprends bien le dossier, un des objectifs de l'ordonnance alimentaire était de permettre à M^{me} Kerr d'avoir accès à une chambre privée pendant qu'elle attendait un lit subventionné dans un établissement convenable près de chez son fils. À compter de la date d'introduction des procédures jusqu'à la date du procès, elle habitait dans le pavillon Brock Fahrni qui se trouve dans un établissement de soins prolongés subventionné par le gouvernement et elle occupait une chambre avec trois autres personnes. À mon humble avis, elle avait besoin de soutien pendant toute cette période. Si, selon le raisonnement de la Cour d'appel, le besoin de M^{me} Kerr ne se ferait sentir qu'une fois qu'elle aurait sa chambre privée, sa décision de faire rétroagir l'ordonnance au premier jour du procès semble incompatible avec ce point de vue. La Cour d'appel n'a pas laissé entendre qu'il y avait une différence sur le plan des besoins qu'elle avait cette journée-là et ceux qu'elle avait au moment où elle a introduit les procédures. Elle n'a pas non plus indiqué que l'ordonnance alimentaire du juge de première instance causerait des difficultés financières à M. Baranow.

[215] Respectfully, the Court of Appeal erred in principle in setting aside the judge's order effective as of the date of commencement of proceedings on the ground that Ms. Kerr had no need during that period, while upholding the judge's findings of need in circumstances that were no different from those existing at the time proceedings were commenced.

[216] Second, the Court of Appeal in my respectful view was wrong to fault Ms. Kerr for not bringing an interim application, in effect attributing to her unreasonable delay in seeking support for the period in question. Ms. Kerr commenced her proceedings promptly after separation and, in light of the fact that the trial occurred only about thirteen months afterward, she apparently pursued those proceedings to trial with diligence. There was thus clear notice to Mr. Baranow that support was being sought and he could readily take advice on the likely extent of his liability. Given the high financial, physical, and emotional costs of interlocutory applications, especially for a party with limited means and a significant disability such as Ms. Kerr, it was in my respectful view unreasonable for the Court of Appeal to attach such serious consequences to the fact that an interim application was not pursued. The position taken by the Court of Appeal to my way of thinking undermines the incentives which should exist on parties to seek financial disclosure, pursue their claims with due diligence, and keep interlocutory proceedings to a minimum. Requiring interim applications risks prolonging rather than expediting proceedings. The respondent's argument based on the fact that a different legal test would have applied at the interim support stage is unconvincing. After a full trial on the merits, the trial judge made clear and now unchallenged findings of need on the basis of circumstances that had not changed between commencement of proceedings and trial.

[215] Avec égards, la Cour d'appel a commis une erreur de principe en annulant l'ordonnance du juge qui prenait effet à la date d'introduction de la demande au motif que M^{me} Kerr n'avait aucun besoin pendant cette période, tout en confirmant les conclusions du juge se rapportant aux besoins de M^{me} Kerr dans une situation identique à celle qui existait au moment où la demande a été introduite.

[216] Deuxièmement, à mon avis, la Cour d'appel a eu tort de reprocher à M^{me} Kerr de ne pas avoir présenté une demande provisoire, lui attribuant de ce fait un retard déraisonnable dans le dépôt de la demande de pension alimentaire pour la période en question. Madame Kerr a introduit sa demande peu de temps après la séparation et, compte tenu du fait que le procès n'a débuté que treize mois plus tard, elle semble avoir poursuivi les procédures avec diligence. Monsieur Baranow avait donc reçu un avis clair de la pension alimentaire demandée et il aurait facilement pu demander conseil concernant l'étendue possible de sa responsabilité. Compte tenu des coûts financiers, matériels et affectifs élevés des requêtes interlocutoires, surtout pour une personne dont les moyens sont limités et qui souffre d'une invalidité importante comme M^{me} Kerr, j'estime qu'il était déraisonnable pour la Cour d'appel d'attacher des conséquences aussi graves au fait qu'une demande provisoire n'ait pas été présentée. À mon avis, la position adoptée par la Cour d'appel n'incite pas les parties à rechercher la communication de renseignements financiers, à poursuivre leurs réclamations avec diligence raisonnable et à restreindre au minimum les procédures interlocutoires. Le fait d'exiger des demandes provisoires risque de prolonger les procédures au lieu de les accélérer. L'argument de l'intimé fondé sur le fait qu'un critère juridique différent se serait appliqué à l'étape de la pension alimentaire provisoire est peu convaincant. Après un procès complet sur le fond, le juge de première instance est arrivé à des conclusions claires et maintenant incontestées quant au besoin de soutien en se fondant sur des circonstances qui n'avaient pas changé entre l'introduction de la demande et le procès.

[217] In short, there was virtually no delay in applying for maintenance, nor was there any inordinate delay between the date of application and the date of trial. Ms. Kerr was in need throughout the relevant period, she suffered from a serious physical disability, and her standard of living was markedly lower than it was while she lived with the respondent. Mr. Baranow had the means to provide support, had prompt notice of her claim, and there was no indication in the Court of Appeal's reasons that it considered the judge's award imposed on him a hardship so as to make that award inappropriate.

[218] While it is regrettable that the judge did not elaborate on his reasons for making the order effective as of the date proceedings had been commenced, the relevant legal principles applied to the facts as he found them support the making of that order and the Court of Appeal erred in holding otherwise.

[219] In summary, I conclude that the Court of Appeal erred in setting aside the portion of the judge's order for support between the commencement of proceedings and the beginning of trial. I would restore the order of the trial judge making spousal support effective September 14, 2006.

D. *Disposition*

[220] I would allow the appeal in part. Specifically, I would:

- a. allow the appeal on the spousal support issue and restore the order of the trial judge with respect to support;
- b. allow the appeal with respect to the Court of Appeal's decision to dismiss Ms. Kerr's unjust enrichment claim and order a new trial of that claim;
- c. dismiss the appeal in relation to Ms. Kerr's claim of resulting trust and the ordering of a

[217] En résumé, M^{me} Kerr n'a pas tardé à déposer sa demande de pension alimentaire et il n'y a pas eu de retard excessif entre la date de la demande et le début du procès. Madame Kerr avait besoin de soutien pendant toute la période pertinente; elle souffrait d'une grave invalidité physique et son niveau de vie était nettement inférieur à celui qu'elle avait lorsqu'elle habitait avec l'intimé. Monsieur Baranow avait les moyens de lui verser une pension, il avait reçu sans délai un avis de sa réclamation, et rien dans les motifs de la Cour d'appel n'indiquait qu'elle considérait que la pension alimentaire imposée par le juge mettait M. Baranow dans une situation financière difficile, de sorte que l'ordonnance était inappropriée.

[218] Bien qu'il soit regrettable que le juge n'ait pas expliqué pourquoi il faisait rétroagir l'ordonnance à la date d'introduction des procédures, les principes juridiques pertinents qui ont été appliqués aux faits qu'il avait constatés appuient le prononcé de cette ordonnance et la Cour d'appel a commis une erreur en décidant autrement.

[219] En somme, je conclus que la Cour d'appel a commis une erreur en annulant la partie de l'ordonnance alimentaire du juge qui couvrait la période écoulée entre l'introduction des procédures et le début du procès. Je suis d'avis de rétablir l'ordonnance du juge de première instance en donnant effet à la pension alimentaire pour conjoint au 14 septembre 2006.

D. *Dispositif*

[220] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en partie. Plus précisément, je suis d'avis :

- a. d'accueillir le pourvoi sur la question de la pension alimentaire et de rétablir l'ordonnance alimentaire du juge de première instance;
- b. d'accueillir le pourvoi en ce qui concerne la décision de la Cour d'appel de rejeter la demande de M^{me} Kerr fondée sur l'enrichissement injustifié et d'ordonner une nouvelle audition de cette demande;
- c. de rejeter le pourvoi en ce qui concerne la demande de M^{me} Kerr relative à la fiducie

new hearing of Mr. Baranow's counterclaim and affirm the order of the Court of Appeal in relation to those issues.

résultaire et l'ordonnance de nouvelle audition de la demande reconventionnelle de M. Baranow et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel quant à ces questions.

[221] As Ms. Kerr has been substantially successful, I would award her costs throughout.

[221] Comme M^{me} Kerr a eu gain de cause en bonne partie, je suis d'avis de lui accorder les dépens dans toutes les cours.

Appeal 33157 allowed in part with costs.

Pourvoi 33157 accueilli en partie avec dépens.

Appeal 33358 allowed with costs.

Pourvoi 33358 accueilli avec dépens.

Solicitors for the appellant Margaret Kerr: Hawthorne, Piggott & Company, Burnaby.

Procureurs de l'appelante Margaret Kerr: Hawthorne, Piggott & Company, Burnaby.

Solicitor for the respondent Nelson Baranow: Susan G. Label, Vancouver.

Procureur de l'intimé Nelson Baranow: Susan G. Label, Vancouver.

Solicitors for the appellant Michele Vanasse: Nelligan O'Brien Payne, Ottawa.

Procureurs de l'appelante Michele Vanasse: Nelligan O'Brien Payne, Ottawa.

Solicitors for the respondent David Seguin: MacKinnon & Phillips, Ottawa.

Procureurs de l'intimé David Seguin: MacKinnon & Phillips, Ottawa.